

un hijo fue desheredado, los otros acrecían su cuota por el monto que le hubiera correspondido a éste.

3. En principio el pretor no hacía, a los efectos de la *b.p. contra tabulas*, ninguna diferencia entre hijos varones y mujeres. Ello otorgaba una situación de preferencia a las mujeres, puesto que por el *ius civile*, en caso de ser *sui heredes*, lo único que podían hacer era, en caso de falencia de sus hermanos (p.ej., emancipados), acrecentar su parte. En cambio, acá, al pedir la *b.p. contra tabulas*, descartaban a los herederos extraños, pudiendo por ello acrecentar más sus cuotas.

4. Así, veamos este caso: El *pater* había instituido heredero a su amigo Ticio, es decir, un heredero extraño. Desheredó a su hijo A. Pero, a su vez, preterió a su hija B., existiendo un tercer hijo C que estaba emancipado. En este caso, B y C pueden pedir la *b.p. contra tabulas* por una cuota igual, es decir, la mitad de la herencia. Ticio es rechazado como un heredero puramente nominal (*sine re*). Y el hijo A tampoco obtiene nada, por haber sido desheredado.

Pero, según nos dice Gayo (2.126), por un rescripto del emperador Antonino (Antonino Pío, o probablemente Marco Aurelio), las mujeres no pueden obtener por la *b.p. contra tabulas* más allá de lo que les correspondiera por el *ius adiacendi* según la herencia *ab intestato*. Este principio se observa también respecto de las mujeres emancipadas.

§ 632. Sin embargo, no resulta cierto decir que la medida pretoriana de la *b.p. contra tabulas* anulaba el testamento. Acá se produce también una combinación entre herencia testamentaria y *ab intestato* siendo también otra excepción a la regla *Nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest*.

Pese a que a primera vista el ordenamiento puede resultar intrincado, en el fondo es más sencillo de lo que parece: El pretor se limita a introducir el principio de la cognación, modificando en consecuencia la calidad de los que podían pedir, en detrimento de los herederos extraños. Pero el resto de las cláusulas testamentarias continúa manteniendo su validez. Así, el heredero pretoriano debe cumplir los legados hechos en beneficio de los ascendientes y descendientes del testador, así como el legado dejado por él a título de dote, a su mujer o a su nuera (Ulp., D.37.5.1 pr.; EP, § 143). Igualmente son válidas la sustitución pupilar (Africano, D.28.6.34.2), así como las manumisiones, daciones de tutores, etc., es decir, todas aquellas cláusulas que surjan de la evidente voluntad del testador, salvo por supuesto lo referente al régimen pretoriano de la *b.p. contra tabulas* en cuanto a los *liberi* preteridos.

1. Las reglas de la *collatio bonorum** y de la *collatio dotis** se aplicaban también a la *b.p. contra tabulas* (Ulp., D.37.6.1 pr.; Jul., D.4.3).

2. El descendiente preterido tiene un año de plazo para pedir la *b.p. contra tabulas* (Inst., 3.9.5).

3. En lo que se refiere a la herencia del patrono, recordemos que por la ley de las XII Tabas, sólo heredaba a su liberto si moría intestado y sin dejar *sui heredes* (5.8; Ulp., 29.1; Gayo, 3.40). Pero si el liberto hacía testamento podía preterir impunemente a su patrono (Gayo, 3.40).

a) El pretor obliga al liberto a dejarle por testamento la mitad de sus bienes, y si no le dejara nada o le dejara menos de la mitad, entonces le era dado al patrono la *b.p. contra tabulas* por la mitad de dichos bienes contra los herederos instituidos (Gayo, 3.41; EP, § 150).

b) Pero, sin embargo, si existían *sui heredes* "sanguíneos" (naturales, para distinguirlos de los adoptivos y de la *uxor in manu*) del liberto, incluidos los emancipados y los dados en adopción y éstos hubieran sido instituidos por una parte cualquiera en el testamento o hubiesen sido preteridos, si pedían la *b.p. contra tabulas* excluyen la del patrono (Gayo, 3.41; EP, § 150).

c) Esta medida de protección del patrono, asegurándole en principio la cuota de la mitad de los bienes, es análoga al supuesto de herencia *ab intestato*, cuando el liberto no ha dejado *sui iuris* sanguíneos: así a un hijo adoptivo o a la *uxor in manu* o la nuera *in manu*: se le concede la *bonorum possessio* por la mitad en contra de dichos *sui heredes* (Gayo, 3.41; ver *supra*, § 631.3).

d) Si el liberto realiza actos de disposición en forma dolosa para disminuir su patrimonio, o hechas *mortis causa*, el patrono tenía la *actio Fabiana* (caso de herencia testamentaria; EP, § 151.1) y la *actio Calvisiana* (caso de herencia *ab intestato*; EP, § 151.2) para pedir la revocación de aquéllos en la medida en que hayan perjudicado su cuota de la mitad calculada antes de la realización de ellos.

III. La querella inofficiosi testamenti.

§ 633. Hacia finales de la República hubo una reacción contra la conducta del testador que de manera injustificada, haciendo mal uso de la amplia libertad que le otorgaba el *ius civile* de testar o desheredar, excluía sin causa justificada o instituye por una porción escasa a sus herederos familiares cercanos.

Si bien el testamento era válido conforme al *ius civile* estricto, se consideraba acá que el testador había faltado al deber del afecto familiar (*officium pietatis*), otorgándose a dichos allegados próximos; la posibilidad de atacar el testamento como "inoficioso" (*inofficiosum; contra officium pietatis factum*), por medio de la querella *inofficiosi testamenti*, logrando que se anulara y se abría la herencia *ab intestato* (Paulo, 4.5.1).

Lo curioso era que la fundamentación de esta querella no era estrictamente jurídica, sino más bien moral por haberse afectado los usos y costumbres que implicaban el *officium pietatis*. Se utilizaba un argumento retórico, según el cual el testador que hubiera perjudicado a sus allegados próximos es como si estuviera bajo los efectos de una perturbación mental (*color insanias*; Marciano, D.5.2.2).

Representaba una indudable conquista de la equidad y del *ius naturale* sobre el derecho estricto (Paulo habla de *ratio naturalis*, D.43.207 pr.). Es, en el fondo, un gran reconocimiento del parentesco cognático y del deber de afección que de él dimana.

1. El conocimiento de este procedimiento en la época clásica resulta bastante difícil. Gayo no la menciona, y sólo contamos con un corto comentario de Paulo (4.5), aparte del también escaso título del Código Theodosiano (2.19). Por tanto, lo que tenemos son los párrafos del Digesto (5.2), evidentemente muy interpolados, así como las leyes que figuran en el Código (3.28-30) y el título sobre el "testamento inoficioso" de las Institutas de Justiniano (2.18).

La denominación correcta es la de querella *inofficiosi testamenti* (la expresión *querela*, usada por los autores modernos, es un anacronismo).

2. Comenzó a ser admitida en el tribunal de los centumviro, actuándose por la vía del *sacramentum*. Ya desde la época clásica se admitió la vía del procedimiento *extra ordinem*, ya ante funcionarios imperiales y en las provincias ante los gobernadores (C.3.28.17, año 284).

Al carecer de una base legal, estando asentada en la argumentación moral, los jueces tenían una muy amplia libertad para apreciar las circunstancias especiales de cada caso y llegar así a la conclusión de si el testador había o no infringido el deber de la *pietas*.

3. Es de destacar el preciosismo de la argumentación, puesto que no se decía que el testador estuviera demente, puesto que en ese caso el testamento hubiese sido directamente nulo, ya que un *furiosus* no tenía la *testamenti factio*. En cambio, el argumento retórico del *color insanias* que equivalía a "como si estuviera demente" por haber infringido la regla moral, que debió ser del gusto de los bizantinos, no significa una influencia de los retóricos —no siempre bien apreciados— respecto de los juristas (cfr. Cic., Brutus, 67.236).

§ 634. Ejercicio de la querella inofficiosi testamenti.

I. Aquellos que podían atacar como inoficioso el testamento eran:

(i) Los descendientes y los ascendientes, en forma recíproca, sin distinguir si se trata de agnados o de cognados, sean varones o mujeres,

se trate del padre o de la madre; es decir, todos aquellos descendientes o ascendientes que pudieran pedir la herencia civil o pretoriana (Ulp., D.5.2.1; D.4.6.2; Paulo, D.4.7; Ulp., D.4.8; Inst., 2.18 pr.).

(ii) También los hermanos bilaterales (*germani*) e incluso los medios hermanos "sanguíneos" (no los "uterinos"); pero, para todos ellos, sólo en el caso de que el testador hubiese instituido heredero a una persona vil (*turpis persona*: así, un gladiador o alguien tachado de infame; Inst., 2.18.1; Constantino, C.3.28.27, año 319).

1. La constitución de Constantino (C.Th. 2.19.1-2)

sólo se refería a los hermanos y hermanas agnados, pero Justiniano, interpolando esta decisión, la admitió a todos los hermanos "consanguíneos" (sean agnados o no) y a los que tienen el mismo padre y distinta madre ("sanguíneos"), excluyendo solamente a los "uterinos" (C.3.28.27).

2. En tiempos de Justiniano, en caso de *adoptio plena* el hijo adoptivo tiene la posibilidad de atacar por inoficioso al testamento. En cuanto al adoptado por la *adoptio minus plena*, no puede atacar el testamento de su *pater adoptivo*, pero sí contra el de su padre natural, salvo que tuviera otra forma de obtener sus bienes (así, p.ej., por la *b.p. contra tabulas* o por la *quarta Antonina*, si habiendo sido adrogado como impúber, fue luego desheredado); Inst., 2.18.2.

Fuera de éstos, los cognados en mayor grado estaban excluidos de atacar el testamento por la querella *inofficiosi testamenti* (Ulp., D.5.2.1; Inst., 2.18.1).

II. El que pretendía la querella *inofficiosi testamenti*, debía demostrar que había sido desheredado o preterido sin causa justificada; o que por dicho testamento haya recibido —por vía de herencia, legado o donación *mortis causa*— una porción que se consideraba insuficiente.

En lo que atañe a las causas de desheredación, no había ninguna disposición expresa que señalara cuáles eran. Le correspondía alegarlas y probarlas al querellante, quedando su apreciación al arbitrio judicial. Además, en un principio, quedó al arbitrio del juez el determinar la suficiencia o la insuficiencia de lo que se recibía, pero finalmente se entendió (influencia de la *lex Falcidia*) que por lo menos el testador le debía haber dejado una cuarta parte de lo que les hubiera correspondido *ab intestato* (Ulp., D.5.2.8.8; Inst., 2.18.3 y 6). De este modo, si el testador dejó a sus herederos una cuarta parte de lo que les hubiera correspondido *ab intestato*, su testamento es seguro e inatacable (Ulp., D.5.2.8.6).

1. Como dato curioso, en una constitución de Theodosio y Valentiniano (C.Th., 16.7.23), esta cuarta

parte es denominada formalmente como "la Falcidia", lo cual vuelve a ocurrir en otra constitución de Arcadio y de Honorio (C.9.8.5.3). Pero las expresiones más usuales fueron *quarta debita portio* ("cuarta parte de la porción debida"; Ulp., D.5.2.8.8) o también *quarta legitima pars* (así, en Inst., 2.18.3: "cuarta de la parte legítima"). Y también *portio legitima* (C.3.28.23; 30 y 31).

Esta terminología no pudo haber sido clásica por la sencilla razón de que el monto quedó fijado, no por ley, sino por la práctica judicial. Para los clásicos, decir *legítima portio* o *legítima pars* significaba solamente "la porción reconocida en la Ley de las XII Tablas". Si los autores posclásicos y Justiniano la denominan así es porque hacen referencia a la porción calculada respecto de lo que les hubiera correspondido *ab intestato*. Luego, los comentaristas hablarán pura y simplemente de "la legítima", y es así como llega al derecho moderno y actual.

2. Para determinar lo que le corresponde por esta *quarta pars legitima*, había que establecer primero el patrimonio neto del testador en el momento de su fallecimiento (C.3.28.6). Hay que computar todos los bienes y créditos, incluso los sometidos a condición, por lo menos mientras no se decida el hecho condicional. Los bienes que han sido legados o donados *mortis causa* se incluyen en la masa hereditaria, puesto que hasta ese momento están dentro del patrimonio del testador (C.8.50.5-12; 8.57.2).

Había que descontar las deudas que pesan sobre la herencia y los gastos funerarios, así como el valor de los esclavos manumitidos por el testamento (Ulp., D.5.2.8.9).

Una vez calculado el monto de la masa hereditaria, había que calcular "la cuarta parte" de lo que le hubiera correspondido al heredero en la herencia *ab intestato*. Se le computaba en su contra todo aquello que el heredero que se querellaba hubiera recibido por causa de muerte, ya como heredero, como legatario, como fideicomisario o por una donación *mortis causa* (Inst., 2.18.6; C. 3.28.36.1). En efecto, con ello este heredero obtenía bienes respecto de los cuales no podía aducir que el testador había incumplido el *officium pietatis*.

Como se ve, sin entrar en mayores detalles, esta cuarta parte se calcula como la *quarta Falcidia*.

3. Las donaciones *inter vivos*, en principio, no entran en el cómputo de la masa hereditaria, puesto que no estaban en el patrimonio del testador al momento de su muerte. Pero Alejandro Severo (Paulo, D.31.87.3), ante un caso en el cual una ahueña, para impedir la *querella*, consumió su patrimonio en las donaciones hechas a su nieto, aceptó que se las admitiera, decidiendo que "exige la razón que se revoque respecto de la mitad de lo que se donó".

Este precedente será completado por la legislación posterior (FV. §§ 270-271-280-282; C.3.29). Se admitió una *querella inofficiosi donationis* (a semejanza de la *q. testamenti*; Constancio, C.3.29.9, año

361). Si bien los textos del Código no son del todo claros, se admite que los herederos que tienen derecho a la "legítima" pueden dirigirse contra los beneficiados por las donaciones realizadas por el testador *inter vivos*, a los efectos de defender su *portio legitima*. No se trataba de provocar la nulidad de ellas, sino de reducirlas hasta un monto que asegure la "legítima" (Diod. Maxim., C.3.29.7-8).

Igualmente, si el *pater*, cuando hizo la donación *inter vivos*, declaró que lo hacía para que se computara a la "legítima", entonces, el monto de lo donado se imputaba a ésta (Ulp., D.5.2.25 pr.). Esta solución será confirmada por Justiniano (C. 3.28.35.2; año 530). Se establecerá el principio general de que toda liberalidad concedida en vida del testador debe ser colacionada. Indudablemente, juega acá el principio de considerarlas como adelanto de la herencia (Inst., 2.18.6; C.5.20.20). Así, aparte de las propiamente donaciones, lo mismo ocurría si el *pater* había donado *inter vivos* una suma de dinero para que el hijo comprara un empleo imperial o un grado militar (*ad militiam emenda*; Justiniano, C.3.28.30.2). Se ve, por ello, que ciertos cargos resultaban venales.

A su vez, la dote a una hija no era computable para la *quarta pars*, porque ella entraba en el patrimonio de su marido. Pero el emperador Zenón permitió imputar sobre la "legítima" la dote constituida a una hija y la donación *propter nuptias* hecha a un hijo (C. 3.28.29; año 479). Para ello se empleaba una *querella inofficiosi dotis*.

III. La *querella inofficiosi testamenti* se debe interponer contra el heredero testamentario dentro de un plazo de cinco años. Como se trata de una medida extraordinaria, sólo se concede a falta de otra vía disponible —ya del *ius civile* o del *ius praetorium*— (Inst., 2.18.2). El que pide la *querella* no debe contar con otro recurso para obtener la herencia. Así, p. ej., si un hijo emancipado ha sido preterido en el testamento, como tiene derecho a pedir la *b.p. contra tabulas*, no puede iniciar la *querella*. En cambio, si lo tiene si ha sido desheredado (Paulo, D.5.2.23 pr.).

1. Según una constitución del año 258 este plazo no comienza a computarse para los menores de 25 años, sino desde que hayan alcanzado dicha edad (Valeriano y Galiano, C.3.28.16; C.2.40.2).

2. Si el heredero perjudicado ha muerto antes de ejercer la *querella*, no la pueden iniciar sus herederos, pues se interpreta que ha perdonado la ofensa al *officium pietatis*. Pero si la había intentado antes de morir, o hubiese preparado su ejercicio con una intimación al heredero, la *querella* podía ser continuada por sus herederos (Ulp., D.5.2.6.2; Paulo, D.1.17).

3. El que pedía la *querella* no tenía que haber realizado actos que significaran un reconocimiento o aceptación del testamento, puesto que de ser así quedaba excluido de peticionarla. Así, p. ej., si el deshe-

redado compró al heredero instituido cosas de la herencia, sabiendo que lo era; o tomó en arrendamiento campos hereditarios, o le pagó deudas debidas al testador. Se entendía que con ello aceptaba la voluntad expresada en el testamento (Paulo, D.5.2.23.1). Igualmente si aceptaba un legado (Paulo, D.1.3; D.1.32 pr. y 1).

Por supuesto, esto ocurre cuando realiza estos actos en su beneficio, pero no para otro. Así, al tutor puede reclamar el legado establecido para su pupilo (lo cual para él es una obligación), pero ello no obstante no pierde el derecho de iniciar la *querella* por su propia cuenta (*nomine suo*; Inst., 2.18.4).

4. Una circunstancia especial se daba si el testador había dejado a sus hijos legados o donaciones *mortis causa* imputables a la legítima, añadiendo que si fueran inferiores a ésta, quería que la legítima fuese "completada" según "el arbitraje de un varón honrado" (*boni viri arbitratu*).

Según una constitución de Constantino (CTh. 2.19.4, año 361), los legitimarios en este caso debían aceptar la voluntad del testador, no pudiendo pedir la *querella*, pero concediéndoles una *actio ad supplemendum legitimam*, que era una *actio in personam* para pedir dicho suplemento. En caso de perder el juicio, no pierden la liberalidad otorgada, como ocurría con la *querella inofficiosi testamenti*.

IV. A) Si la *querella* prospera el testamento queda rescindido (*ipso iure rescissum est*; Ulp., D.5.2.8.16), de tal modo que se abre la herencia *ab intestato*. De este modo, no sólo se beneficia el actor victorioso que percibe por ello su porción intestada, sino también todos los otros que tienen derecho a la herencia *ab intestato* (Ulp., D.1.6.1).

1. Sin embargo, podía suceder que el testamento se rescindiera sólo en parte. Así, p. ej., si había dos herederos instituidos A y B y el querellante gana contra A y pierde contra B, sólo obtiene la parte de A; Pap., D.5.2.15.2. Curiosamente, acá ocurriría que la herencia sería en parte testada y en parte intestada, en contra de la regla *nemo pro parte testatus et pro parte intestatus* (Ulp., D.2.5.24; D.1.25.1; Gordiano, C. 3.28.13, año 239).

2. En lo que se refiere a las manumisiones, legados, fideicomisos, dación de tutor, etc., contenidos en el testamento, en principio se consideró que habiéndoselo rescindido, todas las cláusulas caían (Ulp., D.5.2.8.16; Paulo, D.1.93).

Pero Justiniano terminó al final admitiendo la idea contraria (Nov. 115.3.15, año 542), de tal modo que todas ellas eran válidas.

3. El que triunfa en la *querella* tiene derecho a pedir en principio la parte que le hubiera correspondido *ab intestato*, pero eventualmente la podrá acrecentar respecto de aquellos otros herederos *ab intestato* que han renunciado o perdido el juicio (Paulo,

D.5.2.23.2; D.1.17). Estos últimos no tienen derecho de invocar para sí el triunfo judicial del querellante (Pap., D.5.2.16).

B) Si el querellante pierde la *querella inofficiosi testamenti*, el testamento queda válido. El actor, en este caso, por haber injuriado la memoria del testador es considerado indigno y pierde todo legado o liberalidad, que queda para el fisco (Ulp., D.5.2.8.14).

1. Un caso especial era el del tutor que pidió la *querella* en nombre de su pupilo desheredado. En caso de perder, por considerarse que estaba obligado a iniciarla, no cabe hablar de indignidad, y si existía un legado en favor del pupilo éste no deja de ser válido (Inst., 2.18.5; Paulo, D.34.9.5.2).

IV. La Novela 115 de Justiniano.

§ 635. El emperador bizantino, recogiendo algunas particularidades del derecho posclásico, establecerá mayores precisiones. Sobre la base de la Novela 18 (año 537) y principalmente de la Novela 115 (año 541) trató de establecer un sistema unificado, que tenía algunas importantes modificaciones en lo que se refiere a la sucesión contra el testamento:

A) Los descendientes y los ascendientes, recíprocamente, deben ser instituidos herederos o desheredados en forma nominativa, expresando la mención de la justa causa de desheredación. Igual sucede con los hermanos germanos y medios hermanos consanguíneos, no los uterinos.

B) Quedan especificadas las causas de ingratitud que el testador debía mencionar expresamente como justa causa de desheredación en el testamento para excluirlo de la legítima (Nov. 115.2-4).

1. Respecto de los descendientes figuraban: el maltrato físico al ascendiente; o la injuria grave; el atentar contra su vida; la acusación criminal salvo delito contra el Príncipe; hacerse el hijo hechicero; tratar de impedir que hiciera testamento; no redimirlo estando cautivo; no recogerlo y sostenerlo estando demente; delatarlo falsamente con perjuicio económico; hacerse el hijo hereje; tener relaciones sexuales con la madrastra; hacerse gladiador o dedicarse al teatro, salvo que el ascendiente fuera de esa profesión; no salirle de fiador al ascendiente preso por deudas, pudiendo hacerlo; hacer la hija vida licenciosa cuando sus padres ofrecen casarla y dotarla y es menor de 25 años (Nov. 115.2).

2. Respecto de los ascendientes: acusar al descendiente de delito que merezca la pena capital, a no ser crimen contra el Príncipe; atentar contra la vida del descendiente; tener relaciones sexuales con la nuera;

prohibirle testar, no recibirlo estando cautivo ni socorrerlo estando demente; hacerse hereje; si uno de los ascendientes atenta contra la vida del otro (Nov.115.4).

3. Respecto de los hermanos: maquinan contra la vida de su hermano; acusarle de algún crimen, causarle una gran pérdida en sus bienes (Nov. 22.47).

C) La cuota de la legítima que antes era la *quarta pars*, queda ahora modificada: Si el testador tiene hasta 4 hijos, la "legítima" es de 1/3, la cual se deberán repartir. Si tenía 5 o más hijos era de 1/2 (Nov.18.1).

1. Esto provocaba alguna circunstancia ilógica. Así, si hay cuatro hijos: A, B, C y D, su legítima era en total de 1/3, por lo que cada uno recibía 1/12 (es decir, 1 dividido por 3 para tener el tercio, y luego por 4 para ver lo que correspondía en particular a cada uno. Pero si eran cinco hijos, por ser la legítima total de la mitad, la legítima de cada uno era de 1/10, es decir, una porción mayor.

2. Curiosamente no se dice nada de la legítima de los ascendientes y hermanos, éstos pospuestos por herederos indignos. Cabría suponer, como lo piensan algunos, que seguía rigiendo la *quarta pars*. Quienes piensan lo contrario se apoyan en el párrafo final del

cap. 1 de la Novela 18, que establece que lo allí resuelto se debe observar respecto de todas las personas que tenían derecho a la antigua porción de la *quarta*.

D) Si hubiesen sido excluidos como herederos, es decir, haber sido preteridos o nominativamente desheredados sin justa causa, éstos tienen la *querella inofficiosi testamenti* para lograr la nulidad del testamento, provocando que se pudiera pedir la parte que le hubiera correspondido *ab intestato*. No es suficiente que le dejen todo o parte de la legítima por legados, fideicomisos u otra liberalidad.

E) Si los herederos legitimarios habían sido nominativamente instituidos herederos, de tal modo que han recibido en el testamento alguna cosa, pero por una porción inferior a la legítima, no pueden actuar por la *querella*, sino que debían ejercer la llamada *actio ad supplendam legitimam*, a los efectos de pedir el complemento faltante (C.3.28.30, año 528).

F) La rescisión del testamento sólo abarca a la institución de heredero. Las otras cláusulas (legados, fideicomisos, manumisiones o daciones de tutor) quedan válidas (Nov.115.3, *in fine*).

CAPÍTULO 5

ADQUISICIÓN DE LA HERENCIA

I. Clases de herederos y formas de aceptación.

§ 636. *Clases de herederos.* Para considerar la aceptación o repudio de la herencia, Gayo (2.152) distingue entre los herederos "necesarios" y los "extraños". Esta diferenciación se basa sustancialmente en que los primeros adquieren la herencia en forma automática cuando fallece el *de cuius*. En cambio, los segundos, llamados también "voluntarios", son libres de aceptar o no la herencia. Para aceptarla deben expresar su voluntad de ser herederos.

A su vez, los herederos necesarios pueden ser: a) el llamado "heredero necesario"; y b) los "herederos suyos y necesarios".

§ 637. I. *Heredero necesario.* Un testador, cuando tenía dudas acerca de la solvencia de su patrimonio, solía instituir heredero a su esclavo propio, al cual le otorgaba al mismo tiempo la libertad en el testamento. Hacía esta institución previendo que si luego de su muerte no se podía pagar las deudas y los acreedores iniciaban su cobro por la *venditio bonorum*, la nota de infamia que acompañaba este procedimiento no recaería ya sobre su memoria, sino sobre el esclavo manumitido (Gayo, 2.154; Inst., 2.19.1).

Es llamado "heredero necesario" (*necessarius heres*) porque inmediatamente después de la muerte del testador, aun contra su propia voluntad, es libre y heredero (Gayo, 2.153; Inst., 2.19.1).

1. Esta forma fue permitida por la ley *Aelia Sentia* (Inst., 1.6.1). En época de Gayo, según Fufidio, Sabino había opinado que la nota de infamia no debía recaer sobre el "heredero necesario", entendiendo que soportaba la venta de los bienes no por su falta, sino por necesidad jurídica. Pero el mismo Gayo, que era de la escuela Sabiniana, se inclina por la solución contraria, que fue la prevaleciente (Gayo, 2.154; CTh.2.19.3).

2. En la época clásica algunos juristas admitían que si el testador había instituido heredero a su esclavo sin haber dicho nada de la manumisión, se debía entender que ésta estaba sobrentendida. Justiniano confirma esta opinión (Inst., 2.14.1; C.6.27.5, año 531).

3. La institución del "heredero necesario" podía ser hecha en primero, segundo o también ulterior grado. Esto se refiere a las sustituciones de herederos en el testamento. De este modo, el testador que dudaba de su solvencia patrimonial, podía darle la oportunidad a otro heredero voluntario establecido en grado anterior; p.ej. un amigo, para que si lo veía conveniente aceptara, pero dándole la oportunidad para que, en caso contrario, no aceptara la herencia, quedando siempre el resguardo del "heredero necesario".

Pero, con sentido equitativo, el pretor le permite al "heredero necesario" la ventaja de conservar los bienes adquiridos por éste después de la muerte de su anterior dueño, ahora patrono. Siendo así, estos bienes no entran en el cómputo de la *venditio bonorum*, aun cuando no se alcance a pagar todas las deudas hereditarias (Gayo, 2.155; Inst., 2.19.1).

4. Se trata de un verdadero caso de "separación de patrimonios" (*separatio bonorum*), de tal modo que los acreedores sólo pueden cobrarse con los bienes del patrimonio del testador, pero el resto de los bienes —que son propios del liberto— deben ser separados y no responden de las deudas del *de cuius* (Ulp., D.42.6.1.18).

§ 638. II. *Herederos suyos y necesarios.* (*sui et necessarii heredes*). Son los hijos e hijas (sanguíneos o adoptivos) —lo mismo que la *uxor in manu*, que se ubica en lugar de hija (*loco filiae*), que estaban sometidos a la *potestas* del *pater* en el momento de su muerte, o lo estarían de haber vivido el *pater* (hijos póstumos).

1. Son denominados "suyos", porque en vida del *pater*, en cierto modo están considerados como propietarios: de aquí que muerto aquél *ab intestato*, son los primeros llamados a sucederlo. Son denominados "necesarios" porque en todos los casos, lo quieran o no, tanto *ab intestato* como por testamento, se hacen herederos (Gayo, 2.157).

2. El nieto y la nieta entran también en esta clase, pero no son herederos directos, sino que es necesario que su padre (el hijo del causante) hubiera premuerto o por otra razón —p.ej., por haber sido emancipado— se haya liberado así de la *patric potes-*

cas (Gayo, 2.156). En igual circunstancia está la *uxor in manu* del hijo, que ocupa el lugar de nieta (*neptis loco*).

A) Los *sui heredes* adquieren su posición de sucesores en forma automática (*ipso iure*) con la muerte del *pater*. No interesa que sean incapaces de hecho (caso del *infans* o del *impuber* o del *furiosus*). Incluso son herederos aun cuando su voluntad sea contraria (Gayo, 2.157).

1. Todo esto se corresponde con el carácter monolítico de la familia tradicional romana. En vida del *pater* eran potencialmente propietarios, y cuando se produce la muerte, esta propiedad se actualiza. Del mismo modo debían responder de las obligaciones, puesto que ellas continuaban en cabeza de los herederos (*ultra vires hereditatis*). El rigor de la *patria potestas*, así como el deber de la *pietas* tornan fundamentada esta posición mientras rigió la familia tradicional romana.

B) Para paliar esta rigorismo intervino el pretor, quizá ya en el último siglo de la República, concediendo al *sui heres* la posibilidad de "abstenerse de la herencia", lo cual tenía el efecto principal de liberarse de la responsabilidad por las deudas cuando éstas eran muchas y superaban el acervo hereditario (Gayo, 2.158; Inst., 2.19.2).

1. Gayo (2.160; 163) la denomina *potestas abstinendi*. También se la llamó *facultas abstinendi* (Gayo, D.29.2.57 pr.) y *ius abstinendi* (Marciano, D.28.5.86.1). En cambio, la expresión *beneficium abstinendi*, generalmente usado por los modernos, sólo aparece una vez (Ulp., D.29.2.71.4).

2. Esto significaba, por un lado, una consideración más benigna para el *sui*, pero por el otro, un deterioro del *officium pietatis*, ya que al abstenerse de la herencia, los acreedores iban a ejercer la *venditio bonorum* contra el ascendente, que arrastraba la tacha de infamia sobre su memoria (Gayo, 2.158).

3. Si se trataba de herencia testamentaria, el *pater* podía contemplar la situación instituyendo al hijo así: "Que sea heredero Publio Mevio, si quisiera serlo". En este caso, la herencia no le pasa *ipso iure*, sino cuando se cumpla esa condición potestativa demostrándose que ha aceptado la herencia (Hermog., D.28.7.12).

C) Este *ius abstinendi* no debía ser pedido al pretor. Los *sui heredes* lo adquieren simplemente por no inmiscuirse en la herencia paterna (Ulp., D.29.2.12), y de este modo evitaban la eventual *venditio bonorum* a su nombre, realizándose ésta a nombre del difunto (Gayo, 3.73; Javol., D.42.5.23). Si los acreedores pretenden iniciar la *venditio bonorum* contra el heredero

que se ha abstenido, el pretor lo protege mediante una *denegatio actionis* (Javol., *ibid.*).

1. El tutor del *impuber* y el curador del *furiosus* podían pedir este beneficio en favor de ellos. Pero a los *impuberes* se les reconoce el *ius abstinendi* aun cuando se hubiesen inmiscuido en los bienes hereditarios (Pomp., D.29.2.11).

2. En el caso del pupilo *impuber* se podía pedir un plazo para deliberar, pero para evitar que se realizaran actos en perjuicio de los acreedores, el pretor lo concedía con el agregado de la cláusula "si pareciera que hay justa causa, prohibiré que mientras tanto se disminuyan los bienes, salvo por conocimiento de la causa al arbitrio de un hombre honrado" (*bonus vir*); Ulp., D.28.8.7 pr.; EP, §§ 209; 210.1).

A los *púberes* también se les podía conceder un *ius deliberandi* (Ulp., D.28.8.8, EP, § 210.2).

§ 639. III. *Herederos extraños*. Los otros herederos no comprendidos en las clases anteriores, son llamados "extraños", por cuanto no estaban sometidos a la *potestas* del causante. También son denominados herederos "voluntarios", porque no adquieren la herencia automáticamente (*ipso iure*), sino que de algún modo tienen que expresar su voluntad de aceptar ser herederos (Gayo, 2.161; Inst., 2.19.3). La aceptación de la herencia es denominada "adición de la herencia" (*aditio hereditatis*: de *ad-ire*, "ir hacia la herencia").

1. Así, entran en esta categoría, en caso de herencia testamentaria, ante todo las personas totalmente extrañas a la familia (así, p.ej., un amigo del testador).

Pero también los hijos que han dejado de estar bajo la *potestas* del testador (así, los emancipados y los dados en adopción).

Igualmente, si la madre hacía testamento instituyendo a sus hijos, éstos son "extraños" puesto que no tiene la *potestas* sobre ellos.

También el esclavo que fue manumitido en vida del testador y hecho libreto, si se lo instituye heredero será "extraño". Adviértase que es un caso distinto del "heredero necesario", puesto que éste es manumitido *post mortem* del testador, precisamente con el testamento.

2. En la herencia *ab intestato* del *ius civile*, el agnado próximo será "extraño", precisamente por no ser *sui heres* y no estar sometido a la *potestas* del causante. Por ello es que deben aceptar la herencia o repudiarla (Gayo, 3.12; Inst., 3.2.7, Ulp., 26.5).

En igual situación están los herederos conforme al *s.c. Tertuliano** (la madre no agnada respecto de sus hijos) y *Oficiano** (los hijos respecto de su madre).

§ 640. En el derecho clásico hubo dos modos de aceptar la herencia por parte de esta clase de herederos: la *pro herede gestio* y la *cretio*.

I. *Pro herede gestio*. En general, la delación de la herencia (*delatio hereditatis*) era ofrecida al heredero extraño. Una vez que estaba en conocimiento de dicho ofrecimiento, desde los primeros tiempos, se consideraba que el heredero aceptaba la herencia si realizaba actos que implicaban el "actuar como heredero" (*gerere pro herede*; de ahí *pro herede gestio*). Así, p.ej., si manifestaba su simple e informal voluntad de adir la herencia, si solicitaba la *bonorum possessio* al pretor, o si se "inmiscuía en los bienes hereditarios vendiendo bienes del acervo hereditario, o reclamando a los deudores hereditarios el pago de sus obligaciones, o cultivaba los campos o los daba en arrendamiento (Gayo, 2.163; 167; Inst., 2.19.7; Ulp., 22.25).

1. En los *Frags.* de Auten (2.44) se dice: "¿Qué es actuar *pro herede*? Es tener la intención de tomar la herencia (*animus capiendi hereditatem*); por ello, si tengo las cosas (hereditarias) o en presencia de amigos digo que quiero ser heredero, se satisface la *aditio* de la herencia".

2. En relación con la *nuda voluntas* de querer ser heredero, que también aparece en Gayo (2.167) y en las *Institutas* de Justiniano (2.19.7), algunos autores lo dan como un caso especial —un tercer modo de hacer la *aditio*—, pero lo más probable es que represente una modalidad de la *pro herede gestio*, y no como una forma de aceptación distinta. Obviamente, esta *nuda voluntas* debe manifestarse de algún modo, con conocimiento de la situación de la herencia (*destinatio animi*; Pap., D. 50.17.76).

II. *Cretio*. La *pro herede gestio* fue la forma más antigua. Pero en principio, el heredero extraño no tiene un plazo para que se decida a aceptarla. El puede deliberar mientras viva si acepta o no la herencia (Gayo, 2.167; Ulp., 22.25; Inst., 2.19.7). Lo único que tiene es un derecho a adquirirla, que en vida puede transmitir a otro por la *in iure cessio hereditatis* (Gayo, 2.35; 3.85; v. *infra*, § 652). Pero si muere antes de haberse decidido, la herencia no pasa a los herederos, ya que la vocación hereditaria le pertenece a él y era personal e intransmisible. A sus herederos (C.6.51.1.5, refiriéndose al derecho antiguo; ver *infra*, § 642, E).

a) Ya en la época republicana, para evitar los lógicos inconvenientes que arrastraba esa dilación, se acostumbró a que el testador le impusiera al instituido la obligación de que si quería ser heredero debía aceptar en forma expresa la herencia dentro de un cierto plazo de deliberación (*spatium deliberandi*; Gayo, 2.164; Ulp., 22.27; 22.25).

La cláusula testamentaria podía ser así: "Ticio, sé heredero, y haz la *cretio* dentro de los 100 días siguientes a aquel en que tengas conocimiento y puedas practicarla. Si no la hicieras, sé desheredado" (Gayo, 2.165; Ulp., 22.27).

Si el heredero instituido decidía aceptarla debía decir las siguientes palabras: "Puesto que Publio Mevio me ha instituido heredero en su testamento, yo he decidido aceptar la herencia" (Gayo, 2.166; Ulp., 22.28). Esta declaración ritual no requería de otras formas, pero resulta obvio que se realizaba en presencia de testigos, ya que de lo contrario el heredero no podría probara.

1. En un principio, el heredero señalaba el plazo de la deliberación para la *cretio*, pero sin contener la cláusula de desheredación. Así, p.ej.: "Ticio, sé heredero y haz la *cretio* dentro de los 100 días próximos". Esto le permitía al heredero tomar esta orden como una invitación, pero no tenía efectos decisivos sobre su actitud: podía hacer la *cretio* o la *pro herede gestio* dentro de los 100 días, o posteriormente. Los viejos juristas republicanos se atuvieron a la literalidad de lo escrito, de tal modo que si siquiera consideraban "condicional" la institución de heredero (la condición sería la *cretio*).

Por ello, para acentuar la voluntad del testador, se acostumbró agregarle la cláusula de desheredación: "Si no haces la *cretio* dentro de los 100 días sé desheredado", con lo cual desaparecía el problema. Cuando no se la intercalaba, se la denominaba *cretio imperfecta* (Ulp., 22.34).

2. ¿Qué pasaba si en una *cretio imperfecta* se reemplazaba la cláusula de desheredación por una sustitución de heredero? Así: "Si no haces la *cretio*, que sea heredero Mevio".

Si el primer heredero instituido no hacía la *cretio* pero realizaba actos que significaran la *pro herede gestio* dentro de los 100 días y Mevio, el sustituto, aceptaba la herencia, se planteaba el problema de que el primer heredero no había cumplido con la orden de la aceptación expresa por la *cretio*, aunque también era cierto que había hecho la *pro herede gestio*.

Los juristas clásicos se inclinaron por aceptar que si el primer heredero instituido había actuado por la *pro herede gestio* antes de que finalizara el plazo de deliberación no quedaba excluido, de tal modo que si luego el sustituto hacía la *cretio*, ambos eran herederos, cada uno por la mitad (Gayo, 2.177-178).

Esta solución fue desestimada por Marco Aurelio, quien atribuyó toda la herencia al heredero instituido en primer término si había hecho la *pro herede gestio* (Ulp., 22.34; era la opinión de Sabino, Gayo, 2.178).

Sin ninguna duda, en cambio, si el primero instituido no hacía la *cretio* ni la *pro herede gestio* dentro de los 100 días, entonces quedaba excluido de la herencia (Gayo, 2.177; Ulp., 22.34).

b) Cuando en un testamento no existía la *cretio*, o tratándose de herederos extraños *ab intestato*, intervenía el pretor permitiendo que los acreedores o los legatarios intimaran al heredero para que explicite si aceptará o no la herencia (*interrogatio an heres sit*). El heredero podía responder aceptándola, o de lo contrario la rechazaba, o pedía un plazo para deliberar (*spatium deliberandi*). El pretor no concedía menos de 100 días (Ulp., D.28.6.1; Paulo, D.4.2). Si el heredero dejaba transcurrir el plazo de deliberación sin decidirse, los acreedores, a falta de otros herederos, a los cuales en segundo o ulterior grado le correspondiera la herencia con los cuales se puede seguir el mismo procedimiento, ante el resultado final negativo o sin resultado, podían iniciar la *venditio bonorum* de la herencia (Marcelo, D.28.8.10; Ulp., D.29.2.69; EP, § 208).

§ 641. *Clases de cretio*. El plazo para deliberar (*spatium deliberandi*) podía ser establecido de dos formas distintas:

a) "Haz la *cretio* dentro de los próximos 100 días contados a partir de la muerte del testador". Esta forma era llamada "*cretio* de término o plazo fijo" (*cretio certorum dierum*) (Gayo, 2.171; Ulp., 22.31).

b) "Haz la *cretio* dentro de los próximos 100 días a contar desde el día que tengas conocimiento y puedas practicarla". Esta forma era llamada "*cretio* vulgar" (*cretio vulgaris*) (Gayo, 2.171; Ulp., 22.31).

Como la primera computaba el plazo de los 100 días de manera automática a partir de la muerte del testador, ello podía ocasionar perjuicio irremediable al heredero cuando por cualquier causa, así no haberse enterado, está impedido de optar. Por ello es mejor y más conveniente usar la *cretio vulgaris* (Gayo, 2.172; Ulp., 22.31-32).

§ 642. *Requisitos de la aceptación de la herencia*. Dada la importancia jurídica de la aceptación de la herencia (*aditio hereditatis*), se debían cumplimentar ciertos requisitos:

A) *Debía ser un acto personal del heredero*.

1. Cuando se instituye heredero a un esclavo ajeno o a un *filius* de otra familia, la aceptación debía contar con la autorización (*iussum*) del *dominus* del esclavo o del *pater* de dicho *filius* (Gayo, 2.187; Ulp., 22.12). El hijo y el esclavo son los que deciden aceptar, pero luego de aceptada, el único heredero es el *dominus* o el *pater*, conforme a las reglas de adquisición familiar.

El impuber púgil puede aceptar con la *auctoritas* de su tutor. Respecto del menor de 25 años se

requiere el consentimiento del curador (C.5.26.1; año 631).

2. No la pueden aceptar los infantes ni los *furiosi*. Por una constitución de Theodosio II y Valentiano III (C.6.30.18) se permite que el padre y el tutor puedan aceptar la herencia en nombre de los infantes.

En cuanto a los *furiosi*, el texto de C.5.70.7.3 revela las controversias existentes en la época clásica, y si bien se deduce que la opinión predominante fue la negativa (Afric., D.29.2.47; Marcelo, D.4.63), Justiniano admite la licencia —y la necesidad— del curador de tomar la *bonorum possessio*.

B) *El aceptante de la herencia debía tener la capacidad para heredar*.

1. El heredero debe tener la *testamenti factio passiva* en el momento de la confección del testamento para que la institución exista, así como en el de la delación de la herencia (muerte del testador) y conservarla sin interrupción hasta la aceptación de la herencia (Inst., 2.19.4).

2. La *t.f. passiva* la tienen el mudo, el póstumo, el infante, el *filius* y el esclavo ajeno, porque aunque no puedan hacer testamento, pueden adquirir por testamento, ya para ellos o para otro (Inst., 2.19.4).

C) *La aceptación debe ser total por las cuotas asignadas*.

1. Si el heredero era único respecto de toda la herencia, no puede adirla en parte, dividiéndola (Paulo, D.29.2.1). Si la aceptara *pro parte*, se considera que la ha aceptado en forma total (Ulp., D.4.10).

Si fue instituido por varias partes de la herencia, no puede repudiar algunas y aceptar otras (Ulp., D.4.2; Paulo, D.4.80 pr. y 1; C.6.30.20).

2. Además, la aceptación debe ser pura y simple, es decir, sin supeditarla a una condición o a un plazo (Afric., D.29.2.51.2; Pap., D.50.17.77). Ello obedece a que quien acepta ser heredero debe siempre continuar siendo tal (regla *semel heres, semper heres*).

D) *La aceptación de la herencia es irrevocable*.

1. Mientras dure el *spatium deliberandi* el heredero instituido puede aceptar la herencia o repudiarla. Pero, mientras está vigente dicho plazo si ha decidido no aceptar la herencia, puede sin embargo arrepentirse y cambiar de opinión aceptándola. En cambio, si deja transcurrir el plazo de deliberación sin decidir nada o la ha repudiado sin arrepentirse antes de cumplido el plazo queda excluido (Gayo, 2.168; Ulp., 22.30).

2. La repudiación no exige ninguna forma solemne. Puede hacerlo en forma expresa, o en forma tácita mediante cualquier indicio que demuestre su voluntad de no aceptar (Paulo, D.29.2.95). Igualmente,

como lo hemos dicho, dejando pasar el plazo de deliberación sin tomar decisión alguna.

3. Sin embargo, había algunas excepciones:

a) El menor de 25 años puede arrepentirse cuando ha aceptado imprudentemente una herencia demasiado onerosa (Gayo, 2.162; Inst., 2.19.5).

b) Por una decisión de Adriano se permitió el mismo derecho a un heredero mayor de 25 años, ya que después de haberse aceptado la herencia, descubrió la existencia de una cuantiosa deuda que estaba oculta al tiempo de la aceptación (Gayo, 2.163; Inst., 2.19.6).

c) La repudiación de la herencia es también irrevocable. Si alguien hubiera renunciado engañado en forma dolosa, se le concede el *actio de dolo* (Ulp., D.4.3.9.1), y si se hubiera ejercido violencia, la *actio quod metus causa* (Paulo, D.4.2.21.6). El pretor otorga también la *in integrum restitutio* al menor de 25 años que resultara engañado al repudiar la herencia (Ulp., D.4.4.22).

d) Gordiano otorgó a los soldados ("conocen mejor las armas que los iura"; Inst., 2.19.6; C.6.30.22 pr.), el beneficio de permittirles que sólo debían responder de las deudas hasta el monto de los bienes hereditarios. Justiniano, estableciendo la "aceptación con beneficio de inventario", extenderá este derecho para todos los herederos.

E) *La decisión de aceptar la herencia no pasa a los herederos*.

1. Si el heredero extraño o voluntario fallece antes de producir la adición de la herencia, esta decisión no se trasmite a sus herederos (C.6.30.7; C.6.51.1.5).

2. Pero existirán excepciones:

a) Cuando el heredero no pudo aceptar la herencia por causas justificadas ajenas a su voluntad, el pretor concedió a sus herederos la *bonorum possessio*, recurriéndose al procedimiento de la *in integrum restitutio* (rescripto de Antonino Pio; Pap., D.29.2.86 pr.).

b) Por una constitución de Theodosio y Valentiano, se le concede al *pater* el derecho de aceptar la herencia dejada a su hijo infans, aun cuando éste hubiese fallecido antes de haberla aceptado su ascendiente por omisión suya (C.6.30.18; año 426).

c) Por otra constitución de estos mismos emperadores, cuando el heredero constituido por un ascendiente muere antes de la apertura del testamento, se concede la facultad de aceptar a los herederos del instituido (*transmissio Theodosiana*; C.6.52; año 450).

§ 643. *La aceptación de la herencia en Justiniano*.

En la época de Justiniano se producen algunas reformas:

a) Eliminando toda mención de la *cretio*, se habla solamente de la "aceptación de la heren-

cia" (*aditio hereditatis*), la cual se puede hacer ya por una manifestación expresa o por la *pro herede gestio* (Inst., 2.19.7).

b) Establece la posibilidad de que todo heredero pueda aceptar la herencia con el "beneficio de inventario" (v. *infra*, § 649), de tal modo que en este caso, la responsabilidad por las deudas hereditarias sólo es atendida hasta lo que alcanzan los bienes de la herencia excluyendo a los bienes propios del heredero (C.6.30.22, año 531). Por ello dice que atendiendo a la posibilidad de dicho beneficio "ya no es necesario el auxilio de ninguna deliberación" (Inst., 2.19.6, *in fine*).

c) Sin embargo, no suprime por ello el *spatium deliberandi*. Les da a elegir a los herederos: (i) hacer el inventario, por lo que estaban ya aceptando la herencia; o (ii) regirse por el anterior derecho pidiendo un tiempo de deliberación. Para ello tenían que petitionarlo ante el magistrado dentro de los 9 meses, o ante el emperador, dentro del año (C.6.30.22.13).

Dentro del plazo concedido debían o aceptar la herencia o repudiarla, pero en caso de aceptación no gozan del "beneficio de inventario", debiendo responder de las deudas no sólo con los bienes hereditarios, sino también con los propios, según la regla general del anterior *ius civile*. Si dejaba pasar el plazo de deliberación sin decidirse, se entiende que la ha aceptado, debiendo responder en forma amplia respecto de los acreedores (C.6.30.22.14).

d) Justiniano, prácticamente derogando la regla anterior de que el derecho de aceptación era intransmisible, decidió que muerto el heredero sin haber aceptado o repudiado la herencia, podían ejercer este derecho los sucesores del fallecido, siempre que éste hubiese muerto antes de la expiración del año desde la delación de la herencia (C.6.30.19, año 529).

II. Situación del heredero después de la aceptación de la herencia.

§ 644. *Principios generales*. Como hemos visto, los "herederos necesarios" adquieren la herencia *ipso iure*, mientras que los "herederos extraños" lo hacen producida la adición de la herencia. Pero los efectos serán los mismos para ambos: el heredero sustituye al causante, convirtiéndose en un continuador de su persona. De este modo, se producen las consecuencias generales siguientes:

A) En el aspecto patrimonial activo, todos los bienes hereditarios, así como los créditos que eran en favor del *de cuius*, pasan ahora al heredero. De este modo estos bienes pasan a formar una sola masa con los bienes del heren-

dero. La única excepción está dada respecto de los derechos que son "personales" y que se extinguen con la muerte del causante, como p.ej. el usufructo o el uso.

1. La sucesión se produce respecto de los derechos, pero no en cuanto a las situaciones de hecho, como, p.ej., la posesión (Scev.-Ulp., D.47.4.1.15). Esto significa que el heredero para llamarse poseedor debía efectivamente entrar en la posesión de la cosa. Sin embargo, a los efectos de la *usucapio*, se puede sumar la posesión del causante a la del heredero (v. *supra*, § 240, E, 2).

2. Si hay más de un heredero, mientras no suceda la división de la herencia, las cosas son mantenidas en comunidad. Cada heredero tiene una cuota de participación conforme a la porción en que ha sido instituido. Así, hay dos herederos: A por 1/3 y B por 2/3. Si en la herencia hay un predio, él está en condominio, de tal modo que a A le corresponde una cuotaparte de 1/3 y a B otra de 2/3.

3. El estado de indivisión cesa por la partición de la herencia, que puede ser privada y amigable o recurriendo al magistrado por la *actio familiae erciscundae*.

B) En cuanto al aspecto patrimonial pasivo, el heredero adquiere la responsabilidad por todas las deudas del causante, no solamente con los bienes hereditarios sino con los suyos propios. Esto se enuncia con el principio *ultra vires hereditatis*. Como consecuencia de él se produce la confusión de ambos patrimonios, y los acreedores que eran del causante deberán concurrir con los del heredero.

1. En caso de ser varios los herederos, la responsabilidad por las deudas hereditarias le corresponde a todos ellos.

Si las obligaciones son divisibles, la responsabilidad es según la cuota hereditaria. Así, una obligación de 90, siendo los herederos A por 1/3 y B por 2/3, A deberá pagar 30 y B 60. La regla ya existente en las XII Tablas (5.9) era que las deudas se dividen *ipso iure* (*nomina ipso iure divisa sunt, nomen* = "asiento en el *codex del pater*").

Si la obligación era indivisible o solidaria, cada uno de los herederos debe el total (*in solidum*).

I. Acrecentamiento entre coherederos.

§ 645. Cuando existen dos o más herederos y uno de los llamados a la herencia no quiere o no puede ser heredero, su cuota pasará a acrecentar la porción del otro u otros herederos. A esto se lo llama "acrecentar" (*ius adscrescendi*).

La idea romana es que la herencia le es deferida *in solidum* a todos los herederos, de tal

modo que la aceptación de uno de ellos se refiere a todo el patrimonio hereditario, si bien concurriendo con otro u otros hacen "concurso de partes" (*partes concursu fiunt*). Pero ante la falta de uno de ellos, el otro u otros herederos pasan a acrecer la porción que le correspondía a aquél. Esto se opera de manera automática (*ipso iure*), no necesitando que se haga una adición por parte del o de los beneficiados. Más aún, se produce hasta contra su voluntad, ya que éstos no pueden rehusarse (Gayo, D.29.2.53.1).

A) En la herencia *ab intestato* el acrecentamiento tiene lugar siempre. Así, p.ej., el *pater* ha dejado tres hijos: A, B y C. Si C muere sin dejar herederos, la parte que le correspondía acrecentará su parte, de tal modo que en lugar de tres partes, cada uno de ellos tendrá la mitad de la herencia.

1. Supongamos ahora que no ha dejado *sui heredes*. La herencia le corresponde al agnado próximo. Si, p.ej., hay dos A y B en el mismo grado, cada uno con derecho a la mitad. Si B no acepta la herencia, sino que renuncia a ella, entonces todo va a A (Ulp., 26.5).

2. Incluso si A había aceptado la herencia y hubiese muerto el tiempo que B había repudiado la herencia, el acrecentamiento se produce lo mismo, en favor de los herederos de A (Marciano, D.38.16.9).

B) En la herencia testamentaria, en caso de ser varios los herederos A, B y C llamados al todo, sin asignación distinta de partes, en caso de que uno de ellos C no hubiera aceptado la herencia o hubiera premuerto, la herencia se reparte por mitades entre A y B.

La herencia se debe repartir entre todos los herederos instituidos por el testador. Acá el *ius adscrescendi* se basa en la aplicación de la regla *Nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest*. Por ello, basta que exista un heredero testamentario para que éste acrezca las partes de los que alcanzaron a serlo. Tal como lo habíamos dicho, la aceptación de la herencia es *in solidum*, pudiendo ocurrir el concurso cuando existan otros coherederos; obviamente si éstos faltan, se produce el acrecentamiento. Así lo dice la regla fundamental establecida por Celso (D.38.20): "Instituir herederos en forma conjunta (*coniunctim*) o legar en forma conjunta significa esto: Dar a cada uno toda la herencia o todos los legados, aunque las partes se hacen por los que concurren".

Sin embargo, hay que atender a la forma como el testador ha efectuado las instituciones de herederos, haciéndola en forma separada (*disiunctim*), o formando grupos (*coniunctim*). Cuando ocurre lo primero, cada uno acrece la parte del heredero que falta en forma proporcional a

su cuota. Cuando ocurre lo segundo, se da preferencia a los herederos del mismo grupo.

1. Según lo explica Paulo en un texto didáctico (D.50.16.142), pero que resulta interesante para analizar los casos, la *coniunctio* puede ser de tres clases distintas:

a) *coniunctio re et verbis* (en la cosa y en las fórmulas). Así: "Que sean herederos Ticio y Mevio por mitades". Acá no hay problema de interpretación, ya que a ambos les corresponde la herencia por mitades. Si uno de ellos no acepta la herencia, el acrecimiento se realiza en favor del otro, que se queda con el todo.

b) *coniunctio verbis tantum* (sólo en las palabras de la institución de heredero). Así: "Que sea heredero Ticio; que Gayo y Mevio sean herederos por partes iguales". Se entendía acá que la voluntad del testador era establecer heredero por un lado a Ticio, y por el otro, conformar un grupo con Gayo y Mevio. Por tanto, a Ticio le corresponde 1/2 y la otra mitad le correspondía 1/4 a Gayo y 1/4 a Mevio.

Si Gayo no aceptaba, el que acrecía era Mevio si es que aceptó la herencia. Al contrario, si Ticio es el que no acepta, Gayo y Mevio acrecen su parte, de tal modo que se quedan con toda la herencia por mitades para cada uno.

c) *coniunctio re tantum* (solamente en la cosa). Así: "Que Ticio sea heredero de la mitad; que Seyo sea heredero por la parte en que instituí a Ticio; que Sempronio sea heredero por la mitad".

Juliano decía que se puede, por un lado, interpretar que se han hecho tres mitades, lo cual sería ilógico. Pero, por el otro, cabe pensar que lo correcto es pensar que Sempronio es heredero por 1/2, mientras que Ticio y Seyo lo son por la otra mitad (1/4 a cada uno). En efecto, ambos han sido unidos de manera más íntima, formando un mismo grupo.

Si Ticio no acepta la herencia, el que acrece es Seyo. Al contrario, si el que no acepta es Sempronio, el acrecimiento beneficia a Ticio y a Seyo, que se deben repartir la herencia por mitades.

2. El régimen del acrecentamiento se vio complicado con las leyes caducarias de Augusto, por cuanto alguno de los herederos podía ver que su parte se tornaba "caduca". En principio, quedaban sustraídas al acrecentamiento de los otros herederos, yendo a parar al fisco.

Pero se admitió como "premio" que dichas partes caducas fueran ofrecidas a los herederos, y en su defecto a los legatarios, siempre y cuando que cumplan los requisitos de las leyes caducarias. Siendo así, el acrecentamiento es voluntario, es decir, no se produce *ipso iure* sino que hay que pedirlo pudiendo reivindicar la parte (const. de Caracalla, Ulp., 17.2). Este "premio" conllevaba la obligación de cumplir los legados y fideicomisos correspondientes a la parte caduca (*cum honore*).

Para ciertos casos, se suele mantener el "acrecentamiento" tradicional —*vetum ius*—; así en favor de los descendientes o parientes dentro del tercer grado que hubiesen sido instituidos en el testamento (Ulp., 17.3; cit. C.6.51.1 pr.).

Justiniano derogó el régimen de la caducidad, pero estableciendo que el acrecentamiento debía en ciertos casos cumplir las cargas testamentarias (C.6.51.1. 4 y 9; *infra*, § 662, C, 1).

3. Hay que recordar que en el derecho antiguo, el acrecentamiento se realizaba *sine honore*, es decir que el heredero beneficiado no está obligado a cumplir las cargas, legados y fideicomisos que gravaban al heredero que no aceptaba la herencia.

Pero esto se modificó por una decisión de Septimio Severo (Ulp., D. 31.6.1.1, recordado en C.6.51.1.9).

II. Remedios para la responsabilidad por deudas.

§ 646. Tal como lo habíamos visto (*supra*, § 644, B), desde que se adquiere la herencia, ya fuere *ipso iure* (caso de los herederos "necesarios"), ya a partir de la aceptación de la herencia (caso de los herederos "extraños" o "voluntarios"), el patrimonio del causante se confunde con el del heredero, de tal modo que éste deberá responder por las obligaciones del *de cuius* y obviamente por las suyas.

Cuando se estaba en presencia de una herencia cuyo pasivo superaba al activo, se habla de "herencia dañosa" (*hereditas damnosa*; Jul., D.17.1.32; Gayo, D.29.2.57.1). Según ya vimos, si se trata de un *suius heres* que sospecha esa situación económica, puede recurrir al *beneficium abstinenti*, de tal modo que en caso de no existir otro heredero o *bonorum possessor* que pida la herencia, los acreedores deberán dirigir la *venditio bonorum* contra los bienes hereditarios. También, en el caso del "heredero necesario", el esclavo manumitido por el testamento podía pedir la *separatio bonorum* de los bienes hereditarios respecto de los propios adquiridos por él después del deceso del *de cuius*.

Pero en el caso de un heredero "extraño", frente a tal situación, para evitar o limitar esa responsabilidad, le cabía:

- a) no aceptar la herencia o repudiarla;
- b) pactar con los acreedores, antes de la aceptación de la herencia, que no la aceptaría salvo una reducción de las deudas (Ulp., D.2.14.7.17; v. D.14.8.10);
- c) pedir a los acreedores que para aceptar la herencia, éstos le debían dar un mandato de hacerlo. Con ello el heredero se protege, ya que al ser mandatario cuenta con la *actio mandati contraria* contra todo perjuicio que pudiera su-

frir por la responsabilidad de las deudas del testador (Ulp., D.17.1.32).

§ 647. Pero una vez aceptada la herencia, la situación de heredero es irrevocable, y no puede arrepentirse (principio: *semel heres, semper heres*). Al formarse una sola masa patrimonial (la del causante y la del heredero), esto podía aportar serias consecuencias económicas, tanto para los acreedores como para el heredero. Así, podrían presentarse estos dos supuestos:

A) Los acreedores del causante que están en la expectativa de cobrar sus créditos, por cuanto habían tenido negocios con una persona solvente; que había dejado una herencia que contaba con bienes suficientes, podían ver burladas sus esperanzas de cobro si el heredero, en cambio, contaba con un patrimonio cargado de deudas, ya que iban a formar una sola masa con los acreedores de dicho heredero.

B) Frente a una "herencia dañosa", el heredero debía responder de las deudas del causante más allá del monto del activo de la herencia (*ultra vires hereditatis*), y ello lo debía hacer con su propio patrimonio.

Para solucionar más equitativamente ambos problemas, se establecieron dos beneficios:

§ 648. I. *Beneficio de separación de patrimonios* (*beneficium separationis bonorum*). El pretor concedió a los acreedores del *de cuius* el derecho de separar los bienes de la herencia de los bienes propios del heredero. De este modo, dichos acreedores podían cobrarse con todos los bienes de la herencia, mientras que los acreedores del heredero sólo lo podían hacer luego de haber intentado cobrarse los acreedores del causante con los bienes hereditarios. Los acreedores del heredero se beneficiaban si quedaba algún excedente de la herencia, pudiendo ejecutar sus créditos con este sobrante y, obviamente, con los bienes propios del heredero (EP, § 223; D.42.6).

1. Los únicos que podían pedir la *separatio bonorum* eran los acreedores del causante. Sólo beneficiaba a quienes la hubiesen pedido; de lo contrario quedaban equiparados a los acreedores del heredero (Ulp., D.42.6.1.16). Estos últimos nunca la pudieron pedir, ya que habiendo celebrado negocios con el heredero han aceptado por adelantado las consecuencias de sus actos (Ulp., D.42.1.2).

2. Tenían el plazo de cinco años, a partir de la aceptación de la herencia, para pedirla, siempre y cuando vigente dicho plazo no se haya producido una confusión de ambos patrimonios (Ulp., D.42.13.13).

Una vez pedida, si se habían equivocado sobre la insolvencia del heredero, no podían dejar atrás la *separatio bonorum*, salvo probando una causa de error excusable (Ulp., D.42.17).

3. Se podía presentar el caso de que los acreedores del *de cuius* han obtenido la separación de patrimonios. Se han querido cobrar con los bienes hereditarios, pero agotados éstos ha quedado algún saldo. Mientras tanto, el heredero que aparecía como insolvente (por eso se pidió la *separatio bonorum*), resulta que ha obtenido ingresos inesperados y ha podido pagar todas sus deudas propias. ¿Podían ir ahora contra los bienes del heredero para cobrar los saldos impagos?

La cuestión divide a los juristas. Por un lado, Papiniano (D.42.6.3.2) lo permite siempre y cuando se haya satisfecho a todos los acreedores propios del heredero. En cambio, Paulo y Ulpiano sostenían que no, entendiendo que al rechazar la persona del heredero al pedir la *s.b.*, optaron por querer cobrarse únicamente con los bienes de la herencia (Paulo, D.42.5; Ulp., D.42.1.17, quien habla de que ésta era la solución generalmente admitida).

4. En cambio, como habíamos dicho, sobrando algo de la herencia luego de haberse cobrado todos los acreedores que habían pedido la *s.b.*, los acreedores personales del heredero podían cobrarse con ellos (Paulo, D.42.6.5).

5. El derecho a pedir la *separatio bonorum* se extendió a los legatarios, pero éstos deben esperar que primero se cobren los acreedores que pidieron la separación de patrimonios (Juliano, D.42.6 pr.).

§ 649. II. *Beneficio de inventario* (*Beneficium inventarii*). Justiniano, por una constitución del año 531 (C.6.30.22), creó este beneficio para todos los herederos. El heredero que "acepta la herencia con beneficio de inventario" no queda obligado a pagar a los acreedores del causante más allá del monto de los bienes hereditarios (v. *supra*, § 643, b y c).

1. Como se ve, se trata de una excepción al principio de la responsabilidad *ultra vires hereditatis*. Al contrario, se puede decir que conlleva el principio de la responsabilidad *intra vires hereditatis* (hasta el monto de los bienes hereditarios).

2. Para poder tener este beneficio, el heredero debía cumplir el siguiente procedimiento:

a) Debe aceptar la herencia, pero dentro de los 30 días de la delación de ella, debe comenzar a hacer un inventario ante un escribano (*tabularius*).

b) Dicho inventario debía estar terminado en un término de 60 días; se podía extender a un año si los bienes estaban en lugares distintos.

c) Debía ser hecho en presencia de los legatarios, fideicomisarios y acreedores, o si ellos estuvieran ausentes, en presencia de tres testigos que posean bienes y residan en el mismo lugar.

d) El heredero debía poner su firma (*scriptio*), declarando que no ha tomado ningún bien de la sucesión. Si se probaba lo contrario, es condenado a devolver el *duplum* (C.6.30.22.2 y 10).

3. Luego pagaba a los acreedores a medida que éstos se presentaban. Los acreedores hipotecarios eran preferidos a los quirografarios, y éstos a los legatarios (C.42.22.5-8). Para poder pagar, el heredero podía vender privadamente los bienes hereditarios.

Si sobraba algo, después del pago de las deudas y de los legados, quedaba para el heredero.

4. Si no se hacía el inventario en término, o se había solicitado el *spatium deliberandi*, la herencia quedaba sujeta a las reglas generales del *ius civile* anterior, es decir que se responde en forma plena (*ultra vires hereditatis*); v. *supra*, § 643, c.

III. Casos de herencia no adquirida.

A) Herencia yacente.

§ 650. Como lo hemos visto, en el caso de los herederos "extraños" podía mediar un plazo entre la delación de la herencia y su aceptación. Igualmente, aun tratándose de un *suus heres*, si había sido instituido bajo condición, hasta que ésta se cumpliera, o tratándose de un heredero póstumo, hasta que se produjera su nacimiento. En el lapso intermedio la herencia está en una situación muy particular. Se habla entonces de "herencia yacente" (*hereditas yacens*; Ulp., D.36.4.5.20; D.43.24.13.5). Es una herencia que "no tiene aún heredero, pero espera tenerlo". Por ello no hay que confundirla con la "herencia vacante", situación que se produce cuando, p.ej., nadie ha aceptado la herencia, pues en este supuesto la herencia "no tiene heredero ni espera tenerlo".

I. Ya desde la época republicana se consideraba que las cosas pertenecientes a la herencia son *res nullius* (Gayo, D.1.8.1 pr.; Ulp., D.43.23.13; *res sine domino*, Ulp., D.15.1.3 pr.; D.38.9.1 pr.).

De este modo, se daba la situación curiosa de que el esclavo que perteneció al causante, continúa *in potestate*, pero *sine dominus*. Los créditos en favor de la herencia, lo mismo que las deudas de ésta, continuaban subsistentes, pero careciendo de titular concreto, activo o pasivo, no pueden ser ejercidas. Cuando el heredero acepta la herencia, sólo entonces adquiere la titularidad del dominio y de las obligaciones, sin retrotraérsela al momento de la muerte del causante. Como consecuencia ineludible, siendo *res nullius*, si alguien se apoderaba de alguna cosa no cometía *furtum*.

En la época clásica, los juristas, siempre renuentes a establecer doctrinas generales, trataron de resolver los problemas concretos en cada caso particular. Pero en líneas generales continuaron admitiendo la *hereditas yacens* como la situación de una herencia *sine titular*, tanto respecto de las cosas como de los créditos o deudas.

1. Entre estos criterios particulares podemos mencionar los siguientes:

a) Cassio, respecto de si el esclavo hereditario podía estipular en favor de la herencia, estableció que podía hacerlo, argumentando que cuando aceptara el heredero la herencia se retrotraía al momento de la muerte del causante (Gayo, D.45.3.28.4).

b) Sobre el mismo caso, hablando de que el esclavo podía estipular en favor de la herencia o recibir cosas por tradición, se dijo que la persona del difunto, no la del heredero, es sostenida por la herencia (Jul.-Ulp., D.41.1.33.2 y 4).

Pero también el criterio opuesto, esto es, que en el intervalo es la persona del heredero la que es sostenida por la herencia (Pomp., D.46.2.24); o atribuyendo los derechos y obligaciones a la herencia misma (Paulo, D.35.2.1.1; Hermog., D.41.1.61 pr.).

Estos distintos criterios significan que el patrimonio hereditario se halla sometido al derecho de sucesión, y por ello el causante o el heredero actúan por ella, mientras el esclavo subsiste *in potestate*, aunque sin dueño.

2. Uno de los problemas principales era la carencia de ejercer la *actio furti* respecto de cosas sustraídas de la *hereditas yacens*.

Sólo se la permite en ciertos casos especiales: así, si antes de la aceptación de la herencia, el heredero era poseedor de la cosa (Gayo, 3.201); o si un tercero era poseedor a nombre de la herencia: así, si el causante había dado a otro una cosa en prenda, o aun siendo tenedor, la había dado en comodato; o también en usufructo (Marcelo, D.47.2.68; Scæv., D.42.69).

Los juristas clásicos no pudieron restringir la ausencia del *furtum*, por cuanto además estaba implicada la *usucapio pro herede*. Lo que se hizo fue sancionar como delito el despojo de la herencia, mediante la sanción por Marco Aurelio del *crimen expilatae hereditatis* (Marciano, D.47.19.1; C.9.32), aunque se recalca que pese a ello, no se concede la *actio furti* en el caso de la "herencia yacente" (Ulp., D.47.19.2.1; Paulo, D.42.6).

3. En otros casos —así, por daños injustos sufridos por un esclavo hereditario—, Celso otorga la *actio legis Aquiliae* al heredero (D.9.2.13.2); o si fue arrebatada una cosa con violencia o con clandestinidad, se le concede al heredero el interdicto respectivo (Ulp., D.43.24.13.5).

4. Mientras estuviera yacente la herencia, el pretor podía nombrar un curador de los bienes (Ulp., D.42.4.8; Hermog., D.50.4.1.4).

II. En la época posclásica, en el Derecho vulgar, la herencia fue considerada como una persona jurídica. Se dijo que la herencia hace las veces de persona (*hereditas personae vice fungitur*; Florentino, D.46.1.22 ítp.) o que la herencia obtiene el lugar de dueña (*hereditas dominae locum obtinet*; Ulp., D.43.24.13.5 ítp.).

Paulo, D.41.3.15 pr.). Esta idea, que fue la aceptada por Justiniano interpolando los textos respectivos, parece simplificar las cosas. Pero en realidad las complica, por cuanto el heredero no sucede directamente al causante, sino que lo hace por intermedio de la *hereditas yacens*, considerada como persona.

B) *Usucapio pro herede*.

§ 651. Según nos expresa Gayo (2.54), desde los tiempos antiguos se consideró que las herencias mismas podían ser usucapidas mediante la posesión de los bienes hereditarios. Se daba entonces el caso de la *usucapio pro herede* (usucapio a título de heredero). De este modo, si alguien, aun de mala fe, poseía los bienes hereditarios durante el plazo de un año, adquiría la herencia.

Esta extraña institución, reprochable por cuanto se le concede al poseedor de mala fe, era aprobada por los antiguos, para que los herederos "extraños" aceptaran prontamente la herencia, fundada en dos motivos. Primero, para que fuese continuado el culto doméstico (*sacra privata*), sumamente observado en esos tiempos. Y segundo, para que los acreedores tuvieran alguien a quien dirigirse para recobrar sus créditos (Gayo, 2.55).

El plazo de la *usucapio pro herede* fue de un año, observando lo que decía la ley de las XII Tablas, que imponían el de dos años para los inmuebles y el de un año "para las otras cosas". Dado que la *hereditas* no es un "inmueble" (a pesar de que dentro de ella puedan haber fundos), se interpretó que entraba entre "las otras cosas" (Gayo, 2.54).

En la época clásica solamente existía una *usucapio pro herede* de las cosas individuales, siempre y cuando éstas fueran susceptibles de ser usucapidas. Y aunque se tratase de un inmueble, continuando el criterio antiguo, el plazo siguió siendo de un año (Gayo, 2.53). Podía ser usada frente a un heredero "extraño", pero no respecto de un *suus heres* (que adquiere la herencia automáticamente —*ipso iure*—; Gayo, 2.58).

Esta *usucapio pro herede* —que es llamada *lucrative*, ya que uno se enriquece a sabiendas de que la cosa es ajena (Gayo, 2.56)— va a sufrir limitaciones ya en el propio período clásico. Así, por un s.c. de Adriano se revocan estas usucapiones, cuando son de mala fe y sin *iusta causa*. Y así, el heredero puede pedir la herencia contra aquel que haya usucapido la cosa, como si no mediase *usucapio* (Gayo, 2.57).

Y luego Marco Aurelio castigó el *crimen expilatae hereditatis* (crimen de despojo de la herencia; Marciano, D.47.19.11) cometido por aquel que a sabiendas posee una herencia en forma

dolosa, a falta de la *actio furti*, por el despojo sufrido.

Justiniano suprime la usucapio de mala fe de las cosas hereditarias (*lucrative usucapio pro herede*), admitiéndola sólo en caso de buena fe: así, para el heredero verdadero que creyese erróneamente que una cosa era de la herencia (Pomp., D.41.5.3) o para el heredero aparente, es decir, aquel que cree de buena fe que es heredero, sin realmente serlo (Jul., D.41.3.33.1).

IV. Trasmisión de la herencia.

§ 652. La vocación hereditaria tiene un carácter personal, ya que se hace siempre en favor de determinadas personas. Por ello es que si el llamado a ser heredero no ha adquirido o aceptado la herencia, ésta resulta intransmisible para sus herederos (v. *supra*, § 642, B).

Sin embargo, existió la posibilidad de transmitir la herencia a otro mediante la *in iure cessio hereditatis*. Esta institución, con muchos puntos oscuros, nos es conocida por Gayo (2.35-37 = 3.85-87) y Ulpiano (19.12-15).

1. Parece que su existencia se debió a motivos análogos a los de la *usucapio pro herede*, es decir, para asegurar la continuidad de los *sacra privata* y el interés patrimonial de los terceros cuando ciertos herederos no llegaban a ser tales.

2. No tiene nada que ver con la llamada *venditio hereditatis* (D.18.4), que es la venta en bloque de los bienes hereditarios, pero no la vocación hereditaria ni la calidad de heredero.

A) Si se trata de la herencia *ab intestato*, los agnados podían hacer la *in iure cessio hereditatis* ante el magistrado, antes de la aceptación de ella. Recordemos que siendo "extraños" debían hacer la *pro herede gestio* o aceptarla por la *cretio*. Aquel a quien se cedió la herencia, pasa ahora a ser el heredero (Gayo, 2.35; 3.85; Ulp., 19.12-15).

Pero si ceden la herencia después de haberla aceptado, el cedente permanece como heredero (regla: *semel heres semper heres*). Esto debería significar que la cesión es nula. Sin embargo, produce ciertos efectos: a) las deudas hereditarias continúan vigentes, pudiendo los acreedores actuar contra el heredero cedente; b) en cambio, no ocurre lo mismo con los créditos que se extinguen, de tal modo que los deudores se benefician al no tener que satisfacerlos; c) a su vez, las cosas corporales de la herencia pasan al cesionario como si le fueran cedidas *in iure* una por una (Gayo, 2.35; 3.85; Ulp., 19.12-15).

1. Los proculeyanos entendían que también los herederos "suos y necesarios" podían hacer la *in*

iure cessio, después de aceptada la herencia, al parecer haciendo una interpretación extensiva del régimen aplicable a los herederos testamentarios. Los sabinianos estaban por la negativa (Gayo, 2.37; 3.87).

B) En cambio, los herederos testamentarios no pueden hacer la cesión de la herencia antes de haberla aceptado, ya que el acto es nulo. Si la hicieran con posterioridad, se producen los mismos efectos que respecto de los herederos legítimos *ab intestato* (Gayo, 2.36; 3.86; Ulp., 19.13-15).

La cesión de la herencia desaparece en el siglo III d.C. con el desuso de la *in iure cessio*. Fue suplantada por la *venditio hereditatis*, es decir, el traspaso al comprador de los bienes y cargas de la herencia.

1. En el caso de la *venditio hereditatis*, el cedente no deja de ser heredero. Sólo se compromete a traspasar al comprador las cosas corporales por la *traditio*. En cuanto a los créditos y las deudas, se celebraban estipulaciones recíprocas, llamadas *emptae et venditae hereditatis*, semejantes a las que veremos funcionar en los fideicomisos, por medio de las cuales se ceden los créditos obligándose el cedente a no reclamarlos y las deudas por las cuales responderá el cesionario. Antonino Pio dará al comprador acciones útiles contra los deudores de la sucesión (Ulp., D.21.1.16 pr.).

V. Protección jurídica del heredero.

§ 653. En principio, el heredero puede ejercer todas las acciones usuales relativas a su situación jurídica. Así, si una cosa de la herencia está en poder de otro, puede actuar por la *rei vindicatio*. Si el deudor de una obligación hereditaria no la satisface, cuenta con la acción creditoria correspondiente. Igualmente, el *bonorum possessor* contará con acciones similares, ejercidas como *actiones utiles*.

Pero, aparte de ello, cuenta con defensas judiciales más específicas:

§ 654. I. *Hereditatis petitio*. Cuando alguien le niegue su calidad de heredero, contará con la *hereditatis petitio*, a los efectos de que sea declarado heredero y le sea atribuida la herencia (D.5.3; EP, § 65).

1. Así, si alguien posee una cosa hereditaria, y reclamada ésta por el heredero, no sólo se opone a su entrega, sino que además le cuestiona que sea el heredero, ya sea pretendiendo que él es el heredero o simplemente negando la condición de heredero del reclamante.

2. Para el supuesto de que el heredero iniciara una *actio particular* (así, p.ej., una *rei vindicatio*), el

demandado para evitar que con ello se "prejuzgue" la condición de heredero del actor, podía oponer una *exceptio* (primero fue una *praescriptio ne praeiudicium fiat hereditati* (Ulp., D.5.3.5.2). De este modo, en la *rei vindicatio* no se puede considerar para nada la situación del heredero, de tal modo que el actor deberá reducir sus pruebas a las relativas a la cuestión singular planteada, sin poder valerse de que sea heredero. Con ello, puede obligar a éste a tener que actuar por la *hereditatis petitio* en caso de serle esencial probar su calidad de heredero.

3. Comienza siendo una acción *in rem* con fórmula semejante a la de la *rei vindicatio* (EP, § 232). El actor podía optar entre el procedimiento *per sponsionem* (con *sponsio* de 125 sesteracios; Gayo, 4.95) o actuar *per formulam petitoriam*.

Pero en la época republicana e incluso luego de establecido el procedimiento formulario, la costumbre era presentar la *hereditatis petitio* ante el Tribunal de los Centunvirs, en cuyo caso se actuaba por el *sacramentum*.

La fórmula petitoria ante el pretor tendría cláusula restitutoria, según el arbitrio del *iudex*.

A) Esta acción es iniciada por el heredero civil, testamentario o *ab intestato*, quien por supuesto deberá probar su calidad de tal. Si hay más de un heredero, el pretor otorga la fórmula *si pars hereditatis petatur* (D.5.4; EP, § 66), es decir, sólo por su parte en la herencia.

B) Debe ser llevada a cabo contra quien posee la totalidad o una parte de la herencia, o aun una sola cosa hereditaria cuando se desconozca la calidad de heredero del actor (Ulp., D.5.3.9; Gayo, D.10 pr. y 1). El demandado puede poseer a título de heredero (*pro herede*), es decir que se cree de buena o mala fe que es heredero ("poseo porque soy heredero"; Ulp., D.5.3.11), pero también se terminó admitiendo la acción contra el simple poseedor (*possessor pro possessore*), es decir, poseyendo sin alegar título alguno ("poseo porque poseo"; Ulp., D.12.12; 13 pr.).

1. En la época posclásica el deudor de la herencia que rehúse pagar negando la calidad de heredero del actor, también será admitido como demandado a título de *possessor iuris* (Ulp., D.12.13.15).

2. Al igual que ocurre con la *rei vindicatio*, también, bajo influencia bizantina, puede ser demandado el que se finja dolosamente poseedor (*fictus possessor*), actuando en el juicio y produciendo con ello engaño al heredero (Celsio, D.5.3.45; Celsio-Ulp., D.12.13.13).

3. Contra aquel que invoca un título particular de adquisición: así, por haber comprado la cosa (*pro emptore*), o habérsele sido donada (*pro donato*) o tenerla en dote (*pro dote*), no se otorga en principio la *hereditatis petitio*, aunque el interesado puede aceptar esta vía. En algunos casos excepcionales

se otorga una *actio utilis* (Ulp., D.5.3.13.1; D.1d.4; D.1d.8-10).

C) En el año 129 d.C., bajo el gobierno de Adriano, se aprobó el s.c. *Iuventianum* (tomó el nombre de uno de los cónsules, el jurista proculéyano Juvencio Celso). Conocemos su texto, por la reseña que hace Ulpiano (D.5.3.20.6), que comenta en los párrafos siguientes.

1. En realidad, este s.c. se refiere al caso muy particular de las partes "caducas", las cuales, según las leyes de Augusto, debían recaer en el *Aerarium* (más tarde en el fisco). Si los bienes de estas partes "caducas" eran poseídos por terceros, podían ser reivindicadas por la *vindicatio caducorum*, que no es sino una variante especializada de la *vindicatio hereditatis* (es decir, la *hereditatis petitio*).

2. Conforme al texto se plantea el caso de que los demandados por la acción petitoria hubiesen vendido los bienes de dichas partes. El s.c. distingue el caso de poseedores de buena fe y de mala fe.

Se habla de "poseedor de buena fe" cuando los demandados hubiesen creído tener justas causas de que los bienes les pertenecían. En ese caso debían devolver solamente aquello que por tal motivo los hubiese hecho más ricos, es decir, devolviendo el precio de venta cobrado, sin intereses.

En cambio, el "poseedor de mala fe" era especialmente el que sabía que los bienes no le pertenecían, aun cuando antes de la *litis contestatio* hubiesen dolosamente dejado de poseer. En este caso, se continuaba el juicio contra él, pudiendo ser condenados "como si poseyeran". Debía restituir el valor real de los bienes vendidos y sus frutos, aunque lo que hubiesen cobrado hubiese sido menor (Ulp., D.5.3.20.6 y 12). Por una decisión de Alejandro Severo se extendió a todos los poseedores de mala fe, aunque no hubiesen vendido la cosa (Ulp., D.1d.12).

Esto era importante, por cuanto si antes de la *litis contestatio* el que poseía había dejado de poseer, no se podía ejercer contra él acción alguna. El actor debía dirigirse contra el nuevo poseedor.

3. Como se ve, este s.c. *Iuventianum* se refería solamente al caso de los *bona caduca*. Con posterioridad, quizá por los propios compiladores bizantinos de Justiniano, lo dispuesto en este s.c. se extendió a todos los casos de la *hereditatis petitio*, ya no pedida por el erario (o el fisco), sino por cualquier persona particular (Ulp., D.5.3.20.9 itp.).

D) De este modo, si tenemos en cuenta la fusión de las reglas del s.c. *Iuventianum* con las propias de la *hereditatis petitio*, podemos decir que los efectos de esta acción son semejantes a los de la *rei vindicatio**, con algunas modificaciones:

a) En cuanto a las cosas hereditarias poseídas indebidamente, ellas o su valor debían ser restituidas.

Si una de ellas se hubiese vendido, había que seguirlo ya dicho por el s.c. *Iuventianum*. Si hubiese perimido antes de la *litis contestatio*, el poseedor de buena fe no responde de la pérdida, aunque hubiera sido por su culpa (Ulp., D.5.3.31.3). En cambio, el de mala fe responde en todos los casos. Luego de la *litis contestatio*, ambos, sean de buena o de mala fe, responden por la pérdida, aunque el primero sólo por su culpa, y no por caso fortuito (Paulo, D.5.3.40 itp.).

b) En cuanto a los frutos, el poseedor de buena fe debe devolver todos aquellos que ha percibido y con ellos se ha enriquecido (Paulo, D.5.3.40.1). En cambio, el poseedor de mala fe los debe devolver de manera muy amplia: no sólo los percibidos sino los que, por su negligencia, hubiera debido producir o percibir la cosa (Ulp., D.5.3.25.4; Paulo, D.5.3.40.1).

c) En cuanto a las mejoras, el poseedor de buena fe tenía una *exceptio doli* para que se le pagaran las mejoras necesarias, útiles y voluptuarias (Paulo, D.5.3.38). No así el de mala fe, al cual Justiniano termina por otorgarle el valor de las necesarias y útiles (Paulo, D.1d. itp.).

En la época de Justiniano, la *hereditatis petitio* es considerada una acción "mixta" (tanto *in rem* como *in personam*), quedando clasificada entre los *bonae fidei iudicia* (Inst., 3.31.12.3; Inst., 4.6.28). Por esto último el juez tiene amplias facultades para decidir equitativamente los distintos aspectos que se plantearan.

§ 655. II. *Interdictum quorum bonorum*. Este interdicto (restitutorio) era concedido por el pretor para proteger al *bonorum possessor*. Mediante él podía pedir la restitución de las cosas hereditarias —sólo las corporales— que le correspondían y que estaban detentadas por otro, ya alegando ser heredero (*pro herede*) o ser meramente poseedor (*pro possessore*). También contra el que hubiera dejado de poseer en forma dolosa. No corresponde si la cosa hubiese sido usucapida (Ulp., D.43.2.1 pr.; EP, § 227; D.43.2; C. 8.2).

1. Este interdicto lo tiene todo heredero a quien se le hubiere concedido la *bonorum possessio*.

El heredero civil cuenta igualmente con el interdicto *quam hereditatem* (EP, § 229) por el que cuando el demandado en la *hereditatis petitio* no aceptara el pleito, podía estimar el valor de la herencia y reclamarlo.

2. Como el interdicto *quorum bonorum* resultaba más práctico, con Justiniano se realiza una aproximación con la *hereditatis petitio*. Este emperador acordó el interdicto tanto al heredero como al *bonorum possessor* (C.8.2.1 itp.). Servía para el b.p. como trámite introductorio de la cuestión respecto de la acción petitoria, que pasó a llamarse *hereditatis petitio possessoria*.

§ 656. III. *Acción de partición de herencia*. Cuando existen varios herederos, la herencia permanece en principio en estado de indivisión. La comunidad formada cesa si los herederos, en forma privada, por medio de pactos, se dividen la herencia. Si ello no ocurre, cualquiera de ellos puede pedir judicialmente la partición por medio de la *actio familiae erciscundae* (EP, § 80; D.10.2; C.2.36).

Como las otras acciones divisorias (*actio communi dividundo* y *actio familiae erciscundae*), la fórmula contiene una *adiudicatio** (Gayo, 4.42), de tal modo que lo que correspondía al juez era determinar la parte que le correspondía a cada heredero.

Con Justiniano, pasa a ser una acción mixta (tanto *in rem* como *in personam*), y la hace figurar entre los *bonae fidei iudicia* (Inst., 4.6.20 y 28).

1. Si se trata de una herencia testamentaria, el juez debe cumplimentar las asignaciones de partes hechas por el testador (Pap.-Ulp., D.10.2.20.3).

En la época justiniana, la partición efectuada en el testamento ocasionaba la atribución directa de la propiedad de las cosas asignadas, que de este modo no entraban en la comunidad (Nov.18.7; 103.3).

Un caso distinto ocurría cuando el padre o el abuelo divide los bienes entre los hijos y éstos aprueban y suscriben el documento (*divisio inter liberos*; Nov.18.7).

2. El juez puede atribuir las cosas en forma separada. Si eran de distinto valor, había que asignarles uno, efectuándose los compensaciones pertinentes. Igualmente, se podía ordenar la venta efectuándose la partición en cuanto al precio obtenido (Ulp., D.10.2.22.1).

Había que tomar en consideración los frutos o rentas percibidos por los herederos (Paulo, D.10.2.56), así como los gastos necesarios efectuados y no distribuidos (Paulo, D.10.2.25.15) y también los daños causados a la herencia (Ulp., D.10.2.16.4-5).

CAPÍTULO 6
LEGADOS Y FIDEICOMISOS

I. Los legados.

§ 657. *Concepto de legado.* El legado (*legatum*) es una disposición de última voluntad que el testador impone al heredero, respecto de cosas determinadas, en favor de un tercero, que se denomina legatario (*legatarius*).

1. En todo legado intervienen tres personas: a) el causante que lo ha ordenado en un testamento (o en un codicilo* confirmado por testamento; Gayo, 2.270a); b) el heredero, quien tiene la obligación de cumplirlo; y c) el legatario, que es el beneficiario del legado.

El legatario no está en la situación de heredero. Por ello no es un adquirente *per universitatem*, sino sólo a título particular. De ahí que su validez depende de la existencia de un heredero testamentario. Si no hay testamento no puede haber legados. Si éste es inválido, también serán inválidos los legados. Si el heredero instituido no acepta la herencia, los legados del testamento caen.

2. Las definiciones de legado que figuran en los textos del Digesto son posclásicas.

Así, la de Florentino (D.30.116 pr.): "Legado es una disminución (desagregación) de la herencia, con la cual el testador quería que fuera dejado a otro algo de lo que en su totalidad habría sido del heredero".

También Modestino (D.31.36) dice que "legado es una donación dejada en el testamento".

3. Esta institución de los legados fue muy usada en Roma, y mereció la atención particular de los juristas (Gayo, 2.191-245; D. libros 30-36; Inst., 2.20.24).

Así, desde los tiempos primeros, si el testador había optado por un determinado heredero, podía beneficiar a los otros familiares que habían sido excluidos (su mujer, sus hijos e hijas, parientes inválidos).

Eran usuales, en tal sentido:

a) el legado de usufructo, que asegura que el legatario pueda usar y gozar de un determinado bien; y hasta de todos los bienes hereditarios (Ulp., 24.26; D.33.2);

b) el legado de renta periódica, ya por mensualidades, anualidades, etc. (Pomp., D.33.1), lo que permitía la manutención del legatario; también el legado de alimentos (Ulp., D.34.1.14);

c) igualmente, el legado de dote, por el cual el

heredero queda obligado a dotar a las hijas del testador (D.33.4);

d) también, para beneficiar a un hijo o a un esclavo, les puede legar un peculio (Inst., 2.20.20). Y a la mujer, el legado de las cosas que usaba en la casa (ajuar, mobiliario, provisiones, etc.). Y en especial los regalos que el marido hubiese hecho a la mujer, según la interpretación extensiva de la "presunción Muciana", según la cual, salvo prueba en contrario, todo lo que hubiera recibido en vida la mujer se presumía que provenía de su marido y entraba por ello en el legado (Pomp., D.24.1.51; C.5.16.6.1).

§ 658. *Clases de legados.* Originariamente existieron dos formas de legados: una, el legado *per vindicationem*, con eficacia real, es decir, atribuyendo al legatario la propiedad o uno de los *iura in re aliena*, y el otro, el legado *per damnationem*, con eficacia obligacional, es decir, imponiendo al heredero una deuda en favor del legatario. Luego aparecieron otras formas intermedias.

A) Legado *per vindicationem*. Es llamado así porque se trata de la transmisión *mortis causa* de la propiedad quiritaria de una cosa al legatario. Así: "Doy y lego a Ticio mi esclavo Stichus" (Gayo, 2.193).

El legatario adquiere directamente la cosa legada, sin intervención del heredero, pudiendo en caso de no serle entregada reclamarla como suya por la *rei vindicatio*, ya del heredero o de cualquier tercero que la poseyera (Gayo, 2.194).

1. Las formas empleadas son *do lego*, aun empleadas aisladamente. Pero también: *Capito* (aprehende), *Sumito* (toma) o *Sibi habeto* (tenga para sí); (Gayo, 2.193; Ulp., 24.3).

La forma *Do* no significa mera entrega de la cosa, sino de la propiedad de ella, o de otro de los *iura in re*; así, el usufructo (Paulo, 3.6.17); o de una servidumbre (Pomp., D.8.6.19.1). En estos últimos casos el legatario cuenta con la *vindicatio usus fructus*, o con la *vindicatio servitutis*.

2. Respecto de la adquisición, para los sabinianos, el legatario es propietario quiritario desde que el heredero ha aceptado la herencia, aunque él ignore

que ha recibido un legado. Los proculeyanos piensan que la cosa es del legatario sólo después de que éste manifieste su intención de que le pertenezca, es decir, que lo acepte (Gayo, 2.195).

Por una constitución de Antonino Pio, se exigía la deliberación previa y la aceptación posterior (Gayo, 2.195). Sin embargo, parece ser que la opinión prevaleciente fue la sabiniana. Así lo dice Ulpiano (D.30.44.1): "Cuando el legatario no repudió el legado, se considera que fue de él, desde que fue aceptada la herencia"; e igualmente Juliano (D.30.85.2).

3. Las únicas cosas que pueden ser legadas *per vindicationem* son las pertenecientes a la propiedad quiritaria del testador, tanto en el momento de la confección del testamento, como en el momento de su muerte. Esto será modificado por el s.c. Neroniano (v. *infra*, § 659, A).

Se admitió, respecto de las cosas genéricas (aceite, trigo, dinero amonedado); que bastaba que le pertenecieran al testador sólo en el momento de la muerte (Gayo, 2.196).

B) Legado *per damnationem*. La fórmula empleada era: "Que mi heredero sea constreñido a dar (a Ticio) mi esclavo Stichus" (Gayo, 2.201). De este modo se crea una obligación para el heredero, consistente en realizar una determinada prestación en favor del legatario.

A diferencia del anterior, el legatario no es directamente titular de la cosa legada. Al contrario, la tiene que reclamar al heredero, contando para ello con la *actio ex testamento*.

Esta forma de legar es la más amplia de todas. Se puede legar cosas del testador, del propio heredero y aun de un tercero. En los dos primeros casos, el heredero está obligado a transmitir el derecho sobre la cosa: así, si es una *res mancipi* por medio de la *mancipatio** o la *in iure cessio*†; si es una *res nec mancipi*, mediante la *simple traditio*. Si la cosa es ajena, el legatario queda obligado a adquirirla y entregarla al legatario. Si esto no se logra, deberá cumplir su obligación entregando el valor estimado de ella (Gayo, 2.202).

1. La amplitud de este legado se ve en las múltiples formas que puede adoptar. Así, legar una cosa específica o genérica, pero también un crédito hereditario, cediendo el heredero por estipulaciones las acciones para que el legatario lo cobre, etc. Por ello será denominado el legado por excelencia: *optimum ius legatum* (Gayo, 2.197; Ulp., 24.11).

2. Mientras que el legado *per vindicationem* produce efectos reales, en tanto que el legatario obtiene directamente del testador el dominio quiritario, y por ello, si no se le entrega la cosa puede accionar por la *rei vindicatio*, el legado *per damnationem* produce efectos obligacionales. El legatario sólo tiene un crédito contra el heredero. Si no cumple voluntariamente

su obligación, el legatario lo podrá obligar por la *actio ex testamento*.

3. La *actio ex testamento* es de derecho estricto, con una fórmula *certa* (respecto de una cosa específica o su valor) o *incerta* (respecto de cosas genéricas o indeterminadas); EP, § 170.

Por lo menos, en caso de fórmula *certa*, si el heredero se niega a entregar la cosa y continúa el juicio, se incurre en *litis crescentia**, de tal modo que en caso de ser condenado el heredero, lo será por el *duplum*.

En caso de estar sometido el legado a un plazo o a una condición, el legatario podía exigir al heredero una caución (*cautio legatorum servandorum causae*), para cubrir una eventual insolvencia por parte de aquél (Ulp., D.36.3.1 pr. y ss.).

C) Legado *sinendi modo* (a modo de permisición o tolerancia). Se trata acá de que el heredero debía permitir que el legatario mantuviera una determinada situación de hecho (así, servidumbres, situaciones posesorias, uso, habitación, etc.), y también que tomara, bajo permisición o tolerancia del heredero, cosas del testador o del patrimonio del heredero.

La fórmula empleada era ésta: "Que mi heredero tenga que tolerar que Lucio Ticio tome y adquiera para sí a mi esclavo Stichus" (Gayo, 2.209 ss.). En la época clásica, el legatario cuenta para su cumplimiento con la *actio ex testamento* (con fórmula *incerta*: "Es necesario que el heredero dé y haga lo dispuesto en el testamento"; Gayo, 2.213).

1. Se trata de una forma intermedia entre el legado *per vindicationem* y el legado *per damnationem*. Se parece al primero, en cuanto que tiene efectos reales. Y al segundo, más aún en la época clásica, por sus efectos obligacionales, lo que explica la *actio (incerta) ex testamento*.

Sin embargo, tiende a aproximarse al legado *per damnationem*, ya que la cosa legada no le pertenece en propiedad al legatario desde la aceptación de la herencia. En realidad es del heredero —al igual que en el legado *per damnationem*— hasta que el legatario quiera tomar la cosa, o se vea obligado a entregarla (Gayo, 2.213).

2. Para una parte de los juristas, demasiado lógicos, el heredero no está obligado ni a mancipar, ni a ceder *in iure*, ni a entregarla, puesto que simplemente ha sido condenado a un papel pasivo: permitir o tolerar que el legatario tome la cosa legada. Pero predominó la opinión contraria, que otorgaba al legatario la *actio ex testamento* (Gayo, 2.213-214).

3. También, por las cosas que se puede legar *sinendi modo*, resulta más amplio que el legado *per vindicationem* (sólo las cosas que están en el dominio quiritario del testador), pero menos que el legado *per damnationem*, ya que se puede legar cosas de la

herencia o del heredero, pero no de un tercero extraño (Gayo, 2.210).

Las cosas deben estar en el patrimonio del testador o del heredero en el momento de la muerte del causante, aun cuando en el momento de la faición del testamento no fuesen ni de uno ni de otro (Gayo, 2.211).

D) Legado *per praeceptionem* (de *praecipito*: toma por adelantado). La fórmula era así: "Que Lucio Ticio reciba por adelantado a mi esclavo Stichus" (Gayo, 2.216).

La interpretación de este legado motivó discusiones entre los juristas:

a) Para los sabinianos era un derecho de preferencia que el testador otorgaba a un heredero instituido por una parte de la herencia, de tal modo que cuando se realizara la partición de los bienes por la *actio familiae erciscundae*, el juez debía adjudicar con preferencia a sus herederos, la cosa legada (Gayo, 2.217 y 219). Pero otorgado este legado a un tercero extraño, es nulo (Gayo, 2.218).

b) En cambio, para los proculeyanos este legado era atributivo de propiedad, para lo cual interpretaban que la partícula *prae* era superflua, y que lo que era importante era el *capere* (tomar, apoderarse) del legado. De este modo, podía ser otorgado tanto a un heredero instituido como a un tercero extraño, como si hubiera sido un legado *per vindicationem*. Esta posición fue confirmada por una constitución de Hadriano (Gayo, 2.221).

1. Para la dilucidación de esta controversia jugaba el ejercicio del s.c. *Neronianum*, al cual nos referiremos inmediatamente. Según él, si en el legado *per vindicationem* se legaba una cosa que no era *ex iure Quiritium* del testador, el legado era eficaz, valiendo como si fuera un legado *per damnationem* (Gayo, 2.197). Aunque, como veremos, se fue ampliando la aplicación de este s.c. para otros casos.

Los sabinianos, consecuentes con su posición de que el legado *per praeceptionem* era distinto del legado *per vindicationem*, persistieron en sostener que sólo era válido cuando era otorgado a un heredero instituido, estableciendo que el s.c. *Neroniano* no le era aplicable (Gayo, 2.218).

En cambio, los proculeyanos continuaron diciendo que era válido este legado *per praeceptionem* respecto de un tercero extraño. Si la cosa legada era del dominio quiritario del testador, podía reivindicarla. Si fuera ajena o sólo del dominio bonitario del testador, el legado quedaba convalidado por el s.c. *Neroniano* (Gayo, 2.222).

2. Juliano y Sexto (¿Pomponio? ¿Africano?) aceptaron con los sabinianos que el legado *per praeceptionem* hecho a un tercero extraño era nulo por el *ius civile*, pero por aplicación del s.c. *Neroniano*, debía

ser confirmado y valer como legado *per damnationem* (Gayo, 2.218).

Finalmente, Hadriano, profundizando la opinión citada, se inclina por la tesis proculeyana. De este modo, cuando puede valer como legado *per vindicationem*, el tercero extraño tendrá la *rei vindicatio*, y en los otros casos acepta la convalidación por el s.c. *Neroniano* (Gayo, 2.221).

§ 659. *Evolución posterior de las formas*. Las distintas formas de las cuales nos habla Gayo quedaban referidas a las formas y palabras empleadas. Hubo una tendencia creciente en evitar que por ciertas sutilezas de las fórmulas usadas se produjera la invalidez de los legados.

A) La primera determinación estuvo señalada por el s.c. *Neronianum* (entre el 54 y el 68 d.C.). Aparece en principio mencionado por Gayo (2.193), refiriéndose a que si por el legado *per vindicationem* alguien legaba una cosa que nunca fue suya, el legado —que sería nulo por el *ius civile*— era eficaz como si se hubiera legado de "derecho óptimo" (*optimum ius*). Este era el nombre que se asignaba al legado *per damnationem*, que era el más amplio de todos, y que permitía legar una cosa ajena.

Sin embargo, ya fuera que figurara también en dicho s.c., o debido a la interpretación de los juristas clásicos, se extendió la aplicación a otros casos. Así, respecto al empleo de palabras inadecuadas en el otorgamiento de los legados e igualmente respecto de las personas (caso ya visto del legado *per praeceptionem*).

De este modo, sin abolir las formas solemnes, aunque restándoles eficacia, en caso de que un legado fuera por el *ius civile* inválido, resultaba convalidado por el s.c. *Neroniano*. Así, si p.ej. el testador ha legado la cosa de otro *per vindicationem*, o *sinendi modo* o *per praeceptionem*, el legado permanecía válido como legado *per damnationem* (Gayo, 2.197, 212, 220; Ulp., 24.11a; FV, § 85).

B) Una reforma más radical se produjo con Constantino, quien suprimió los requisitos de las fórmulas solemnes, tanto para la institución de herederos (C.6.23.15; año 339), como para los legados (C.6.37.21; año 339). Según estas disposiciones, las cuatro clases de legados no quedan abrogadas, de tal modo que el testador podía optar por la que quisiera. Pero en la expresión de su voluntad no se tienen en cuenta vocablos exclusivos. Todos resultan eficaces si es que resulta clara la intención del testador de legar.

C) Finalmente, con Justiniano las cuatro clases de legados desaparecen, de tal modo que todos gozan de "una misma naturaleza" (*ut omnibus legatis una sit natura*), pudiendo el legatario, cualquiera que fueran los términos del legado, perseguir su ejecución por medio de ac-

tiones in rem, in personam o por la *actio hypothecaria* (Inst., 2.20.2; C.6.43.1, año 529).

1. Pese al empeño unificador de los legados, en el sentido de que por la forma empleada siempre valdrá como legado, Justiniano no pudo ir contra las características propias de la intención del testador y también las de la propia cosa legada, por lo que el otorgamiento de las acciones mencionadas dependerá de cada uno de los casos.

2. Así, se podrá ejercer una *actio in rem* cuando el legado consiste en una cosa del testador o del heredero, ya fuere la *rei vindicatio* para el supuesto de que se trate del dominio, o la *actio confessoria* si se trata de una servidumbre.

Pero indudablemente no se puede ejercer la *rei vindicatio* si la cosa es ajena, o si por alguna característica del legado su cumplimiento resulta incompatible con la *actio in rem*; así, p.ej., si depende de un hecho del heredero o de su abstención, o si se trata de un legado de crédito o de deuda.

3. En cambio, para todos los casos, el legatario tiene la *actio ex testamento*, que es una *actio in personam*, de tal modo que se dirige contra el heredero para obligarlo a cumplir con el legado.

4. A su vez, la *actio hypothecaria* del legatario es una creación de Justiniano. Éste concede al legatario una hipoteca tácita* sobre la parte de la herencia del heredero gravado con el legado prohibiendo toda enajenación o pignoración de las cosas legadas (C.6.43.1.1; 3.2.4, año 529). Por ello es que puede ejecutar lo legado, persiguiendo la cosa en manos de quien la tenga y con preferencia a los acreedores personales del heredero. Sólo debe esperar que se cobren los herederos del causante, porque los legados son exigibles una vez pagadas las deudas hereditarias.

§ 660. Características de los legados por su objeto.

Pueden ser legadas tanto las cosas corporales como las incorporeales, así como universalidades (Inst., 2.20.21).

I. *Legados de cosas corporales determinadas*. Se puede legar las cosas propias del testador, como también las cosas del heredero, y las de otro. Lo que se exige es que se trate de una *res in commercio* (Inst., 2.20.4). Si no lo fuera, así p.ej. el legado de un templo o de una *res publica*, el legado es nulo y el heredero no debe ni la estimación de la cosa (Inst., *ibid.*).

1. El legado de la cosa ajena sólo era posible en la forma *per damnationem*. Luego, el s.c. Neronianus lo convalida para cualquier forma de legado. Y con Justiniano, al unificar la naturaleza de los legados, se pudo directamente legar.

Sin embargo, se hace una distinción, que arranca ya de Antonino Pio (Inst., 2.20.4). Hay que averiguar

si el testador sabía que la cosa era ajena o ignoraba que la cosa fuera de otro.

Si sabía que era ajena, se interpreta que el testador quiso gravar conscientemente al heredero con este legado. Quedaba obligado a comprarla y darla al legatario, o bien su precio si no pueda comprarla.

En cambio, si ignoraba que era ajena, el legado es nulo. Esto se explica porque siendo el legado un gravamen al heredero, se interpretaba que la voluntad del testador debía ser bien clara; es decir, sabía que era ajena y lo mismo la legó, mientras que si lo ignoraba, probablemente no hubiese hecho este legado. La prueba de si el testador sabía o ignoraba que fuera ajena, le corresponde al legatario, y no al heredero (Inst., 2.20.4; Marciano, D.23.3.21).

2. Si la cosa estaba hipotecada, el heredero debía desempaños. Y se aplica acá la misma distinción anterior: si el testador sabía que estaba hipotecada, le corresponde al heredero pagar la obligación hipotecaria, pero no si no lo sabía (rescriptos de Severo y Antonino). Sin embargo, si el testador hubiera querido que el desempeño quede a cargo del legatario, y así lo ha manifestado, es éste, y no el heredero, quien debe pagar la deuda hipotecaria (Inst., 2.20.5).

II. *Legados de cosas genéricas*. Así, p.ej., si se lega un esclavo, o un caballo, es decir, un "género", no una "especie" (*legatum generis*). Basta con que el género esté bien aclarado (Ulp., 24.14). Pero si está totalmente indeterminado (p.ej., un animal o una planta), sería más bien de una cosa incierta y es nulo (Paulo, 3.6.13). Se trata, pues, de una cuestión de hecho a determinar en cada caso (Ulp., D.30.71 pr.).

1. En la época antigua y clásica, si se trataba de un legado *per vindicationem*: "Doy a Ticio un esclavo", era válido si en la herencia había por lo menos un esclavo bajo el dominio quirritario del testador. Si había varios, el legatario, por tener la *rei vindicatio*, tenía el derecho de elegirlo (Paulo, D.6.1.6).

Si se trataba de un legado *per damnationem*: "Que mi heredero sea condenado a tener que dar un esclavo, hubiera o no esclavos en la herencia", era entonces el heredero obligado el que podía elegir cuál esclavo entregaba al legatario (Ulp., 26.14; Afric., D.30.108.2 (tp.)).

2. Justiniano decide esta cuestión estableciendo que la elección le pertenece al legatario, a menos de existir una disposición contraria por parte del testador (Inst., 2.20.22).

Pese a ello, en caso de que en la herencia no haya cosas del género legado, el legatario no tendría la *rei vindicatio*, sino la *actio ex testamento*, por lo que en este caso sería el heredero quien debe elegir (Pomp., D.33.5.2.1 y 12; Ulp., D.30.47.3; Paulo, D. 33.6.4).

III. *Legado de cosas incorporeales*. El legado puede consistir en la constitución de un usu-

fructo, una servidumbre, o un uso o una habitación (v. *supra*, § 657, 3). Pero aparte de ello, hay ciertos casos especiales sobre legados de créditos y de deudas.

A) *Legado de crédito*. Si el testador tiene un crédito no cobrado lo puede dejar en legado (*legatum nominis*). En realidad el crédito figura en cabeza del heredero, como sucesor del *de cuius*. Para poder cumplir este legado éste debe ceder las acciones pertinentes para que pueda actuar el legatario reclamando del deudor (Inst., 2.20.21).

1. La manera de efectuar esta cesión era constituyendo al legatario como una especie de mandatario del heredero, como "procurador" suyo, pero en beneficio del legatario (*procurator in rem suam*).

El heredero se limita a ceder las acciones respectivas. No garantiza ni la solvencia del deudor, ni aun la existencia de la obligación (Jul., D.30.105; Ulp., D.íd. 39.3; 75.2).

2. El legatario puede obligar al heredero por medio de la *actio ex testamento*, pero si se rehusaba el heredero le era concedida una *actio utilis* para actuar ante el deudor (Diocleciano, C.6.37.18).

3. Si el testador cobra en vida el crédito-legado, el legado es nulo (Inst., 2.20.21). Si lo cobra el heredero, puede ser compelido a tener que reembolsar lo cobrado al legatario (Ulp., D.32.11.13; Afric., D.íd.64).

B) *Legado de liberación*. En este caso, el testador libera a un deudor suyo de la deuda que tiene con él. Así, p.ej.: "Lego a Ticio la liberación de lo que me debe" o "Prohíbo a mi heredero demandar a Ticio por lo que me debe" (*legatum liberationis*; D.34.3; Inst., 2.20.13).

1. En realidad, el legado no es un modo válido para extinguir una obligación. En consecuencia, de estar estrictamente a lo que dice el *ius civile*, la deuda subsiste. Pero si el heredero pretende iniciar la acción de cobro, el legatario le puede oponer la *exceptio doli mali* (Ulp., D.34.3.3.3; Paulo, D.44.4.8.1).

Pero también puede actuar por la *actio ex testamento* contra el heredero para obligarlo a que realice el modo de extinción de la obligación (así, p.ej., por una *acceptilatio**; Inst., 3.29.1, 2 y 4).

2. El legado de liberación puede hacerse también indirectamente; así, p.ej., legando al deudor el documento escrito donde conste la deuda (*chirographum*). Al menos valdrá como fideicomiso (Ulp., D.34.3.3.1-2).

C) *Legado de deuda*. Se trata del caso de que se legue al acreedor del testador la deuda que éste tiene con él. Este legado es en principio nulo, ya que no consiste en una liberalidad, puesto que se trata de la obligación debida.

Pero resulta válido si con el legado le procura al acreedor una ventaja. Así, si el testador

ha legado pura y simplemente la obligación que era debida a plazo y bajo condición (Inst., 2.20.14).

1. Lo mismo ocurre cuando un marido lega a su mujer la dote. Si bien ésta debe serle restituida, la situación de la mujer es mejor, por cuanto de este modo puede ejercer la *actio ex testamento* que permite escapar a las retenciones y demás particularidades de la *actio rei uxoriae* (Inst., 2.20.15). Era llamada *dos prolegata* (D.33.4).

Si la mujer no hubiere constituido ninguna dote, según un rescripto de Severo y Antonino había que hacer una distinción: si el legado se hace sin explicación alguna, es nulo. Pero si el testador hace alguna indicación respecto de una suma de dinero o una cosa que deben ser separadas de la herencia vale como legado dotal (Inst., 2.20.15).

2. Justiniano, cuando se refiere al legado al acreedor (Inst., 2.20.14), establece la opinión de Papiniano de que, aun cuando el fincencimiento del plazo o el cumplimiento de la condición ocurran en vida del testador, el legado es válido. No resulta muy lógico por cuanto la ventaja otorgada al acreedor por el legado ya no existe al tiempo de la muerte del testador, por lo que el legado sería inútil. La opinión de Papiniano-Justiniano parece confirmada por una regla general de Paulo (D.50.17.85.1), pero en general está contradicha en otros párrafos del Digesto que consideran nulo el legado (Marciano, D.34.8.3.2; Paulo, D.31.82 pr.).

IV. *Legado de opción*. Se trata acá no propia y directamente del legado de una cosa, sino que lo que se lega es la "opción" o la "elección" que debe efectuar el legatario de una cosa genérica (Ulp., 24.14; D.33.5).

Así, en la época clásica tenía generalmente por objeto el poder elegir un esclavo dentro de los que están en la herencia: "Que Ticio opte por uno de mis esclavos. De este modo, como lo que se lega es un derecho personal de "opción" por aquel esclavo que elija el legatario, es necesario que dicha decisión sea tomada en forma personal por el legatario.

1. Es por ello que la opción no podía ser hecha por un *procurator* del legatario (Pap., D.50.17.77; Ulp., D.íd.123). Si el legatario moría sin haber optado, no transmitía el legado a los herederos (Inst., 2.20.23). Si se trataba de varios colegatarios, debían ponerse de acuerdo sobre la elección; de lo contrario el legado resulta impedido de ejecutarse.

2. En la época clásica quedaba asimilado al legado *per vindicationem* (Jul., D.33.5.11; Paulo, D.íd.13; Javol., D.íd.15). Antes de la opción el legatario cuénta con la *actio ad exhibendum* para que se le muestren las cosas entre las cuales debe elegir (Ulp., D. 10.4.3.6; Paulo, D.33.5.4; Afric., D. 33.13).

3. Para los clásicos, este *legatum optionis* tiene por objeto la *optio* o la *electio*. Por ello, no hay que confundirlo con el legado de cosas específicas ofrecidas en forma alternativa: "Lego a Ticio mi esclavo Stichus o mi esclavo Pánfilo". Aquí, si bien el legatario debía elegir, el objeto del legado no es directamente la *optio* o la *electio*, sino una de las cosas mencionadas por el testador. Si el legado era *per vindicationem*, *sinendi modo* o *per proceptionem*, la elección es del legatario, quien debe elegir una. Si era *per damnationem* la elección es del heredero. Todo ello si el testador no ha establecido expresamente a quién le correspondía elegir. Dicha elección pasa a los herederos (Ulp., D.36.2.12.7-8).

4. Justiniano termina confundiendo bajo la forma de "legado de opción o elección" las dos formas clásicas (el *legatum optionis* propiamente y el legado de cosas alternativas). En ambos casos, si el legatario no ha hecho en vida la elección, pasa a los herederos el derecho de optar. Si hubiere varios colegatarios o ya varios herederos de un solo legatario, para evitar que el legado perezca, según lo establecían los clásicos, había que someter la opción al azar, sorteando la cosa legada (Inst., 2.20.23; C.6.43.3).

V. Legado de una parte de la herencia. El testador, en lugar de legar una cosa determinada (*species*), o genérica (*genus*), o universalidades de cosas (p.ej., un rebaño, un peculio, etc.) podía legar una parte cualquiera de la herencia. Así, "Que mi heredero divida mi herencia compartiéndola con Ticio" (Ulp., 24.25). Esta especie de legado se denominaba *partitio* y el legatario "legatario parciario" (*legatarius partarius*; Ulp., *ibid.*; Gayo, 2.254). Podía ser por una cuota cualquiera, pero si no se decía nada, se entendía que era por la mitad (Ulp., D.50.16.184.1).

Este legado de parte de la herencia no convertía al legatario en coheredero, es decir, en continuador de la persona del *de cuius*, sino que tenía derecho como acreedor para reclamar al heredero su parte, como dirían los modernos "a título particular". Por ello:

a) La validez del legado depende siempre de la existencia del heredero. Si caía la institución de heredero por cualquier causa, caía igualmente la *partitio*.

b) No tiene un derecho directo sobre los bienes hereditarios. Por ello, no puede ejercer ni la acción de partición de la herencia (*actio familiae erciscundae*), ni la *petitio hereditatis*.

Respecto de los créditos y de las deudas, éstos continuaban recayendo en cabeza del heredero. Se realizaban entre éste y el legatario estipulaciones recíprocas (*stipulationes partis et pro parte*), al igual que en fideicomisos (Gayo, 2.254-257). De este modo se comprometían a atender los créditos y las deudas, pero transfiriéndolos, en proporción a la cuota legada. El

heredero prometía al legatario darle su parte de las sumas que le fueran pagadas y el legatario prometía reembolsarle su parte de las deudas que tuviera que pagar (Ulp., 25.15).

c) El "legatario parciario" por no ser heredero, sino legatario, no tiene vocación eventual al todo de la herencia, sino únicamente a la porción asignada. Por ello es que carece del derecho de "acrecer" respecto de la herencia. Así, siendo dos herederos: Ticio y Mevio y un legatario por un cuarto de la herencia, en caso de no llegar a ser Ticio heredero, quien acrecerá su parte es el coheredero Mevio, no el legatario parciario.

1. La razón de esta forma era otorgar el beneficio de la herencia a alguien a quien no se instituyó como heredero. Así, p.ej., para evitar la carga del culto familiar (*sacra privata*; Cic., de leg. 2.20). Servía igualmente para escapar a las prohibiciones de la *lex Voconia**, que prohibía al testador con patrimonio superior a 100.000 sesteracios instituir heredera a una mujer. De este modo, el *pater* instituía heredero a sus hijos varones, y beneficiaba a las mujeres como "legatarias parciarias".

O para el caso interesante que menciona Javoleno (D.28.6.39 pr.). Un *pater* tiene dos nietos, uno *in potestate* y otro emancipado. Para beneficiar a ambos, instituye al primero como heredero y al otro como "legatario parciario", pero de tal modo que si el que estaba *in potestate* muriera *impuber*, el otro lo sustituya como heredero (a semejanza de la "sustitución pupilar"). Esto fue lo aconsejado por Labeón, Ofilio, Cascelio y Trebacio.

2. Se interpretaba que era como un legado *per damnationem*. Respecto de los bienes hereditarios, los proculyanos entendían que el heredero les debía dar directamente en especie los bienes de su parte. En cambio, los sabiniianos opinaban que el heredero debía entregar el valor en dinero de dicha parte (*aestimatio*). Justiniano le permite elegir entre una u otra solución (Pomp., D.30.26.2 *itp.*).

3. El legatario parciario, si bien no puede acrecer respecto de la herencia, tiene este derecho si p.ej. son dos o más los legatarios. En este caso el derecho de acrecer es entre ellos y hasta el monto de la porción asignada.

4. En la época en que el legado parciario estuvo diferenciado del fideicomiso, esta forma de legar era frecuente. En cambio, con Justiniano, aparece totalmente confundido con el fideicomiso. Por ello es que esta clase de legado no aparece citado en sus Institutas.

VI. Legado de peculio. El testador puede legar, ya a un tercero, pero más frecuentemente a un esclavo suyo, al cual lo manumitía en el testamento, el peculio* que en vida le había concedido, como un reconocimiento a sus servicios (Inst., 2.20.20).

estableció la diferenciación entre el *dies cedens* y el *dies veniens*.

1. Según lo explica Ulpiano (D.50.16.213 pr.), estas expresiones se aplican en forma general a otros negocios: "Ceder" el término significa comenzar a ser debido el dinero. "Llegar" el término significa haber llegado el día en que se puede reclamar el dinero. Y nos pone el ej. de una *stipulatio*: "Cuando uno hubiere estipulado pura y simplemente, "cede" y "llega el término". Si es a plazo, "cedió" el término, pero no "llegó" todavía. Si es bajo condición, ni "cedió", ni "llegó" el término, estando todavía pendiente la condición".

A) Aplicado a los legados, se establece que el *dies cedens*, que coincide normalmente con la muerte del causante, asegura en beneficio del legatario, un derecho eventual para su adquisición. Decimos eventual porque la suerte del legado corre pareja con la del testamento, y éste puede resultar invalidado o tornarse ineficaz, p.ej. si el heredero repudia la herencia y cae el testamento.

— Pero se entiende que producido el *dies cedens*, el derecho, aunque eventual, figura en cabeza del legatario y por ello es transmisible a sus herederos (Ulp., D.36.2.5.1). Este derecho eventual se efectiviza cuando se produzca la aceptación de la herencia por el heredero. Acasce entonces el *dies veniens* y desde ese momento el legatario o sus herederos gozan del derecho de reclamar el legado.

B) Esta solución de atribuir el legado —aunque no su adquisición efectiva— en un momento objetivo, fuera del momento subjetivo de la aceptación hereditaria por el heredero, se aplica en caso de un legado puro y simple. Y también si el legado era a plazo cierto (Ulp., D.36.2.5.1).

Pero no si fuera condicional (o a plazo incierto), ya que en este caso hay que esperar que ocurra el evento condicional, desplazándose el momento del *dies cedens* hasta que se produzca esa circunstancia. Por ello si el legatario muere antes de que se cumpla la condición, no trasmite su derecho a sus herederos (Ulp., D.36.2.5.2).

1. En un comienzo el momento del *dies cedens* es el del momento de la muerte del causante. La ley *Papia Poppaea* lo llevó al momento de la apertura del testamento (Ulp., 24.31). Pero Justiniano lo volvió a restablecer en el momento de la muerte (C.5.51.1.1 c.5).

2. Respecto del legado *per vindicationem*, los sabiniianos entendían que en un legado bajo condición, mientras ésta no se cumpliera la cosa es del heredero. Los proculyanos, en cambio, fieles a su principio de que el legatario no adquiere la cosa sino a partir de su aceptación, habían decidido que la cosa era una *res nullius* (Gayo, 2.200).

1. El peculio, como ocurría igualmente con un rebaño, es una universalidad que crece o decrece. Por ello acá tiene importancia saber en qué momento había que tomar en consideración el monto del peculio. Aquí, había que tener en consideración cuándo nacía el derecho eventual del legatario (regla del *dies cedens*, que veremos más abajo).

Estos aumentos no están referidos a nuevas adquisiciones que logre el legatario, sino a aquellos que provengan directamente de las cosas integrantes del peculio (*ex rebus peculiaribus*; Inst., 2. 20) Así, p.ej., el aluvión que aumenta la extensión del campo, el nacimiento de las crías de los animales del peculio, etc.

2. Si se trataba del legado del peculio a un tercero, el momento del derecho eventual del legatario estaba fijado a la muerte del testador (*dies cedens*). En consecuencia, los aumentos posteriores no beneficiaban al legatario (Inst., *ibid.*).

3. Si se trataba del legado del peculio a un esclavo, el momento de dicho derecho quedaba fijado cuando se producía la manumisión de éste, y ello ocurría con la aceptación de la herencia. Por ello el peculio se engrasa con los aumentos producidos entre la muerte del testador y la *aditio hereditatis* (Inst., *ibid.*).

4. El esclavo manumitido por testamento no tiene derecho al peculio, si éste no le ha sido legado. Pero si hubiera sido manumitido en vida del testador, el esclavo puede retener el peculio, bastando que el *dominus* no se lo hubiese reclamado. De todos modos, si en las relaciones domésticas el esclavo le hubiera adelantado sumas al dueño, éstas no pueden ser reclamadas por el legado (Const. de Severo y Antonino, D.33.8.3.4; id., Diocleciano y Maximiano, C.7 23; Inst., 2.20.20).

§ 661. Adquisición de los legados.

Como hemos visto, la efectividad de los legados depende de la existencia válida de un testamento, y además de que exista realmente un heredero. Si éste es un heredero "necesario", como la sucesión se opera *ipso iure*, el legatario detenta directamente su derecho al legado desde la muerte del testador. En cambio, siendo un heredero "extraño", había que esperar que se produjera la aceptación de la herencia.

En este caso, hasta tanto el heredero acepte, el derecho del legatario es una mera expectativa, que se verá frustrada si p.ej. el único heredero repudiara la herencia. Esto traía un perjuicio para el legatario, puesto que el heredero extraño podía retrasar la aceptación, calculando p.ej. la inminente muerte del legatario. Si esto ocurría, el heredero se veía libre de tener que cumplir el legado, ya que al no haber sido adquirido por el legatario, no pasaba a sus herederos.

Para poder favorecer la voluntad testamentaria, y amparar los legados, la jurisprudencia

Según ya dijimos, la opinión pravalescente fue la sabiniana, si bien atenuada por Juliano, que consideraba que la aceptación quedaba pendiente para el legatario, hasta el momento de aprehensión de la cosa (Juliano, D.30.86.2).

C) Hay, sin embargo, ciertos casos en los cuales el *dies cedens* no se opera al momento de la muerte del testador:

a) Si se trata del legado dejado a un esclavo a quien se manumite por el mismo testamento. El requisito de la manumisión adquiere prevalencia, puesto que un esclavo no puede recibir legados. Ello recién ocurrirá cuando se produzca la aceptación de la herencia por el heredero: entonces se puede decir que el libertado adquiere el legado. Consecuentemente con lo dicho, el *dies cedens* no se puede establecer a la época de la muerte del causante, sino que se traslada al momento de la *aditio hereditatis* (Ulp., D.36.2.7.6; D.41.8; ver *supra*, § 660, VI, 2).

b) Si se trata de un legado de usufructo, uso o habitación, por ser derechos concedidos en forma personalísima, el *dies cedens* se traslada al momento del *dies veniens*. Ello es así porque la fijación del *dies cedens* está establecido en interés del legatario y de sus herederos. Pero acá, como dichos derechos son intrasmisibles a los herederos del legatario, éstos carecen de interés (Ulp., D.36.2.2.2; 3).

D) Con el *dies veniens* el legatario tiene derecho a adquirir el legado. Si éste es puro y simple, puede ejercer la *rei vindicatio* si se trata de un legado con efectos reales y la *actio ex testamento* si se trata de un legado con efectos obligacionales. Si se trata de un legado con plazo cierto, deberá esperar el cumplimiento de éste.

1. Lo que no puede hacer el legatario es lograr las cosas por su propia mano, esto es, sin el consentimiento del heredero. El pretor protege al *bonorum possessor* (en la época de Justiniano el heredero) contra el legatario que se apresura a tomar por sí el legado con un interdicto para recuperar la posesión (*interdictum quod legatorum*).

§ 662. *Acrecentamiento entre colegatarios*. Cuando un legado es dejado conjuntamente a dos o más personas, y uno de ellos queda excluido por muerte, incapacidad o renuncia, se puede producir el "acrecentamiento" en favor del o de los legatarios restantes.

A) En la época en que se distinguían las cuatro clases de legados, pero anterior a las leyes caducarias, era necesario observar cómo se había otorgado el legado.

Por de pronto, el legado podía haber sido dejado en forma "conjunta" (*coniunctim*), de este

modo: "Doy y lego mi esclavo Stichus a Ticio y a Seyo"; o en forma separada (*disiunctim*), así: "Doy y lego mi esclavo Stichus a Lucio Ticio; doy y lego el mismo esclavo a Seyo".

a) Si se trataba de un legado *per vindicationem*, sea que haya sido dejado *coniunctim* o *disiunctim*, a cada uno de los legatarios le pertenece una parte y la porción del que faltare acrece la de sus colegatarios (Gayo, 2.199; Ulp., 24.12). Esto se explica fácilmente por cuanto se trata de un legado de propiedad, la cual ha sido legada en su totalidad, por lo que faltando uno, se produce el acrecentamiento en favor del otro u otros colegatarios.

1. Si lo legado *per vindicationem* era un usufructo, si uno de ellos no lo adquiere, el otro acrecienta su parte. Pero tenía la particularidad de que habiéndolo adquirido, p.ej., dos colegatarios y posteriormente uno de ellos muere, el acrecentamiento se produce en favor del otro (Ulp., D.7.2.1.2-3), a diferencia de lo que ocurría si fuera la propiedad, porque la parte del fallecido pasa a los herederos (Ulp., FV.77). Esto se debe al carácter temporal del usufructo, de tal modo que en cuanto uno no se halla en concurrencia con el otro, usará de todo el usufructo.

b) Si el legado era *per damnationem*, el acrecentamiento no se producía nunca, ya que lo que se lega no es la propiedad sino un crédito contra el heredero.

Así, si el legado era *coniunctim*: "Condeno a mi heredero a dar el fundo a Ticio y a Seyo", ambos colegatarios tienen una porción del crédito en particular, el cual era dejado en común, y cada uno debía pedir su parte. De este modo, la porción del que falte no acrece la de su colegatario, sino que permanece en la herencia y beneficia al heredero (Gayo, 2.205; Ulp., 24.13).

Si el legado había sido dejado *disiunctim*: "Condeno a mi heredero a dar el esclavo Stichus a Ticio; condeno a mi heredero a dar el mismo esclavo a Seyo", cada uno de los legatarios tendrá derecho a pedirlo al heredero. El primero que lo haga obtiene al esclavo, mientras que el otro su estimación (*aestimatio*). Esto se explica por cuanto el legado le es debido a cada uno por la totalidad (Gayo, 2.205; Ulp., 24.13), pero no existe el acrecentamiento (*ius adscrescendi cessat*; FV, 85 y 87).

c) Si el legado era *sinendi modo*, se aplican las mismas reglas que en el caso anterior, es decir, no se aplicaba el acrecentamiento.

1. Gayo nos habla de discusiones entre los juristas cuando era *disiunctim*. Según unos, se debe la totalidad de la cosa, igual que en el legado *per damnationem*. Según otros, es preferida la posición del ocupante, ya que en este género de legado el heredero

es compelido a sufrir pacientemente que el legatario se apropie de la cosa, y habiéndose producido así, el heredero quedaba a cubierto de cualquier reclamo del otro. No nos dice nada del dejado en forma *coniunctim*, pero se debían aplicar las reglas del legado *per damnationem* (Gayo, 2.215). Pero a pesar de las diferencias doctrinarias, es evidente que no existía el acrecentamiento.

d) Finalmente, siendo el legado *per praecipationem*, se aplican las mismas reglas que respecto del legado *per vindicationem*, es decir, cada uno tiene una cuotaparte de la cosa y existe el acrecentamiento (Gayo, 2.223).

B) Las leyes caducarias de Augusto sancionaron que las partes caducas de los legatarios incurros como *caelibes u orbi* iban a parar al *aerarium* (luego al fisco), otorgando —al igual que el caso de los coherederos— un sistema de "premios" en favor de los otros colegatarios que tuvieran hijos. Esto no era propiamente acrecentamiento, sino una adquisición nueva con derecho para vindicar las partes caducas (*ius cadaua vindicandi*; v. *supra*, § 645, 2).

C) Justiniano suprimió las leyes caducarias, y habiendo reducido todos los legados a una misma naturaleza, estableció, en relación al acrecentamiento entre colegatarios, que él tenía lugar siempre, cuando una misma cosa ha sido dejada a dos o más legatarios, ya fuera en forma *coniunctim* o *disiunctim*. Si falta uno de ellos, ya por negarse al legado, ya por fallecer antes que el testador, o por otra causa cualquiera, el colegatario tiene el derecho entero (Inst., 2.20.8; C.6.51.1).

1. Sin embargo, hace una distinción, que es un residuo de la legislación caducaria, al establecer que si el legado es *disiunctim*, el acrecentamiento se produce en forma forzosa y sin hacerse cargo de los gravámenes que pesen sobre la cosa (*sine onere*); lo mismo que ocurría en la ley Papia, con las partes caducas. En cambio, si era dejado en forma *coniunctim*, el acrecentamiento era voluntario, siendo además *cum onore*, es decir, haciéndose cargo de los gravámenes.

2. Pese al empeño unificador de Justiniano, figuran en el Digesto restos de las leyes caducarias, que resultan difíciles de interpretar en el sistema pensado por este emperador (así, Pomp., D.41.16 pr.; Ulp., D.41.34.9; Juliano, D.41.82.5 y 84; Paulo, D.31.7; Pomp., D.41.13 pr. y 1; Scév., D.41.89.2; Scév., D.32.36.2; Celso, D.33.2.14; Scév., D.41.9; Paulo, D.41.89).

§ 663. *Limitaciones al derecho de legar*. En los tiempos antiguos, la ley de las XII Tablas permitía que el testador tuviera la más amplia libertad para hacer legados (5.3; Gayo,

2.224; Ulp., 11.14; Inst., 2.22 pr.). Ello ocasionaba inconvenientes, ya que si la herencia estaba sumamente cargada de legados, el heredero no mostraba interés en aceptar la herencia por cuanto recibía o muy poco e incluso hasta nada de los bienes hereditarios, viéndose, al contrario, responsabilizado del pasivo del causante. Por ello se abstenía o no aceptaba la herencia, con lo cual caía el testamento, abriéndose la herencia *ab intestato*. De este modo quedaban burladas las expectativas de los legatarios (Gayo, 2.224).

A) Para evitar este problema se sancionó la *lex Furia* (primera mitad siglo II a.C.). Según sus disposiciones, se prohibió, salvo a ciertas personas, adquirir por legado o por causa de muerte una suma superior a mil ases.

Sin embargo, no se consiguió el efecto buscado, ya que, p.ej., quien tenía un patrimonio de 5.000 ases, podía agotarlo todo haciendo cinco legados de 1.000 ases, con lo cual cada le quedaba al heredero (Gayo, 2.225).

1. Las personas exceptuadas eran los *cognati* hasta el 6° grado (*sobrini*), y del 7°, es decir, el nacido del *sobrino* (FV, 301).

2. Quien contraviniendo lo dispuesto en la *lex Furia* adquiría más de 1.000 ases era pasible de una pena del *quadruplum*, que se hacía efectiva por la *manus iniectione pro iudicato* (Ulp., 1.2; Gayo 4.23).

B) Para evitar esto, apareció la *lex Voconia* (año 169 a.C.). Dispuso que a nadie, ya a título de legado o por causa de muerte, le era lícito adquirir más de lo que adquirirían los herederos.

Pero esta ley tampoco resultó eficaz, puesto que el testador podía distribuir su patrimonio en muchos legados a personas distintas, de tal modo que al heredero le quedaba tan poco que no le convenía, por esta reducida ventaja, tener que soportar las cargas de la herencia (Gayo, 2.225).

C) Finalmente, se aprobó la *lex Falcidia* (año 40 a.C.), que demostró finalmente haber resuelto el problema. Dispuso que no le era lícito al testador legar más allá de las 3/4 partes de la herencia, debiendo reservar al heredero una cuota mínima de 1/4 (*quarta Falcidia*; Gayo, 2.227; Ulp., 24.32; Inst., 2.22 pr.).

§ 664. I. A quién se aplica la *lex Falcidia*. La *quarta Falcidia* se le debe a todo heredero testamentario. En caso de haber dos o más herederos, se entiende que el derecho a recibir la cuarta parte reside en cada uno de ellos respecto de su cuotaparte hereditaria, sin ocuparse de la de los otros. Así, p.ej., se han instituido dos herederos: Ticio y Seyo, el primero cargado con legados que gravan su cuota más

allá de las 3/4 partes, el segundo, con su porción libre de legados. En este caso, Sevo, por no estar gravado con legados, recibe su cuota (la mitad de la herencia). En cambio, Ticio tiene derecho a pedir que se le asegure la cuarta parte de su cuota, debiéndose pagar los legados hasta donde alcancen las 3/4 partes restantes.

Ahora bien, si uno de los herederos no aceptara la herencia, el otro puede tener el *ius adscrescendi*. El problema era saber si la *quarta Falcidia* se debe aplicar en forma separada a cada una de las partes o éstas se confunden. Los sabinianos (Cassio) opinaban que las porciones se confundían, de tal modo que el legatario debía formar una sola masa de su cuota con la que acrecía, mientras que Próculo entendía que debían permanecer separadas. La primera posición tuvo a su favor una decisión de Antonino Pío. Pero, al inclinarse Juliano por la posición de Próculo, ésta resultó la prevaliente (Paulo, D.35.2.1.14; Gayo, D.id.78).

De este modo, había que distinguir:

a) Si la parte gravada con legados acrece a la otra parte que está libre de legados, esta última sigue permaneciendo intacta. El cálculo de la *quarta Falcidia* debe efectuarse solamente sobre la cuota que acrece.

b) Si ambas partes resultan cargadas con legados, la solución es igual. El cálculo de la *quarta Falcidia* debe efectuarse de manera separada respecto de cada cuota, la que acrece y la de quien recibe el acrecimiento.

c) Pero si la parte que acrece no está gravada con legados, y el legatario beneficiario del acrecimiento está cargado de legados, como todo el provecho es para éste, las dos partes se confunden y la cuarta hay que calcularla sobre el todo.

§ 665. II. Cálculo de la cuarta Falcidia.

El problema del cálculo de la cuarta parte involucra dos aspectos: el primero es determinar el momento en el cual se debe establecer el patrimonio; el segundo es, ya determinado éste, cómo se calcula la *quarta Falcidia*.

A) El cálculo de la *quarta Falcidia* debía efectuarse tomando el valor del patrimonio en el momento de la muerte del testador (Gayo, D.35.2.73 pr.), sin interesar los aumentos o disminuciones posteriores (Meciano, D.35.2.30 pr. y 2-4; Gayo, D.id. 73 pr.).

1. Cabe preguntarnos por qué se toma en cuenta el momento de la muerte del testador y no el de la adición de la herencia. Lo primero que hay que pensar es que ello es así por el principio del *dies cedens*, por el cual comienza el derecho eventual de los legatarios, que está fijado regularmente al momento de la muerte del testador.

2. Pero observarse que este criterio considera indistintamente a todos los legados, siendo que, como lo hemos visto, para algunos de ellos el *dies cedens* coincide con el *dies veniens*. Ello no obstante, la razón se encontraría en que, dado que las liberalidades habían sido fijadas por el causante, de manera invariable había que atenderlas, en relación con él, y no respecto del interés de los herederos en el momento en que debían optar por aceptar o no la herencia.

Para comprender mejor este principio veamos estos dos casos:

a) Cuando murió el testador su patrimonio era de 100 áureos y los legados eran de 100 áureos. El heredero debe calcular su cuarta parte en 25 áureos, no pudiendo los legados superar las 3/4 partes restantes (75 áureos). Y ello era así aun cuando en el momento de aceptar la herencia el patrimonio haya aumentado (así, por ingresos de los esclavos, o por hijos nacidos de esclavas o por crías que han tenido los ganados), y el patrimonio aumentó a 125 áureos. El monto máximo de los legados no puede superar la suma ya fijada de 75 áureos, es decir, a los legatarios no aprovecha en nada lo que obtenga el heredero de los bienes hereditarios después de la muerte del causante (Inst., 2.23.2).

b) Al revés, si el patrimonio ha disminuido (así, por incendios, naufragios o muerte de esclavos), supongamos a 75 áureos, los legados deberán ser siempre pagados por el monto de 75 áureos fijados para el momento de la muerte del testador (Inst., *ibid.*).

El heredero, en este último caso, resultaría burlado en sus expectativas hereditarias. Pero, como dice Justiniano, no es así, ya que siendo libre de aceptar o no la herencia, puede por ello llamar a los legatarios y ponerlos en la necesidad de pactar una transacción, porque de lo contrario no acepta la herencia y aquéllos perderían todo al caer el testamento (Inst., *ibid.*).

B) Para calcular el activo hay que deducir las deudas (Pap., D.35.2.15.3; C. 6.50.6; 14), los gastos funerarios (Paulo, D.id. 1.19; Marcelo, D.id. 2), el valor de los esclavos manumitidos (Inst., 2.22.3), así como también los gastos que demande la aceptación de la herencia (Gayo, D.35.2.72; C. 6.30.22.9).

Establecido entonces el patrimonio "neto", el heredero, en el caso de que los legados superen las 3/4 partes, apartará para sí la cuarta parte (*quarta Falcidia*) y las 3/4 partes restantes se deberán dividir a prorrata entre los legatarios conforme al monto de cada legado (Inst., 2.23.3).

Por supuesto, si el monto total de los legados no alcanza los 3/4 del patrimonio hereditario neto, el heredero debe cumplir con ellos en forma total.

1. En las Institutas de Justiniano (2.23.3) se dan los siguientes casos, que muestran cómo se efectúa el pago a prorrata:

a) El patrimonio hereditario es de 400 áureos de oro y los legados ascienden a la misma suma. El heredero apartará para sí 100 áureos. Con los 300 áureos restantes hay que pagar los legados, de tal modo que en proporción al monto de cada uno hay que pagar cada legado disminuido en 1/4 parte.

b) Si en el mismo ejemplo, la suma total de los legados es de 350 áureos, el heredero retiene su cuarta parte (100 áureos), y cada legatario recibirá el monto del suyo disminuido en 1/8 parte.

c) Finalmente, siguiendo el mismo ejemplo, si el monto de los legados es de 500 áureos, es decir, supera el monto de la herencia, se debe primero suprimir 100 áureos, es decir, lo que se excede del patrimonio. Luego, el heredero retendrá la 1/4 parte (100 áureos: el patrimonio era de 400 áureos), y con los 300 restantes habrá que reducir proporcionalmente cada uno de los legados, es decir, cada legatario recibirá 1/6 de lo que le correspondía.

2. Si el heredero no sabe aún si tendrá lugar la reducción del legado, antes de pagarlo podrá pedir al pretor que el legatario le preste una caución para el caso de que luego sea realmente reducido (Ulp., D.35.3.1 pr.). Pero si el heredero ha pagado por error un legado que debió haber reducido, luego no lo podrá reclamar (Paulo, D.22.6.9.5).

§ 666. III. Casos excluidos de la *lex Falcidia*. La aplicación de la *lex Falcidia* no se lleva a cabo en los siguientes casos:

a) En los testamentos militares (Scev., D.35.2.17; Macer, D.id. 92; Scév., D.id.96; C.6.21.12).

b) Si se trata de un legado de dote, ya que se considera que la mujer recibe una cosa suya (Gayo, D.35.2.81.1). Lo mismo si se lega a la mujer cosas de su uso personal (Ulp., D.id. 2).

c) En ciertas clases de legados: así, si se lega un esclavo con la carga de manumitirlo (Paulo, D.35.2.33); si se trata de un "legado de deuda" (*legatum debiti*), por cuanto se lega al legatario la cosa que le es debida (Marcelo-Ulp., D.30.28.1).

1. Justiniano ampliará las excepciones a los legados dejados a obras pías (Nov. 131.12). E igualmente, para el caso de que el heredero haya sido negligente en hacer el inventario, por lo que el heredero debía cumplir la totalidad de los legados (Nov. 1.2.2).

2. Pero además estableció un principio general, en virtud del cual la *lex Falcidia* no se aplica cuando el testador le deniega al heredero hacer uso de la *quarta*. Así, "Ticio sé heredero, y te doy este predio con tal de que no pidas la *quarta*" (Nov.1.2.2).

Esto es importante por cuanto se pierde, por lo menos en este caso, el carácter públicamente obliga-

torio de la *lex Falcidia*, para transformarse en una simple presunción de la voluntad del testador, que éste puede destruir por su manifestación contraria.

§ 667. Ineficacia de los legados.

I. Por la invalidez del testamento que lo contiene. Si el testamento es inválido, los legados también serán inválidos, por cuanto reciben su fuerza de aquél y de la institución de heredero (Gayo, 2.229; Inst., 2.20.34).

1. En la época clásica el legado debía ser ordenado después de la institución de heredero (Gayo, 2.229; Ulp., 24.15; Paulo, 3.6.2), puesto que la *heredis institutio* es "principio y fundamento de todo testamento". Justiniano consideró vituperable el hecho de darle primacía a la letra escrita sobre la voluntad del testador, y reformará este principio, declarando válido el legado hecho antes, entre o después de la institución de heredero (Inst., 2.20.34; C.6.23.24, año 528).

2. Sin embargo, se admitieron ciertas situaciones que significaban una independencia del legado respecto de la institución de heredero:

a) En la *bonorum possessio contra tabulas*, los peticionantes de ella tenían la obligación de pagar, en proporción a sus cuotas, los legados que dejó el testador a los ascendientes y a los descendientes. También a la mujer o a la nuera en carácter de dote (edicto *De legatis prestandis*; EP, § 143; Ulp., D.37.5.1 pr.; C.6.12.1).

b) En caso de ejercerse la *querella inofficiosa testamenti*, Justiniano establecerá que los legados quedaban en pie (Nov. 115.3.15).

c) Cuando un heredero *ab intestato* ha sido designado como heredero voluntario en un testamento, y para evitar tener que cumplir con los legados ha repudiado la herencia testamentaria, el pretor salva los legados mediante acciones con fórmulas ficticias (Ulp., D.29.4.1 pr.; EP, § 168).

d) Igualmente el fisco debe cumplir los legados de una herencia vacante. Además, el *ius adscrescendi* por las leyes caducarias podía implicar pagar los legados, por la cuota respectiva (*cum honore*); v. supra, § 645, B, 2-3; § 662, C, 1.

§ 668. II. Invalidez por causas intrínsecas al legado. Así, (a) en la época clásica por un defecto de forma no confirmable por el s.c. *Neroniano*; (b) si el objeto del legado es inmoral, ilícito (Marciano, D.30.112.3) o imposible. Así, si se hace un legado al único heredero (Ulp., 24.22; Florentino, D.30.116.1), o el legado de una cosa que es del legatario (Ulp., 24.20; Inst., 2.20.10); (c) si la cosa parece por caso fortuito (Inst., 2.20.16).

§ 669. Regla catoniana. Según un principio que parece elemental, un acto que es nulo en su origen

no puede tornarse válido por el solo transcurso del tiempo: "Aquello que está viciado en su inicio no puede convalidarse por el transcurso del tiempo" (Paulo, D.50.17.29).

Aplicado a la institución de heredero, la regla opera normalmente: es necesario que la capacidad de ser instituido heredero exista en el momento de la facción del testamento: "La institución que fue inútil desde el comienzo no puede convalidarse con posterioridad" (Licinio Rufino, D.50.17.210).

En principio, esta regla se aplica también a los legados: así, si el legatario carece de la *testamenti factio* (Celso, D.28.5.59.4), o si se legan cosas fuera del comercio (Inst., 2.20.4), etc., el legado es nulo ab initio.

Pero, podía ocurrir que ciertos legados involucran circunstancias que en el momento de la facción del testamento, los tornaran inútiles, pero susceptibles después de desaparecer. Así, p.ej., si se otorga un legado a alguien que está sometido a la potestas del que instituímos heredero (Gayo, 2.244); o también, si se lega a alguien una cosa que le pertenece (Inst., 2.20.10). Estos legados son inútiles, porque en el primer caso, estando el legatario *in potestate*, carece de sentido que se lo pueda reclamar a aquel de quien depende; y en el segundo, porque perteneciéndole la cosa al legatario es inítil reclamarla.

Sin embargo, luego de la facción del testamento podría ocurrir que en el primer caso el legatario quedara fuera de la potestas del heredero, o en el segundo, que el legatario vendiera la cosa, con lo cual ya no le pertenecía. Lo que se preguntan los juristas era: el legado ¿es nulo desde su origen?, o ¿podría tornarse válido si la situación inútil del comienzo variaba antes de que se produjera la adquisición del legado?

a) Los proculeyanos se mantuvieron en una respuesta negativa: el legado es siempre inválido.

b) Servio Sulpicio, en cambio, sostenía que si el legado era puro y simple, si la situación variaba estando vivo el testador (así, el hijo o el esclavo del heredero a quienes se dejaba el legado se emancipaba o era manumitido, el legado es válido. Si el legado era condicional, también valía si dicho acontecimiento ocurría antes del cumplimiento de la condición.

Y finalmente, (c) poniéndose en una situación intermedia los sabinianos opinaban que si el legado era condicional, era válido y había que esperar que el cambio de circunstancias ocurriera antes del cumplimiento de la condición. En cambio, si el legado era puro y simple, debía ser tenido por nulo, "porque sería absurdo que un legado que habría sido nulo si el testador hubiese muerto inmediatamente después de hecho el testamento, pudiera valer por el hecho de que haya vivido más tiempo" (Gayo, 2.244).

Esta última posición es la que se acuñó bajo el nombre de regla Catoniana (*Catoniana regula*).

Esta regla Catoniana es debida al hijo de Catón el Censor, llamado M. Porcio Catón Lici-

niano (siglo II a.C.). Establecía lo siguiente: "El legado que fuera nulo si el testador muere en el momento en que hace el testamento, no puede resultar válido sea cual sea el momento en que el testador hubiese muerto" (Celso, D.34.7.1 pr.).

Se aplica a los legados otorgados en forma pura y simple, pero no a los dejados bajo condición (Celso, D.34.7.1.1; Ulp., D.34.7.4). En efecto, en este caso, aun cuando el testador muriera inmediatamente después de hacer el testamento, el legado no había sido dado para producir efectos inmediatos, sino que estaba subordinado a una condición, de tal modo que había que esperar hasta que el acontecimiento condicional se cumpliera o no.

Por la misma razón no se aplica a aquellos legados en los cuales el *dies cadens** no ocurría con la muerte del testador, sino que coincidiendo con el *dies veniens*, sucedía con la aceptación de la herencia (Pap., D.34.7.3). En efecto, en este caso, aun cuando el testador muriera inmediatamente después de hacer testamento, no se puede decir que el legado sea nulo. Había que esperar si el obstáculo desaparecería o no antes de la aceptación de la herencia para saber si era válido o nulo.

1. Se trataría del caso de legado dejado al esclavo del testador (v. *supra*, § 661, C, a) y del caso del legado de usufructo (v. *supra*, § 661, C, b).

2. Tampoco se aplica a las instituciones de herederos (Pap., D.34.7.3). Igualmente no es de aplicación a los legados alcanzados por las leyes caducarias (Ulp., D.34.7.5; Ulp., 17.1); así, el legado hecho a un célibe, pues éste tiene 100 días para regularizar su situación.

3. Por ello, atendiendo a todos estos casos de excepción, Celso nos dice que "en algunos casos esta regla catoniana es falsa". Pero se aplica no sólo a los legados, sino también a los fideicomisos (C.6.37.13).

§ 670. *Legados a título de pena*. Legar a título de pena (*poenae nomine*) significa coaccionar al heredero, no al legatario, a que haga o no haga algo, y en caso de un obrar contrario se le impone como pena un legado. Así, p.ej.: "Si mi heredero diera su hija en matrimonio a Ticio, que le dé 10.000 sesterces a Seyo"; o también lo contrario: "Si mi heredero no diera su hija en matrimonio a Ticio, que le sean dados 10.000 a Seyo".

Esta clase de legados era nula. Se considera reprochable esta forma por cuanto el heredero resulta constreñido a hacer o no hacer algo, quedando a su arbitrio cumplir el deseo del testador o de lo contrario encontrarse gravado con un legado. Además, los legados se deben otorgar en forma amistosa basado en el afecto

que se siente respecto del legatario, y no en un resentimiento hostil contra el heredero (Theophilus, *Paraphr.*; Inst., 2.20.36).

1. El legado hecho en forma condicional al legatario; así: "Legó 10.000 a Ticio, si da su hija en matrimonio a Seyo", es perfectamente válido. Ticio considerará si acepta o no esa condición. En cambio, en el legado de pena, la condición de hacer o no hacer está dirigida no al legatario, sino al heredero.

2. El legado de pena se aplica igualmente a un legado de libertad de un esclavo, condicionando al heredero a sufrir el legado si no manumite a un esclavo (Gayo, 2.236), así como también a instituir un heredero (Gayo, 2.243), o a un fideicomiso (Ulp., 25.13). La prohibición del legado de pena se aplicaba incluso a los testamentos militares, a pesar de los favores que gozaban éstos (Inst., 2.20.36).

3. Justiniano permitirá que los legados y otras disposiciones a título de pena sean perfectamente válidos, salvo, sin embargo, las penas que obligaran a cosas imposibles, prohibidas por las leyes o deshonestas (Inst., 2.20.36; C.6.41).

§ 671. *Legados post mortem del heredero*. También es nulo el legado hecho para después de la muerte del heredero, como, p.ej.: "Cuando mi heredero haya muerto, doy y lego" (Gayo, 2.232; Inst., 2.20.35). La razón estaba en que no era un legado impuesto al heredero, sino al heredero del heredero (Ulp., 24.18; Paulo, 3.6.5).

1. En cambio, era válido si se legaba así: "Cuando mi heredero se muera", ya que en este caso no se deja para después de la muerte del heredero, sino para su última hora (Gayo, 2.232).

2. Era también nulo el legado hecho "después de la muerte del legatario" (Inst., 2.20.35). La razón es evidente: como el plazo incierto no se cumplirá sino luego de la muerte del legatario, el derecho al legado no lo tendrá nunca éste, de tal modo que no deja nada a sus herederos.

3. Esta regla no se aplica a los fideicomisos, en los cuales estas cláusulas eran válidas (Gayo, 2.277; Ulp., 25.8). Justiniano, al asimilar los legados a los fideicomisos, las tendrá por válidas también respecto de los legados (Inst., 2.20.35; C.4.11.1; 8.38.11).

§ 672. *III. Invalidez por incapacidad del legatario*. El legatario debe contar con la *testamenti factio passiva* (*supra*, § 620, II). De lo contrario el legado es inválido (Inst., 2.20.24).

1. Respecto de las personas "inciertas", se hablaba en primer término de aquellas que el testador no tenía presente en su espíritu de quien se podía tratar. Así, p.ej.: "A quien primero viniera a ofrecermela honras fúnebres, que mi heredero le dé 10.000";

o también: "A quienes luego del testamento serán designados cónsules". En estos casos el legado es inválido (Gayo, 2.238; Ulp., 24.18; Inst., 2.20.25).

Pero si se hacía una indicación cierta entre personas indeterminadas, entonces el legado es válido. Así, p.ej.: "Que mi heredero dé 10.000 a quien entre mis actuales cognados viniera primero a ofrecermela honras fúnebres" (Gayo, 2.238; Ulp., 24.18). O también "A quien entre mis actuales cognados tomara en matrimonio a mi hija" (Inst., 2.20.25).

2. Respecto de los "póstumos extraños", es decir, aquellos que al nacer no serán *sui heredes* del testador, tampoco se les puede legar (Gayo, 2.241; Inst., 2.20.16). Esto se debe a que son considerados personas inciertas.

Sin embargo, Justiniano reformará esto, permitiendo que los póstumos extraños, las diversas corporaciones, los pobres, puedan recibir legados y fideicomisos, aunque no la nominación de un tutor (Inst., 2.20.27; C.6.48).

3. En cambio, (a) si el testador se ha equivocado en el nombre, *cognomen* o *agnomen* del legatario, siempre que la intención del testador esté manifestamente expresada acerca de la persona del legatario, el legado es válido (Inst., 2.20.29; Ulp., 24.19; Gayo, D.35.1.17 pr.; Marciano, D.44.33; Florentino, D.44.34). Pero si la nominación es vaga o ininteligible, es reputada como no escrita (Ulp., D.28.5.9.1; Ulp., D.30.4; Const. Gordiano, C.6.23.4).

A su vez, (b) una equivocación en cuanto al dato del legatario, así p.ej.: "Legó a Stichó, nacido de mi esclava", y es cierto que no nació de ella, sino que lo había comprado, se entiende que como no hay problema de identificación, ese error no invalida el legado (Inst., 2.20.30). O si se dice: "El esclavo Stichó que he comprado a Seyo", cuando en realidad lo ha comprado a otro, el legado es válido (Inst., *ibid.*).

(c) Tampoco lo invalida una causa falsa. Así, p.ej.: "Legó mi esclavo Stichó a Ticio, porque ha administrado mis negocios durante mi ausencia", o bien "Legó mi esclavo Stichó a Ticio, porque en virtud de su defensa me ha logrado absolver de una acusación capital", aunque Ticio no haya prestado esos servicios al testador, el legado es válido (Ulp., 24.19; Inst., 2.20.31; Pap., D. 35.1.72.6; C.6.44).

En cambio, si la causa expresada fuese expresada como condición, el legado es inválido. Así "Legó tal fundo a Ticio si ha cuidado de mis bienes" (Gayo, D.35.1.17.2-3; Inst., 2.20.31). En realidad no es propiamente una condición, ya que no se refiere a un hecho futuro sino pasado, pero acá se interpreta la voluntad del testador que señala específicamente que sólo lega si la causa es real.

4. Respecto del esclavo podían suceder estos dos casos:

a) "Que Ticio sea mi heredero y lego 10.000 a su esclavo Stichó". En principio, si el legado es puro y simple, sería nulo puesto que según la regla catoniana, si el testador muere en el momento de la facción

del testamento, Ticio no es solamente heredero, sino que además como dueño del esclavo también recibiría el legado dejado a éste. Y no se puede reunir en una misma persona la calidad de heredero y de legatario (Florent, D.30.1.116.1; Juliano, D. id. 104.3 y 5; Inst., 2.20.32).

En cambio, si es condicional.—así, p.ej., "Que Ticio sea mi heredero y lego a su esclavo Stichus 10.000 si antes de la aceptación de la herencia fuera libreto", no se aplica la regla catoniana, y habrá que esperar si llegado el *dies veniens* se ha cumplido o no la condición (Inst., 2.20.32).

b) En el caso inverso: "Que Stichus esclavo de Ticio sea mi heredero. Y doy a Ticio un legado de 10.000". Acá el heredero, en principio, es Stichus. Si aplicamos la regla catoniana en relación al legatario Ticio, siendo el legado puro y simple, el *dies cedens* ocurre con la muerte del testador. Pero él no es el heredero, sino Stichus, y habrá que esperar que se acepte la herencia.

Si a ese momento la situación de esclavitud no ha cambiado, el legado será inválido, por cuanto Ticio será titular de la herencia y del legado. Pero puede ocurrir que en el lapso intermedio Stichus sea vendido (la herencia irá al nuevo *dominus*) o haya sido manumitido (la herencia irá a Stichus), y dándose alguno de estos supuestos, el legado a Ticio será válido, por cuanto el esclavo no lo pertenece (Inst., 2.20.33; Gayo, 2.245; Ulp., 24.24; Jul., D.36.2.17, Scév., D.35.2.20; Paulo, D.30.25; Jul., D. id. 91).

§ 673. IV. *Invalidez por voluntad del testador*. Puede ocurrir que el testador resuelva dejar sin efectos el legado. La situación más simple sería si al hacer nuevo testamento no habla para nada del legado. Pero, fuera de ello, pueden ocurrir estas dos situaciones:

a) *Revocación del legado*. Esto ocurre si en el mismo testamento el testador manifiesta su voluntad contraria a dejar el legado. Así, en la época clásica, tenía que emplear términos contrarios: Si primero había dicho "Doy y lego", basta que luego agregue, corrigiendo lo anterior: "No doy y no lego" (Ulp., 24.29). En la época de Justiniano no es necesario el requisito de términos contrarios, bastando cualquier expresión que signifique la voluntad revocatoria del testador (Inst., 2.21 pr.).

1. En la época clásica se solía hacer en un codicilo confirmado (Ulp., 24.29). Justiniano lo admite para el empleo de toda clase de codicilos (Inst., 2.21 pr.).

2. La revocación no sólo puede ser expresa, sino también tácita, interpretando la voluntad del testador (Paulo, D.34.4.16). Así, p.ej., si éste realiza actos incompatibles con el legado: p.ej., cobrando él mismo el crédito que ha legado (Inst., 2.20.21). Incluso se puede presumir de ciertas circunstancias: así, p.ej., si

ha surgido una enemistad evidente con el legatario (Ulp., D.34.4.3.11.4; Pap., D. id. 22; Scév., D. id. 31.2), o si el testador, por una escritura posterior, ha agregado una nota injuriosa contra el legatario (Marciano, D.34.4.13; Paulo, D. id. 29).

3. Un caso particular ocurría con el legado de una cosa particular, que luego el testador vendía. En la época clásica se podría pensar que por el s.c. Neroniano, el legado valdría *per damnationem*, que admite el legado de cosa ajena. Pero según Gayo, la opinión prevaleciente para su tiempo es que en este caso no se podía usar de dicho s.c. Neroniano, ya que si bien sería válido por el *ius civile*, el legatario que reclamara la cosa puede ser repelido por la *exceptio doli mali*, como si la demanda fuera hecha contra la voluntad del difunto (Gayo, 2.198; Inst., 2.20.12).

Sin embargo, triunfó finalmente la opinión de Celso, confirmada por un rescripto de Severo y de Antonino y consagrada por Justiniano (Inst., 2.20.12). Según ella, había que probar que la enajenación efectuada por el testador tenía la intención de revocar el legado. Si esta voluntad no existe, el legado es válido entendiéndose que no ha sido revocado.

Así, si la enajenación fue hecha por una necesidad urgente, los herederos son los que tienen que probar la intención de revocar (Ulp., D.32.11.12). Al contrario, si la enajenación ha sido sin ninguna necesidad, así por una donación, el legatario tiene que probar que no hubo intención de revocar (Modest., D.34.4.18).

El texto del rescripto mencionado (C.6.37.3) se refería al caso de un legado de fundos que luego el testador ha dado en *pignus*. Estimando que no se ha revocado el legado, se nos dice que el legatario podrá reclamar del heredero que desgrave dichos fundos, interpretando que el testador los ha tenido que hipotecar por necesidad.

Si sólo se vendía una parte del fundo legado, la parte restante es debida por el legado (Pomp., D.30.3 pr.). Según el rescripto respecto de la parte vendida, sólo se debe en el caso de que la venta haya sido hecha sin intención de revocar el legado.

b) *Traslación del legado*. El testador puede transferir el legado hecho en favor de alguien a otra persona: "El esclavo Stichus que yo he legado a Ticio, yo lo doy y lo lego a Seyo". Se entiende acá que hay una revocación del legado a Ticio y la constitución de uno nuevo en favor de Seyo (Inst., 2.21.1).

1. Según nos dice Paulo, la traslación de legado se podía hacer de cuatro formas: a) cambiando la persona del legatario; b) cargando con el legado a otro de los herederos instituidos; c) cambiando la cosa del legado; y d) subordinando a una condición el legado que en principio era puro y simple (D. 34.4.6).

2. En el primer caso, si el beneficiado por la traslación rehúsa el legado, ello no obstante el prime-

ro queda revocado, por ser ésa la voluntad del testador (Jul., D.34.4.3; Pomp., D. id. 20).

Si se trataba de un cambio de cosa legada, si la segunda no ha sido efectivamente dada, subsiste el legado de la primera, interpretándose que el testador no ha querido privar al legatario de todo beneficio (Pomp., D.32.18).

II. Los fideicomisos.

§ 674. *Concepto*. El fideicomiso (*fideicommissum*) es un negocio que nace basado solamente en la confianza (*fides*) depositada en una de las partes.

Su utilidad era evidente. Así, si una persona quería dejar algo a otro —p.ej., un amigo extranjero—, que no tenía la *testamenti factio passiva*, recurría a este procedimiento: encomendaba a alguien, que obraba como *heredero fiduciario*, para que, luego de su muerte, le diera, ya el total de la herencia, ya una parte, o ya solamente una cosa determinada a dicho extranjero, que era el beneficiario. Este tercero es denominado *fideicomisario*. Se puede dejar por fideicomiso la herencia por entero, o por una cuotaparte (*herencia fideicomisaria*). Pero también se puede dejar por fideicomiso una cosa particular (*fideicomiso de cosas singulares*).

La manera de encomendar un fideicomiso era así: "Ticio, sé heredero. Te ruego, L. Ticio, y te pido que tan pronto como aceptes mi herencia, se la devuelvas y la restituyas a Gayo Seyo". A diferencia del testamento, el fideicomiso es informal. Lo usual era emplear palabras tales como: "pido, ruego, quiero, confío en tu buena fe" (*Peto, rogo, volo, fidei committo*; Gayo, 2.249).

1. Ulpiano nos dice (24.1) que mientras en los legados son establecidos por palabras "imperativas" (*legis modo*), en los fideicomisos se emplean términos "rogativos" (*precativo modo*), y sin las exigencias del *ius civile*, interesando más la voluntad del causante. La falta de formalidades precisas llevaron a que un fideicomiso sería válido establecido por un simple signo (*nutus*) de la voluntad (Ulp., 25.3).

2. Debido a esta informalidad, los fideicomisos no sólo sirven para poder dejar cosas a quien carece de la *testamenti factio passiva*, sino también para evitar el efecto de las leyes caducarias (Gayo, 2.286). Igualmente para evitar los límites de las leyes *Furia y Voconia*, y en general para soslayar los formalismos y exigencias de los legados.

§ 675. *Evolución*. En un principio, en la época republicana, el cumplimiento de los fideicomisos era un compromiso moral, basado en la *fides* (Cic., *de finib.*, 2.17.18; Inst., 2.23.1). Pero

dada la negación del heredero respecto de su cumplimiento, Augusto ordenó a los cónsules que interpusieran su autoridad, entendiendo en ellos mediante la *extraordinaria cognitio*.

Esta medida de reconocimiento jurídico de los fideicomisos fue plenamente aceptada, y por decisión de Claudio se podía recurrir al *praetor fideicommissarius* (Pomp., D.1.2.32), y en provincias a los gobernadores (Gayo, 2.278). Como institución no totalmente asimilada al *ius civile*, se seguía siempre el procedimiento *extra ordinem*.

1. Esto significa que los fideicomisos no se reclamaban por la fórmula petitoria, sino siguiendo la jurisdicción extraordinaria. En Roma, un asunto de fideicomiso se puede reclamar en cualquier época, mientras que si se trata de un legado, sólo en los días fijados para las demandas judiciales (Gayo, 2.279).

2. En la época clásica los fideicomisos podían ser encargados en griego, lo cual no se podía hacer —en esa época— con los legados (Gayo, 2.281; Ulp., 25.9).

Luego, según una constitución de Constantino (C.6.37.21, año 339) se establece tanto para los legados como para los fideicomisos una amplia libertad de palabras, interesando la voluntad del causante, aunque "uno haya descuidado el uso del lenguaje".

3. En cuanto al número de testigos, Justiniano, interpolando una constitución de Theodosio II (C.6.36.8.3; año 424), decidió que, con excepción de los testamentos, el número era de cinco (Inst., 2.23.12).

Y también estableció que si un fideicomiso no podía ser probado ni por escritura ni por cinco testigos, en caso de que el heredero fiduciario se negara con "perfidia" a la restitución, negando haber recibido tal encargo, el fideicomisario, después de haber jurado su buena fe, podrá deferir el juramento al heredero fiduciario, quien deberá jurar que no ha recibido tal encargo del causante. Pero la voluntad del testador no peca nunca. Y así, si con posterioridad, después de haber negado el fideicomiso, confiesa después el hecho, aunque envolviéndose en sutilezas jurídicas, no dejará por ello de ser obligado a pagar (Inst., 2.23.12; C.6.42.32, año 531).

§ 676. *Reglas generales de los fideicomisos*. La regulación de los fideicomisos obedecía a las siguientes reglas:

A) El fideicomiso puede ser dispuesto en un testamento o en un codicilo, ya fuere éste confirmado o no por un testamento (Gayo, 270a; Ulp., 25.8; Paulo, 4.1.10; Inst., 2.25.1). También se lo puede establecer en una herencia *ab intestato* (Gayo, 2.270; Ulp., 25.4; Inst., 2.23.10).

B) El fideicomitente debe tener la *testamenti factio* para que el fideicomiso sea válido (Ulp., 25.4).

C) Se puede encomendar con un fideicomiso, tanto al heredero testamentario como *ab intestato* (Gayo, 2.260; 270; Inst., 2.24 pr.; 2.23.10).

Pero también al legatario (Gayo, 2.271), y a aquél que ha recibido una donación *mortis causa* (Pap., D.31.77.1; Ulp., D.32.3.8). Incluso al fisco, respecto de los bienes vacantes (Afric., D.30.114.2). La regla es, pues, que el fideicomiso puede gravar a todo aquel que reciba algo del *de cuius*.

D) El fideicomiso puede ser dejado en favor de cualquier persona, aun no teniendo la *testamenti factio passiva*.

1. Así, por de pronto a los extranjeros; pero también a la mujer que no podía ser instituida por la *lex Voconia* (Gayo, 2.274) y a los latinos junianos, que por la *lex Iunia Norbana* no pueden ser instituidos herederos o legatarios (Gayo, 2.275; Ulp., 25.7). Y también para escapar a las leyes caducarias, estableciendo por fideicomiso beneficios en favor de los *caelibes* y los *orbi*.

2. Pero luego que el fideicomiso es considerado como engendrando derechos válidos y exigibles, no se tardó en restringir las situaciones señaladas. Así, según el s.c. Pegasiano (bajo Vespasiano), debían respetarse las leyes caducarias, de tal modo que en caso de fraude podría el heredero fiduciario perder su derecho respecto de la *quarta pars* sobre los montos de las partes prohibidas (Gayo, 2.286a; Pap., D.34.9.11; Gayo, D.1d.10).

Si bien en un comienzo los extranjeros podían dar y recibir fideicomisos, y tal fue su origen, luego se les prohibió. Un s.c. habido en época de Adriano estableció que éstos fideicomisos podían ser vindicados por el fisco (Gayo, 2.285; Inst., 2.23.1; 2; 25 pr.). Tampoco se pudo por otro s.c. de Adriano dejar a las personas inciertas (Gayo, 2.287; Ulp., 25.13).

§ 677. I. *Fideicomisos de herencia*. El fideicomiso de herencia es aquel en el cual se deja toda una herencia, o una cuotaparte de ella. Así: "Que Lucio Ticio sea mi heredero", agregando luego: "Te ruego, Lucio Ticio, que restituyas esta herencia a Gayo Seyo, desde que puedas hacer adición de ella" (Gayo, 2.250; Inst., 2.23.2).

Ante todo debe existir un heredero, el heredero fiduciario, quien debe transmitir las cosas, créditos y deudas hereditarias al beneficiario ("fideicomisario"). Pero aun restituyendo la herencia, el heredero fiduciario no por ello deja de ser heredero (regla: *semel heres semper heres*). En cambio, el fideicomisario quedaba asimilado al heredero.

§ 678. A) En un principio, el uso común para cumplir el fideicomiso era así: el heredero fiduciario transmitía la herencia por medio de una venta figurada, que se operaba por una *mancipatio* en la que se pagaba una sola moneda (*nihilum uno*). Y al mismo tiempo se realiza-

ban estipulaciones recíprocas entre el "heredero fiduciario" y el "fideicomisario" a propósito de esta "compraventa" (*emptae et venditae hereditatis stipulationes*); Gayo, 2.252.

1. Estas estipulaciones se realizaban del siguiente modo. Respecto de las deudas hereditarias o por cosas que hubiera entregado de buena fe a un tercero, el heredero fiduciario preguntaba: "¿Prometes devolverme el dinero que por causa de las deudas hereditarias u otras acciones por causa de la herencia fuera yo condenado a pagar y seré rectamente defendido por ti en los juicios, actuando como mi *cognitor* o mi *procurator*?" y el fiduciario contestaba: "Lo prometo" (Gayo, 2.252).

Y a su vez, respecto de los créditos y acciones reclamando cosas hereditarias, el fiduciario preguntaba: "¿Prometes devolverme todo lo que se te pague por créditos hereditarios y dejarme ejercer todas las acciones por causa de la herencia como *cognitor* o *procurator*?" Y el heredero fiduciario respondía: "Lo prometo" (Gayo, 2.252).

2. Como estas *stipulationes* tenían su principio en la venta realizada eran denominadas *emptae et venditae hereditatis stipulationes*. Por ello, Gayo nos dice que en la época antigua el fiduciario "no ocupaba ni el lugar de heredero ni el de legatario, sino más precisamente el de un comprador" (Gayo, 2.252).

3. De este modo, quedaba salvado el principio del *semel heres semper heres*, puesto que el heredero fiduciario quedaba siempre como heredero, no obstante lo cual se lograba la transferencia de los créditos y de las deudas. Recalquemos, además, que en cuanto a las cosas de la herencia, éstas debían ser transmitidas en forma particular conforme a cada cosa *mancipi* o *nec mancipi*.

§ 679. B) Esta forma de transferencia tenía sus peligros: el primero, porque dependía de la solvencia de las partes; debido a ello, para precaverse de la insolvencia de lo estipulado, se empleaban cauciones de garantía (Gayo, 2.253).

Para solucionar este inconveniente se aprobó el s.c. *Trebellianum* (Nerón; año 56 d.C.). Se estableció en él que la persona del fideicomisario quedaba directamente asimilada a la de un heredero (*heredis loco*): ocupando el "lugar del heredero". Por ello, ya no son necesarias las estipulaciones, sino que *ipso iure* se le conceden al fideicomisario, bajo la figura de "acciones útiles", las que tenía el heredero o eran dirigidas a él (Gayo, 2.253).

1. La situación del heredero fiduciario es la siguiente: conserva la situación jurídica de heredero, si bien el fideicomisario está ahora en lugar suyo (*quasi heres*).

Pero prácticamente no puede ejercer con éxito las acciones. Así, si pretendiera cobrar los créditos de la

herencia, los deudores le opondrían la "excepción de herencia restituida" (*exceptio restitutae hereditatis*). Y si los acreedores del causante quisieran cobrarle a él, les podría oponer la misma excepción (Jul., D.36.1.27.7).

2. Las acciones que se otorgaban al fideicomisario eran acciones útiles, en las cuales el pretor empleaba la ficción "si fuera heredero" (*si heres esset*), de manera análoga a la empleada por el *bonorum possessor* (Gayo, 4.34; EP, § 68).

§ 680 C) Pero entonces ocurría otro inconveniente, ya que los herederos inscritos en el testamento a quienes se rogaba transmitir la totalidad o la casi totalidad de la herencia, rehusaban aceptarla, ya que el beneficio que aprovechaban era nulo o mínimo, motivo por el cual los fideicomisos se extinguían (Gayo, 2.254; Ulp., 25.15; Inst., 2.23.5).

Por ello, posteriormente, en época de Vespasiano (años 69-79 d.C.), se aprobó el s.c. *Pegasianum* (siendo cónsules Pegaso y Fusio). Por él se dará una solución análoga a la establecida por la ley *Falcidia*, a propósito de los legados: el heredero fiduciario podía siempre retener una cuarta parte de la herencia (*quarta Pegasiana*). El propio heredero es quien debe soportar las cargas hereditarias. El fideicomisario, que podía recibir hasta las 3/4 partes de la herencia, quedaba asimilado al "legatario parciario", debiéndose interponer entre heredero y fideicomisario las *stipulationes partis et pro parte*, que son usuales para el caso de esta clase de legados. Por ellas, los beneficios y las pérdidas son comunes y se reparten a prorrata (Gayo, 2.254; Ulp., 25.15; Paulo, 4.8.1 ss.; Inst., 2.23.5).

1. El régimen establecido por el s.c. Pegasiano no deroga el s.c. Trebelliano, sino que funcionaba en combinación con él. De este modo, la aplicación conjunta resultaba bastante compleja. Cabía distinguir los siguientes casos:

1. *Que el fideicomiso sea parcial e inferior a las 3/4 partes de la herencia*. En este caso, como el heredero fiduciario tiene asegurada su *quarta pars*, debe restituir el fideicomiso conforme al s.c. Trebelliano.

Las acciones hereditarias son dadas respectivamente contra el uno y el otro, a prorrata de sus porciones. En favor y en contra del heredero, en virtud de lo que dispone el *ius civile*, y en favor o en contra del fideicomisario en virtud del s.c. Trebelliano.

Sin embargo, como el heredero permanece heredero incluso respecto de la parte fideicomisaria que debe restituir, puede ejercer las acciones o ser dirigidas contra él, pero sólo hasta "el beneficio que obtenga de la herencia" (Gayo, 2.255; Ulp., 25.14; Inst., 2.23.6).

2. *Que el fideicomiso sea total, o por más de las 3/4 partes de la herencia*. Aquí se aplica el s.c. Pe-

gasiano. Ahora el heredero fiduciario que puede reclamar su parte, debe responder como heredero civil de las cargas hereditarias totales.

Por otra parte, ya no se puede hablar del fideicomisario como ocupando el lugar de heredero (*heredis loco*), sino el de "legatario parciario", debiendo mediar las *stipulationes partis et pro parte*. Acá, a su vez, podía ocurrir:

(i) Que el heredero fiduciario acepte la herencia y retenga su parte, es decir, la *quarta*. En este caso continúa siendo el heredero, y entre él y el fideicomisario deben celebrarse las *stipulationes partis et pro parte*, respecto de los créditos y de las deudas (Gayo, 2.257; Ulp., 25.15; Inst., 2.23.6).

(ii) Que el heredero fiduciario acepte la herencia, pero renuncie a retener su *quarta*. En este caso continúa siendo heredero, debe soportar todas las cargas; pero las *stipulationes* deben ser por el total de la herencia; es decir, volvemos a las *emptae et venditae hereditatis stipulationes* (Gayo, 2.257).

(iii) Que el heredero se niegue a aceptar la herencia. Entonces, puede ser compelido a restituirla por el magistrado. En este caso, el heredero pierde su *quarta*, pero el fideicomisario pasa al lugar de heredero (*heredis loco*) y las acciones en su favor o en su contra les son dadas como acciones útiles, conforme al s.c. Trebelliano. En este caso, dadas las seguridades que tiene el fideicomisario no son necesarias las *stipulationes* (Gayo, 2.258; Ulp., 25.16; Inst., 2.23.6).

§ 681. Todo este sistema muy complicado y hasta abstruso, fue reformado por Justiniano. No conservamos la constitución respectiva, pero el régimen aparece explicado en Institutas, 2.23.7.

Las estipulaciones que se practicaban fueron calificadas por Papiniano de "capciosas" (Inst., *ibid.*). Por ello, siguiendo el principio de la simplificación y de la claridad y rechazando la complicación, Justiniano deja sin efecto el s.c. Pegasiano, conservando sólo la vigencia del s.c. Trebelliano, aunque manteniendo algunas disposiciones del primero.

De este modo, considera al fideicomisario como el sucesor universal. En cuanto al heredero fiduciario podrá retener su *quarta*, obligándolo a aceptar la herencia y entregarla al fideicomisario, quien la podrá en caso de no aceptación reclamar judicialmente.

1. En el Digesto sólo existe el título sobre el s.c. Trebelliano (D.36.1), no así sobre el s.c. Pegasiano. El sistema quedó así:

I. En todos los casos, el heredero fiduciario deberá restituir la herencia al fideicomisario, conforme al s.c. Trebelliano, ocupando éste siempre el "lugar de heredero" (*heredis loco*).

II. Se mantiene la *quarta* en favor del heredero, con lo cual se conserva este principio del s.c. Pega-

siapo. Incluso, si la ha restituido por error, puede repetirla por la *condictio indebiti*, lo cual no era permitido en el derecho clásico (Páulo, 4.3.4; Inst., 2.23.7).

III. No hay necesidad de *stipulationes*. Si el heredero se queda con la *quarta* (conocida ahora por algunos como *quarta Trebelliana* y no *quarta Pegasiana*), las acciones se dividen a prorrata según la parte asignada a cada uno. Si no se queda con la *quarta*, entonces toda la herencia pasa al fideicomisario, juntamente con todas las acciones en favor y en contra.

IV. También se conserva del s.c. Pegasiano el poder exigir al heredero fiduciario la aceptación de la herencia, en caso de negarse a hacerla, pasando todas las acciones —en favor y en contra— en cabeza del fideicomisario, conforme al s.c. Trebelliano, de tal modo que no le queden al heredero ni cargas ni beneficios (Inst., 2.23.7).

§ 682. II. *Fideicomiso de cosas particulares*. Ocurre cuando se deja el fideicomiso de cosas singulares, como p.ej. un esclavo, un vestido, dinero amonedado (*pecunia numerata*), encargando al mismo heredero o al legatario transferir la cosa a un tercero, aunque no se pueda encomendar ningún legado al legatario (Gayo, 2.260; Inst., 2.24 pr.).

1. Se puede dejar en fideicomiso, no solamente las cosas propias del testador, sino también la del heredero o la del legatario o la del fideicomisario y también la de un tercero cualquiera (Gayo, 2.261; Ulp., 25.5, Inst., 2.24.1). Con ello se aproxima a la forma más amplia de legados, es decir, al legado *per damnationem*.

2. Si se trata de una cosa ajena que ha sido dejada por fideicomiso, el fideicomisario está obligado a comprarla y dársela al beneficiado, o pagar su estimación (Gayo, 2.262; Inst., 2.24.1).

En tiempos de Gayo, algunos pensaban que en caso de fideicomiso de una cosa ajena, en el caso de que el dueño no la quisiera vender, el fideicomiso se extingue, estableciendo que es una situación distinta del legado *per damnationem*. Pero el mismo Gayo parece no darla como la opinión prevaleciente (2.262). Justiniano, sin siquiera mencionar esta discrepancia, establece que en ese caso se debe pagar la estimación de la cosa (Inst., 2.24.1).

3. Existe, sin embargo, un límite: que no se puede encomendar un fideicomiso de cosa ajena por un valor mayor que el que ha recibido el encargado de cumplirlo (Gayo, 2.261; Inst., 2.24.1).

Esta regla era un principio general que se aplicaba también al heredero respecto de los legados: "Nadie puede ser obligado a tener que cumplir un legado que exceda lo que recibe por causa de la herencia" (Ulp., D.36.1.1.17; D.40.5.24.13). En principio, será nulo el fideicomiso por la parte excedente.

Así, si al legatario o al fideicomisario que ha

recibido una suma de dinero se le ha ordenado o rogado que diera a otro una casa o un esclavo ajenos, que él debe comprar, y se le exige un precio que supera al monto recibido, no está obligado a comprar dicha cosa, pudiendo negarse a comprarla (Marcelo-Ulp., D.40.5.24.12-13).

Pero si se trata de una casa o de un esclavo propios, deberá cumplir el legado o el fideicomiso, sin poder alegar que ha recibido menos que el valor de dichas cosas. Se entiende que desde el momento que aceptó la carga la deberá cumplir (Pap., D.31.70.1; Marcelo-Ulp., D.40.5.24.12-13).

§ 683. Respecto de los fideicomisos de cosas singulares, se va logrando un acercamiento recíproco con los legados. Podemos observar un doble movimiento convergente. Por un lado, sobre todo a partir de los efectos prácticos del s.c. Neroniano*, se irá liberando a los legados de las formalidades estrictas. Por el otro, se va otorgando mayor protección y regulación jurídica a los fideicomisos; así, p.ej., la analogía de la *quarta pars* producida entre la ley *Falcidia* y el s.c. *Pegasianum*. Con Justiniano se produce la fusión de ambas instituciones (Inst., 2.20.2-3; C.6.43.1, año 529; Ulp., D.30.1 itp.: "En todo fueron iguales los legados con los fideicomisos").

1. Pese a ello, Justiniano, en sus *Institutas*, trata por separado los legados (2.20) de los fideicomisos de cosas particulares (2.24). Pero si se consideran los resultados prácticos, la igualdad es total: La disposición testamentaria que no pueda valer como legado no es nula sino que vale como fideicomiso; y recíprocamente todos los efectos de los legados se comunican y valen para los fideicomisos (Inst., 2.20.3).

2. Así, hemos visto cómo a los fideicomisos se los puede establecer con la misma amplitud en cuanto a las cosas, que lo permitía por el legado *per damnationem*. Igualmente, el derecho al gravado de poder retener la *quarta pars*. Y también, el principio del *dies ceditus* se aplica tanto a los legados como a los fideicomisos (D.36.2).

§ 684. III. *Fideicomiso de libertad*. También se puede por fideicomiso otorgar la libertad a un esclavo, rogando al heredero o al legatario, o al fideicomisario (Inst., 2.24.2) manumitirlo (Gayo, 2.263; Ulp., 25.16; 2.7; Inst., 2.24.2). Así: "Ruego, encomiendo a la *fides* de mi heredero que el esclavo Stichos sea manumitido" (Ulp., 2.7).

No interesa que el testador ruegue manumitir a un esclavo suyo, o a uno del heredero o del legatario, o más aún al de un tercero extraño (Gayo, 2.264; Ulp., 2.10; Inst., 2.24.2). En este último caso debe ser comprado y manumitido (Gayo, 2.265; Ulp., 2.11; Inst., 2.24.3).

El esclavo manumitido por fideicomiso no se hace libre del testador, como ocurre si hubiese sido manumitido en forma directa en el testamento (acá, se lo llamaba *Orcinus*), sino que su patrono es aquel que cumpliendo el fideicomiso lo manumite (Gayo, 2.266; Ulp., 2.8; Inst., 2.24.2).

1. Sin embargo, existe otra diferencia entre la manumisión directa por testamento y el fideicomiso de libertad. El testador puede manumitir en forma directa en el testamento, solamente al esclavo propio ("Que mi esclavo Stichos sea libre"; Gayo, 2.267 y 272; Ulp., 2.7-8; Inst., 2.24.2). En cambio, por fideicomiso se puede manumitir al esclavo ajeno, según lo dicho más arriba.

2. El tratamiento de este fideicomiso de libertad figura en un título especial del Digesto (40.5). En general, de su lectura se desprende un espíritu de *humanitas*, favorecedora de una interpretación proclive a la efectividad de la manumisión del esclavo.

Si bien el esclavo no tiene capacidad procesal, se admitió que en el procedimiento *extra ordinem* de los fideicomisos pudiera presentarse ante el pretor especial reclamando su voluntad.

3. Hay varios s.c. que demuestran el interés imperial en tal sentido:

a) Así, el s.c. Rubriano (Trajano), por el cual si los herederos no comparecen convocados por el pretor, éste considera libres a los esclavos manumitidos por fideicomiso (Ulp., D.40.5.26.7).

b) El s.c. Iuniano (año 127 d.C.), por el cual se permite que el pretor declare libre al esclavo si el heredero fiduciario no comparece o no da razones atendibles para no manumitirlo (Ulp., D.40.5.28.4).

c) El s.c. Vitrasiano (Hadriano), para el caso de que uno de los herederos fuera un *infans*, y por ello no se le rogó la manumisión, dado que no puede venderlo a los coherederos que sí fueron rogados, se interpreta (cfr. también con un rescripto de Antonino Pío) que le corresponde la libertad al esclavo, debiendo los coherederos darle al *infans* la cuota parte del valor del esclavo (Ulp., D.40.5.30.6).

d) El s.c. Danuciano (Hadriano), por el cual si se trata de personas ausentes por justa causa (p.ej., por ser prisioneros de guerra, o ser *furiosi*) y por ello no estar comprendidos en el s.c. Rubriano, si no se presentare el tutor o curador, el esclavo obtiene la libertad (Modest., D.40.5.36 pr.).

e) El s.c. Articuleyano (año 123 d.C.), por el cual, en provincias, los gobernadores entendían en el caso de ausencia de los herederos.

4. También por un rescripto de Antonino Pío y Pertinax se dan las libertades fideicomisarias, en caso de que la herencia vaya finalmente al fisco (Modest., D.40.5.12.2).

Por otro de Marco Aurelio (Inst., 3.11), para el caso de que los acreedores de la herencia realicen la *venditio bonorum*.*

5. En la época clásica si se trataba del fideicomiso de libertad de un esclavo ajeno, y el dueño no lo vendiera, el legado se extingue, ya que no es posible reemplazar el cometido por el precio, como en la cosa ajena (Gayo, 2.263; Ulp., 2.11).

Justiniano, siguiendo un rescripto del emperador Alejandro (C.7.4.6), entiende que el fideicomiso no se extingue, sino que su cumplimiento queda diferido, "porque el tiempo puede suministrar ocasión de comprar al esclavo y manumitirlo" (Inst., 2.24.2).

§ 685. IV. *Fideicomiso de familia*. Se podía también establecer la "sustitución fideicomisaria", aunque esta expresión no existe en los textos. Podía ocurrir que se estableciera un fideicomisario sustituto para el caso de que el beneficiario no adquiriera el fideicomiso. Sería un caso de "sustitución fideicomisaria vulgar". Pero también para el supuesto de que el causante establezca el destino del fideicomiso luego de la muerte del beneficiario primero. Así, a diferencia del caso de la herencia, se podía decir, como fideicomiso: "Cuando mi heredero Ticio haya muerto, quiero que mi herencia vaya a Public Mavio" (Gayo, 2.277).

Esta modalidad se empleó al comienzo reducido al fideicomisario para luego de la muerte del heredero. Pero luego se lo amplió para casos posteriores (Modest., D.31.32.6 itp.).

Esto configuró el "fideicomiso de familia" (*fideicommissum familiae relictum*). Consiste en el encargo al heredero de que conservase el patrimonio hereditario, de tal modo que a su muerte fuera dejado a personas pertenecientes a su familia. Al principio, parecía estar limitado a la primera generación, pero luego también, ligando los bienes familiares en un orden sucesivo de generaciones (a lo cual se pueden unir los respectivos beneficiarios continuando la serie). Se solía establecer generalmente con el cargo de no vender los bienes.

1. Este procedimiento fue luego muy usado en la Edad Media y Moderna, determinando el origen del "mayorazgo", es decir que los bienes iban pasando sucesivamente al hijo mayor, quien debía continuar manteniendo el patrimonio familiar.

2. Justiniano limitó estas "sustituciones fideicomisarias" a la cuarta generación (Nov. 159.2, año 535); pero determinó también que el fideicomiso se extingue cuando el penúltimo fideicomisario muere antes de llegar a la pubertad (Nov.11.3).

§ 686. V. *Fideicomiso de residuo*. Esta modalidad consiste en establecer el fideicomiso por lo que quede de la herencia*. Esto se solía usar, p.ej., para dejar que la hija heredera tomara para sí ciertas cosas, confiando en su *fides*, que dejara el resto de la herencia a los hermanos.

Estas disminuciones de la herencia debían respetar la voluntad del testador implicada en el fideicomiso (Ulp., D.36.1.22.4; Pap., D.4.56 y 60.8). También, si el heredero vende alguna cosa y con el producido compra otra, se entiende

que ésta sustituye a la primera ("subrogación real"; Pap., D.31.70.3).

Justiniano fija el límite de disposición del fiduciario en las 3/4 partes, reservando al fideicomisario la cuarta (Nov. 108).

ÍNDICE ALFABÉTICO DE MATERIAS

Cada una de las palabras se refiere al número de párrafo (§). La indicación en negrita señala el lugar principal del tema.

- Abandono noxal: 331.
Abdicatio
liberorum: 511 (C.4);
tutelae: 557.
Acceptilatio: 381, 477.
Accessio (stipulatio): 387 (e).
Accessión
de posesiones para usucapir: 240 (E.2-3);
frutos: 207; modo de adquirir la propiedad: 244 ss.
Accesorios: 207 (a).
Accusatio suspecti tutoris: 566 (A).
Aceptación de la herencia: v. *Aditio hereditatis*.
Actio: concepto: 91; clasificación: 92 ss.; v. *Actiones*;
ad exemplum institoriae actionis: 521;
ad exhibendum: 246, 256 (c);
ad supplendum legitimam: 636;
aquae pluviae arcendae: 234 (5);
arborum furtim caesarum: 347;
auctoritatis: 233 (c), 421;
Calvisiana: 631;
certae creditae pecuniae: 361, 384;
certae rei: 361, 384;
civilis: 117;
incerta: 373;
in personam: 384;
commodati: 366;
communi dividundo: 126, 261;
conducti: 281, 425;
confessoria: 268, 275;
de albo corrupto: 356 (1.a);
de arboribus succisis: 339 (B), 347;
de dolo: 305 (i);
de effusis et deiectis: 357 (B);
de eo quod certo loco: 125 (A.3.iii), 474 (2);
de falso tutore: 566;
de incendio ruina naufragio rate nave expugnata: 346;
de in rem verso: 522;
de modo agri: 236 (c.2); 422;
de pastu pecoris: 347;
de pauperie: 347;
de peculio (et de in rem verso): 522;
de pecunia constituta: 379 (A y B);
depensi: 396;
depositi: 370;
de posito et suspensio: 357 (C);
de recepto (recepticia): 380;
de sepulchro violato: 199 (B), 356;
de servo corrupto: 347 (d), 356 (b);
de sponsu: 528 (a);
de tigno iuncto: 245 (B.a), 339 (1.a);
de turba: 346;
dotis: 541;
empti: 415;
exercitoria: 520;
ex lege: 453;
ex stipulatu: 384;
ex testamento: 658 (B), 658 (D.2);
Fabiana: 631;
familiae erciscundae: 126, 261, 578, 656;
fiduciae: 286;
finium regundorum: 126, 234 (3), 261;
furti: 340-342;
concepti: 339 (a);
manifesti: 337-338;
nec manifesti: 337-338;
non exhibiti furti: 339 (d);
oblatus: 339 (b);
prohibiti furti: 339 (c);
hypothecaria
del legatario: 659 (C.4);
v. *Actio Quasi Serviana*;
in factum (legis Aquiliae): 350;
ingrati: 179;
iniuriarum: 354, 534;
in rem (enfiteuta): 284;
institoria: 521;
quasi institoria: 521;
respecto de la intercessio: 402;
iudicati: 123, 145;
kalendarii: 362;
legis Aquiliae: 123, 350 (I);
in factum: 350 (II);
legis Laetoriae: 575 (A);
locati: 425;
mandati: 442;
momentariae possessionis (interdictum): 220 (3.d);
negatoria: 257;
negotiorum gestorum (directa y contraria): 448;
operarum: 404;
Pauliana: 467-468;
pignoratitia: 290 (A);
praescriptis verbis: 374;
pro socio: 437;
protutela: 566;
Publiciana in rem: 255;
utilis: 255;

quanti minoris: 422 (A);
 quasi Serviana: 291 (d);
 quod iussu: 519;
 quod metus causa: 306 (c.1);
 rationibus distrahendis: 566 (B);
 recepticia: 380;
 redditoria: 422 (A);
 rei uxoriae: 540 (c.1), 541 (B);
 rerum amotarum: 540 (c.2);
 restitutoria: 402;
 Rutiliana: 147;
 sepulchri violati: v. *Actio de sepulchro violato*;
 Serviana: 291 (c);
 utilis: 291 (d);
 subsidiaria (tutela): 567 (c);
 tributaria: 523;
 triticaria: 384;
 tutelae (directa-contraria): 566 (C);
 venditi: 415;
 vi bonorum raptorum: 345.

Acciones
 adiecticiae qualitatis: 518, 524;
 arbitrarie: v. *Formula arbitraria*;
 bonae fidei: v. *Bonae fidei iudicia*;
 civiles: v. *Formula in ius concepta*;
 ficticiae: v. *Formula ficticia*;
 honorariae: v. *Actiones in factum*;
 in factum (lex Aquilia): 350;
 (de effusis et deiectionis): 357;
 (de posito et suspensio): 357;
 (juez que hace suya la causa): 357;
 v. *Formula in factum*;
 in personam: 92(b);
 litis contestatio: 120 (1);
 in rem: 92(a), 120 (1);
 scriptae: 92(b.6);
 mixtae: 93 (c);
 noxales: 168;
 perpetuas: 94;
 poenales: 93 (b), 330;
 populares:
 reipersecutorias: 93(a);
 stricti iuris: v. *Formula in ius concepta*;
 temporales: 94;
 utiles: 136;
 adrogatio: 506 (c.f.f.a);
 (interdictos): 220;
 legis Aquiliae: 356;
 manus: 512;
 superflua: 281 (c);
 transmisión de créditos: 495.

Acrescentamiento
 entre coherederos: 645;
 entre colegatarios: 662.

Acreeedor pignoraticio (como possessor): 213 (B.ii).

Actos ad emulationem: 224 (2).

Actos jurídicos: 298;
 v. *Negocio jurídico*.

Actus servidumbre: 265 (A.ii).

Acneducto: 265 (A).

Addictio
 addicti: 180 (B);
 (in iure cessio): 237.

Aditio hereditatis: 640 ss;

época de Justiniano: 643;
 requisitos: 642.

Adiudicatio: 126, 261.

Adiunctio: 246 (a).

Adoptio: 505, 508;
 hereditaria: 507;
 plena y minus plena: 508 (b).

Adplumbatio: 246.

Adquisición de frutos: 207.

Adquisición de la herencia: 643 ss.

Adrogatio: 506.

Adsertor libertatis (liberalis causa): 167 (e.1.2);
 manumisión per viandam: 174 (A).

Adsignatio
 de tierras públicas: 235 (A.b);
 libertas: 608 (D).

Adstipulatio: 393;
 lex Aquilia: 348.

Adulterio: 534 (A.e).

Aequitas
 concepto: 82 (b);
 v. *Bonae fidei iudicia*.

Aerarium: 189, 654 (C.1).

Aes alienum: 359.

Aestimatum: 375 (B).

Affectio maritalis: 527 (a), 529 (C), 549.

Afinidad: 531 (c);
 v. *Parentesco*.

Ager
 arcifinius-limitatus: 234 (3), 243 (I.A.2, y C.1),
 244;
 publicus: stipendiarius; tributarius: 229;
 vectigalis: 283.

Agere
 cum compensatione: 483 (b);
 cum deductione: 483 (c).

Agnación (adgnatio): 499, 578, 582;
 agnado próximo: 584.

Aguas de lluvia: 234 (5).

Album iudicum: 119.

Alieni iuris: 498;
 relaciones patrimoniales con el pater: 516;
 v. *Peculios y Acciones adiecticiae qualitatis*.

Aluvión (alluvio): 243 (I.A).

Alteri stipulari non potest: 388 (II).

Alveus derelictus: 290, 243 (C).

Anatocismo: 362.

Animus: 211;
 domini: 210 (2);
 donandi: 451;
 furandi: 335;
 iniuriae faciendae: 353;
 locandi: 333;
 lucri faciendi o lucrandi: 336;
 novandi: 480 (e);
 rem sibi habendi (possidendi): 210 (2);
 revertendi: 212 (2), 242 (I).

Anticresis: 288.

Antiphrasa: 543.

Anulabilidad (actos jurídicos): 315.

Apelación: 155.

Apertura del testamento: 626.

Aquae ductus: 265 (A);
 aquae haustus: 265 (A.2).

Arbitraje (procedimiento arbitral): 157.

Arbiter: 103.

Arboles en los límites del vecino: 234 (2), 347.

Argentarii: 280 (1), 321, 360, 405 (6), 406 (2), 483 (b);
 receptum: 380.

Arras (arrhas)
 compraventa: 417;
 sponsaliciae: 528 (c).

Arrendamiento: v. *Locación*.

Asunción de deudas: 497.

Auctoratus: 180 (D).

Auctoritas
 del Senado: 17 (b), 38;
 del tutor: 563 (B), 564;
 de los iurisperdentes: 45.

Audientia: 153 (1);
 episcopalis audientia: 157.

Ausencia: 162 (2).

Autonomía de la voluntad: 325 (C.7).

Aversio: v. *Mezcla*.

Avulsio (avulsión): 243 (B).

B

Banquero; ver *Argentarius*.

Basilicas: 65.

Beneficio (beneficium): 85 (2);
 competencia: 433, 437, 471 (b.1);
 de ceder acciones: 295 (C.2.b), 401, 541 (B);
 de excusión: 295 (C.2.c), 401;
 de inventario: 643, 649;
 de separación de patrimonios: 638, 648;
 divisionis: 401.

Bona
 adventicia: 517 (B.c).
 caduca: 532 (c);
 materna: 517 (D);
 parafernales: 537;
 (patronato): 178 (c);
 vacantes: 650.

Bona fides: 411, 434.

Bonae fidei iudicia: 137, 411, 412, 461.

Bonorum emptor: 147 (c), 466, 483.

Bonorum possessio: 580;
 contra tabulas: 580 (B.b), 631;
 cum re y sine re: 580 (A.c), 595;
 decretales: 580 (B.ii); 596;
 edictalis: 580 (B.i); 587;
 furiosi nomine: 596 (c);
 intestati: 580 (B.c); 586 ss.;
 secundum tabulas: 580, 617, 624.

Bonum et aequum: 357;
 v. *Bonae fidei iudicia*.

C

Cadacum (caduca): 532 (c).

Caelibes: 532.

Cancillería imperial
 época de Augusto: 22 (2);
 época de Adriano: 49 (4), 51(2), 53.

Capandad
 (de derecho): 187;
 (de obrar): 187;

procesal: 116 (2).

Capiones mortis causa: 456 (C).

Capitis deminutio
 concepto y clases: 163;
 forma extintiva de la patria potestas: 510;
 forma extintiva de una obligación: 491.

Captivus redemptus: v. *Redemptus ab hostibus*.

Castrados: 529 (C.3).

Caso fortuito (casus): 462 (III);
 maior: 365, 461;
 minor: 365, 461.

Caupones: 339, 357 (D), 380.

Causa
 de esclavitud: 165, 176 (A.iii.1);
 donationis: 450 (B);
 in causa mancipi: 180 (A);
 liberalis causa: 167 (e.1.2);
 perpetua (servidumbres): 264 (D);
 posesión: 210 (4);
 tradición: 238 (c; d);
 usucapio: 240 (B).

Causa Curiana: 302 (2).

Cautio
 damni infecti: 234 (6);
 de non amplius turbando: 268;
 dominum rem ratam habiturum (cautio de rato):
 114;
 iudicatum solvi: 113 (2), 114;
 iudicio sisti: 152;
 legatorum servandorum causa: 658 (B.3);
 Muciana: 308;
 pro praede litis et vindictarum: 101;
 rei uxoriae: 541 (A);
 rem pupilli salvam fore: 562;
 stipulatio: 382;
 tutor: 562 (B);
 usufructuaria: 275;
 vadimonium sisti: 111.

Cautividad en poder del enemigo: 545;
 v. *Postliminium y Fictio legis Corneliae*.

Caza
 (occupatio): 242 (I).

Cenáculo (coenaculum): 281 (b.3).

Censo: 5;
 manumisión por censo: 174 (B).

Censor: 12 (2).

Centunviro: 119 (c).

Cessio bonorum: 145, 158 (4).

Chirographum: 407.

Circumambulatio: 210, 238.

Ciudadanos romanos: 182;
 (adquisición y pérdida de la ciudadanía romana):
 183.

Civitas
 (civitates): 191;
 (libre): 185;
 (quiritaria): 3, 161.

Cláusula
 codicilar: 627 (c.1);
 doli: 305;
 penal: 338, 392.

Cientes: 4 (b).

Codex accepti et expensi: 405.

Codicilos (codicilli): 627;

ab intestato: 628;
confirmados por testamento: 628;
no confirmados por testamento: 628.
Codificación: 59 ss.
Código
de Justiniano: 64 (I).
Gregoriano: 59 (A);
Hermogeniano: 59 (B);
Theodosiano: 59 (C).
Coemptio
fiduciae causa: 513 (C.2), 571;
matrimonii: 513 (C).
Coercitio (magistrados): 11 (a.1).
Cognados: 499, 578;
cognatio servilis: 167 (f), 551,
herencia: 597;
narratio unde cognati: 593.
Cognitio: v. *Extra ordinem*.
Cognitor: 113.
Coherederos (coniunctum, disiunctum): 645,
v. *Acrecentamiento*.
Colación de bienes (collatio bonorum): 589;
de dote: 590.
Colegarios (coniunctum y disiunctum): 662.
Colegios sacerdotales: 3 (d).
Collegium: 192.
Colonia partiana: 427 (2).
Colono (colonato): 180 (E).
Comicios
adrogatio: 506 (a);
calados: 3 (c), 615;
centuriados (aparición): 6 (c), 15 (b);
curiados: 3 (c), 15 (a);
elección magistrados: 11 (b);
tribados: 15 (c).
Comentaristas, escuela de: 68.
Commercium (ius commercii): 182, 184.
Communio pro indiviso: 248, 437.
Comodato: 364 ss.;
actio commodati: 366;
obligaciones del comodatario: 365.
Compenación: 482 ss.;
evolución: 463;
reforma de Marco Aurelio: 484,
reformas de Justiniano: 485.
Competencia jurisdiccional: 116 (I).
Compraventa: 414;
acciones: 415;
arras: 417;
consentimiento: 416;
cosas que pueden ser compradas y vendidas: 419;
evolución en Roma: 413;
garantía de evicción: 421;
pactos agregados: 423;
precio: 418;
riesgos de la cosa: 420;
vicios redhibitorios: 422.
Compromissum: 157 (1).
Comunidad de herederos: 644;
v. *Erectum non cito*.
Concepción en iustae nuptiae: 504,
v. *Nasciturus*.
Concesión de ciudadanía: 183 (II);
v. *Constitutio Antoniniana*.

Concubinato: 549.
Concurso de causas (lucrativas): 490.
Condemnatio: 125;
particularidades: 128.
Condición: 307 ss.;
clasificaciones: 308;
efectos: 309.
Condictio (legis actio): 104;
causa (rem) data causa non secuta: 373, 374;
certae creditae pecuniae: 361, 384;
certae rei: 361, 384;
ex lege: 376, 454;
ex poenitentia: 374 (c);
furtiva: 377, 342;
generalis: 376;
incerti: 384;
indebita: 376 (A);
ob causam finitam: 376 (C);
ob rem datam re non secuta: v. 373, 374;
ob turpem (vel iniustam) causam: 376 (B);
sine causa: 376 (C.2-3);
lriticaria: 361.
Condominio: 259;
partición: 261;
vida jurídica: 260;
v. *Communio pro indiviso*.
Conductio vectigalis: 253 (b).
Confarreatio: 513 (b).
Confesión: 106;
in iure: 117, 153.
Confessus pro veritate habetur: 117 (I).
Confusión
como extinción de una obligación: 489;
dominio: 248;
Comixción: 248.
Comorientes: 162 (1).
Consecratio: 199 (A.b).
Consentimiento (consensus)
consentimiento contrario: 411 (C), 488;
consentimiento de los contrayentes para casarse:
529 (C);
de los padres para casar a sus hijos: 529 (D);
v. *Contratos consensuales*.
Consilium
amicorum: 548 (2);
de juristas (Hadriano): 49 (4), 150;
fraudis: 467 (b);
para manumitir: 176 (A.i; iii,1).
Consolidatio: 274.
Consortium: 433-434, 436.
Constantino: 25, 54.
Constitución imperial (constitutio Principis): 52.
Constitutio
Antoniniana: 183 (II), 185 (3);
Rutiliana: 240 (A.iii,1).
Constitutum
debiti alieni: 379 (B), 497 (c);
debiti proprii: 379 (A).
Constitutum possessorium: 212 (b), 238 (d.3).
Cónsules: 12 (1.d).
Contra bonos mores: 353, 376 (B, 441 (a), 528 (b)).
Contractus donationum: 453 (B.b).
Contractus emphyteusos: 284.
Contrarius consensus: 488.
Contratos: 326;
consensuales: 410 ss.;
innominados: 374;
literales: 495 ss.;
reales: 358 ss.;
verbales: 381 ss.
Contubernium: 167, 551.
Contumacia: v. *Indefensus*.
Convivium: 529, 550.
Convención (conventio): 325.
Convento in manu: v. *Manus*.
Cónyuge superviviente: 594, 607 (A).
Coproiedad: v. *Condominio*.
Corporación: 607;
v. *Personas jurídicas*.
Corpus (posesión): 210 (1).
Corpus Iuris Civilis: 61 ss.; 64 ss.
Correalidad: v. *Obligaciones correales*.
Cosa juzgada: v. *Res iudicata*.
Cosas: v. *Res*.
Cretio: 640 (II);
clases: 641.
Crimen: 329;
expilatae hereditatis: 650;
suspecti tutoris: 566.
Cuasicontratos: v. *Quasi ex contractu*.
Cuasidelitos: v. *Quasi ex delicto*.
Cuasiposesión: v. *Quasi possessio*.
Cuestor: 12 (1.a).
Culpa: 462 (II);
lata, in abstracto, in concreto: 462;
levissima: 350, 462.
Curatela: 572 ss.;
especiales: 576;
furiosi: 573;
menores: 575;
pródigos: 574.
Curator
bonorum: 147, 149;
especial: 576;
ventris: 160, 576 (b); 596 (b).
Cursus honorum (magistrados): 12.
Custodia: 365, 372, 427 (b), 432, 437, 461.

D
Dación de la herencia: v. *Herencia*.
Dación de la tutela: v. *Tutela*.
Dammum emergens (daño emergente): 460 (C).
Dammum infectum: 110, 234.
Dammum iniuria datum: 347 ss.
Daños causados por animales: v. *Actio de pastu pe-*
coris.
Dare, datio: 318.
Dare actionem: 115 118.
Datio in solutio: 471 (a).
Dationes
ex eventu: 377;
ob causam: 376;
ob rem: 373.
Debitum: 317.
Decemviri litibus iudicandis: 119 (d).
Decenviros: 13 (h.2).
Decretum de iudicium dare: 118.

Dedicatio: 199 (A.b).
Dedictio: v. *Peregrinos*.
Deductio in domum mariti: 527, 530.
Deductio
servitutis: 266 (2);
usufructus: 272.
Defensor civitatis: 149 (4.a), 560.
Deiectum vel effusum: 357.
Delegatio: 480, 493 (a).
Delito (delictum): 328, 329;
delitos pretorianos: 356.
Demandado
infinitas: 93(c), 122 (1.a), 145;
posiciones que puede asumir: 117.
Demonstratio: 125.
Denegatio actionis: 118.
Denuntiatio: 496.
Deportatio in insulam: 183 (III.2), 185, 502, 546.
Depósito: 367 ss.;
actio depositi: 370;
contenido: 368;
irregular: 369 (B);
necesario: 369 (A);
secuestro: 369 (C).
Derecho Romano: 27;
antiguo: 29;
clásico: 39, 47, 51;
Derecho objetivo y subjetivo: 79-80, 90, 263;
en Oriente después de Justiniano: 65;
en la Argentina: 74;
etapas: 28;
etimología: 77;
posclásico: 54;
situación actual del: 73;
Vulgar: 55;
Derelictio: 197, 242.
Desheredación: 629;
por ingratitud: 636.
Diarquia: 22.
Dictator: 13 (a).
Dictio dotis: 403, 539 (b).
Dies interpellat pro homine: 463.
Dies cedens; veniens: 661, 669.
Diffarreatio: 513 (B.3).
Digesto de Justiniano: 64 (II).
Diligens paterfamilias: 365, 372, 442, 462.
Diligentia: 365, 372, 442, 448, 462.
Dioleciano: 24, 54.
Dioses Manes: 199 (B.1).
Distractio bonorum: 149, 158 (3).
Divisio inter liberos: 656 (1).
Divorcio: 548; (Justiniano):
bona gratia: 548 (E.3),
communis consensu: 548 (E.c);
ex iusta causa: 548 (E.a);
sine causa: 548 (E.b).
Dolo
incumplimiento doloso de una obligación: 462 (II);
vicio de la voluntad: 305.
Domio: 24-26.
Dominium (propiedad): 222-223;
ad tempus: 226;
caracteres: 224;
ex iure Quiritium: 227;

- in bonis habere: 228;
limitaciones: 232;
propiedad peregrina: 230;
propiedad provincial: 229.
Donación: 450 ss.;
ante nuptias (propter nuptias): 643;
donaciones matrimoniales: 542 ss.;
donatio sub modo: 388, 455;
inter vivos: 451 ss.;
limitaciones: 452;
mortis causa: 456;
revocación: 454.
Dos praelegata: 541 (B.2), 680 (C.1).
Dote: 538 ss.;
constitución: 539;
régimen jurídico al disolverse el matrimonio: 541;
régimen jurídico durante el matrimonio: 540;
retenciones: 541.
Dotis datio: 539.
Dotis dictio v. *Dictio dotis*.
Duo rei stipulandi (duo rei promittendi): 389;
v. *Stipulatio solidaria*.
Duplicatio: 132 (4).
Duumviri iure dicundo: 150.4.

E

- Ecloga legum: 65.
Ecclesia (obispos, monjes y clérigos):
arbitraje: 157;
colonos: 180 (E.1);
excluidos de la patria potestas: 510 (4);
excusaciones, tutela: 561 (C);
fundaciones piae causae: 193 (3-4);
manumisión (in ecclesia): 174 (D);
prescripción, acciones: 94 (5);
San Ambrosio: 26;
sucesión clérigos: 607 (C.a);
testamento, formas: 619 (II.4);
usufructo: 240 (A.iv);
venta de cosas sagradas: 199 (A.b).
Edad: 187 (A).
Edere actionem (editio actionis): 111, 115.
Edicto
Carboniano: 596;
clases: 42;
de alterutro: 541 (B.2), 541 (C.7);
de aquaeductu Venafrano: 233 (2);
de feris: 356;
de los magistrados: 41;
importancia del edicto del pretor: 43;
Perpetuo: 51 (2).
Edictum Theodorici: 60 (III).
Edificación (Inaedificatio): 245 (E).
Edificio que amenaza ruina: 234 (6).
Edil: 12 (1.b).
Ejecución
en el procedimiento extra ordinem: 153;
en el procedimiento formulario: 145 ss.;
en las legis actiones: 105-107.
Emancipatio (emancipación): 511;
Anastasiana: 511 (A y B.2);
Justiniana: 511 (A).
Emperadores, dinastías: 23.

- Emptio spei; emptio rei speratae: 419 (3).
Emptio venditio: v. *Compraventa*.
Endoploratio: 338.
Enfiteusis: 283-284.
Enriquecimiento (sin causa): 522.
Epanagogue: 65.
Episcopalis audientia: 157 (2).
Erectum non cito: 433.
Error: 304;
de derecho y de hecho: 304;
in corpore: 304 (III.i);
in negotio: 304 (I);
in persona: 304 (II);
in qualitate: 304 (III.iii);
in substantia: 304 (III.ii);
respecto de la cosa: 304 (III).
Erroris causa probatio: 503 (c).
Esclavo (servus): 159 bis; 165-167;
causas de esclavitud: 168;
condición jurídica: 166;
esclavo fugitivo: 211 (3);
peculio: 167;
servi poenae: 172;
servus publicus: 166.
Escuelas
de Derecho: 56;
del Derecho Natural: 70;
de los Comentaristas: 68;
de los Glosadores: 67;
histórica: 71;
humanista: 69;
(Proculeyanos-Sabinianos): 60.
Especificación: 247.
Esponsales (sponsalia): 528.
Estipulación: v. *Stipulatio*.
Equidad: v. *Aequitas*.
Evicción (evictio): 421.
Exauguratio: 199 (A.b.2).
Excepción (exceptio): 117, 132;
clasificación: 133;
doli generalis y doli specialis: 305 (ii);
doli mali: 305 (ii): 385;
iusti domini: 255;
legis Cinciae: 452;
legis Laetoriae: 575 (B.a);
merci non traditae: 415;
non adimpleti contractus: 415;
non numeratae pecuniae: 386, 408;
pacti conventi: 132 (4), 133, 486;
quod metus causa: 306 (c.2);
rei donatae et traditae: 452;
rei iudicatae vel in iudicio deductae: 120, 124;
rei venditae et traditae: 255.
s.c. Macedoniani: 363;
s.c. Velleiani: 402; 561;
vitiosae possessionis: 217 (2-3), 218 (1), 219 (A.3), 220.
Excusación (tutor): 561.
Executores: 152, 159.
Exercitor navis: ver *Actio exercitoria*.
Exheredatio: v. *Exhereditatio*.
Expensilatio: 405, 406.
Exposición del hijo: v. *Ius exponendi*.
Expromissio: 480.

- Expropiación: 233.
Extinción de las obligaciones: 469 ss.;
clasificación de los casos: 469.
Extra ordinem cognitio: 150;
apelación: 156;
características: 151;
marcha del procedimiento: 152;
pruebas: 154;
sentencia: 155;
vías de ejecución: 158.
F
Facere: 318.
Falsus tutor: 566.
Familia, concepto: 498 ss.;
de esclavos: 339;
de publicanos: 339.
Familiae emptor: 616.
Fas: 81, 531 (a y c.1).
Favor
libertatis: 100, 168 (I);
testamenti: 621 (II.1).
Fenus nauticum: 362.
Ferruminatio: 246 (b).
Festuca: 100, 174 (A).
Fianza: v. *Sponsio*; *Fideipromissio*; *Fideiussio*.
Fictio legis Corneliae: 171.
Fictus possessor: 251.
Fideicomiso: 674 ss.;
concepto: 674;
de cosas singulares: 674, 682;
de familia: 685;
de herencia: 674, 677;
de libertad: 684;
de residuo: 686;
evolución de los fideicomisos: 675;
régimen de los fideicomisos: 676.
Fideiussio: 397;
efectos: 398;
en la época de Justiniano: 401;
indemnitas: 399 (A.2);
relación entre el acreedor y los obligados: 399;
relación entre el deudor y los fideiussores: 399.
Fideipromissio: 394.
Fides
clientes: 4 (b.1);
fideicomisos: 674 ss.;
patrono: 179;
sociedad: 434;
sponsio: 381 (4);
stipulatio: 381 (3);
usufructo: 240 (C);
v. *Bona fides*.
Fiducia
cum amico: 363 (1);
cum creditore: 286.
Filosofía (influjo)
Iluminismo: 73, 90;
ius naturale: 38;
primeros filósofos: 47;
respecto de cosa: 194;
respecto de fuentes de las obligaciones: 324;
respecto de res incorporales: 195;
respecto de sujeto de derecho: 159 bis;
respecto de la especificación: 247.
Fiscus: 190, 293.
Flamines Dialis
adrogatio: 510 (4);
conferreatio: 513 (B).
Flumina: 200.
Fórmula: 108, 124 ss.;
arbitraria: 133 (A);
con trasposición de personas: 138 (B), 147;
ficticia: 136;
adrogatio: 506;
legis Aquiliae: 350;
manus: 512;
in factum concepta: 135;
in ius concepta: 134;
Octaviana: v. *Actio quod metus causa*;
partes: 124 ss.
Fraude (manumisión): 176 (A.iii.3);
en perjuicio de los acreedores: 466-467.
Fructus licitatio: 141 (3.a).
Frutos: 207 (d);
caídos en el fundo vecino: 234 (1);
en la rei vindicatio: 254 (2).
Fuerza mayor: v. *Casus*.
Fundaciones: 193;
v. *Piae causae*.
Fundos stipendiarios y tributarios: 229;
v. *Provincias*.
Furiosus: 187 (C), 529;
bonorum possessio: 596 (c);
curatela: 573.
Furtum: 332 ss.;
acciones: 333-339;
animus furandi: 335;
animus lucri faciendi: 336 (1);
clases: manifestum-nec manifestum: 337-338;
conceptum: 339 (a);
ejercicio de la actio furti: 340-342;
formas de comisión (furtum rei, furtum usus, furtum possessionis): 333;
obligatum: 339 (b);
sobre qué cosas puede recaer: 334.

G

- Garantías personales: v. *Fideipromissio*; *Fideiussio*;
Sponsio.
Garantías reales: v. *Hipoteca*; *Pignus*; *Prenda*.
Gastos hechos en la cosa: v. *Impensae*.
Gens (gentiles): 2, 585;
patres gentis: 3(b).
Gestio (tutor): 563 (A);
herencia: v. *Pro herede gestio*.
Gestión de negocios: 446.
Glosadores, escuela de los: 67.

H

- Habere licere: 414;
stipulatio de: 421.
Habitatio (habitación): 277.
Hechos jurídicos: 298;
v. *Negociis jurídicos*.
Heredis institutio (institución de heredero): 621.

- Herencia (hereditas)
 ab intestato: 581 ss.;
 adquisición: 636 ss.;
 conceptor: 579;
 dañosa (damnosa): 579;
 del liberto ciudadano romano: 608;
 del liberto latino iuniano: 609;
 de los libertos dedictos: 610;
 de un filiusfamiliae: 613;
 evolución histórica: 578;
 testamentaria: 614 ss.;
 yacente: 650.
 Hereditas yacens (herencia vacante): 650.
 Hereditatis petitio: 654.
 Herederos: 579;
 ex re carta: 621;
 extraños: 639; suyos y necesarios (sui heredes): 583, 638;
 necesarios: 637;
 protección del heredero: 653 ss.;
 situación del heredero después de aceptar la herencia: 644.
 Hermanos: germani, unilaterales: 604, 505.
 Hexabiblos: 65.
 Hijos
 adoptivos: 506, 508;
 legitimados: 509;
 legitim, spurii, vulgo concepti, obscuro loco nati: 504 (2);
 naturales: 504 (2), 509, 549, 607 (B);
 póstumos: 620.
 Humanitas: 354, 446 (1), 471 (b); 506 (b.iv), 634 (2).
 Honor: 159;
 (liber bona fidei serviens): 165 (2);
 sacer: 199 (A).
 Honor: v. *Infamia*.
 Honorarium
 en el mandato: 440 (B);
 profesiones liberales: 432 (2).
 Hyperocha: 290 (4), 296 (c).
 Hypotheca: 291 ss.;
 características: 292;
 casos especiales: 294;
 derechos del acreedor hipotecario: 295;
 extinción: 296;
 hipotecas tácitas y legales: 293.
- I
- Impedimentos matrimoniales: 531.
 Impensae (rei vindictio): 254 (c).
 Imperium
 magistrados: 11 (a.1);
 proconsulare maius et infinitum: 21 (b).
 Impubes: 187 (A.b);
 adrogatio: 506 (b.ii);
 pubertati proximi: 187 (A.b);
 ver *Púberes*.
 In bonis habere: 228.
 In causa mancipi: v. *Mancipium*.
 Indefensus: 111, 117.
 In diem addictio: v. *Compraventa; Pacta adiecta*.
 Indignus: 624, 634.
 de los legados: 667.
 Ineficacia de los testamentos: 623 (B).
 Infamia: 123 (1.3), 187 (D), 354.
 Infantes: 187 (A.a);
 (infantiae proximi): 187.
 Infundando lis crescit in duplum: v. *Demandado infundans*.
 Ingenuos: 164;
 herencia de un ingenuo emancipado: 612.
 in integrum restitutio: 142, 466 (a-b);
 (menores): 575 (B.b);
 (pupilo): 567 (d).
 In iure cessio: 237;
 hereditatis: 652.
 Iniuria: 351 ss.;
 atrox iniuria: 354;
 penas: 354.
 In ius vocatio
 legis acciones: 98;
 procedimiento formulario: 111.
 Infuria (infuria); distintos significados: 351.
 In mancipio (in causa mancipi): 180 (A).
 Inmissio (de humo y otras emanaciones): 234 (4).
 Insinuatio: 258, 453, 544 (3).
 Institor: v. *Actio institoria*.
 Institución de heredero: v. *Heredis institutio*.
 Institutas
 de Gayo: 50;
 de Justiniano: 64 (III).
 Instrumenta
 domus: 201 (c);
 dotalia: 530; 539;
 fundi: 201 (c).
 Incentio: 126;
 errores en la intentio: 127.
 Intercessio
 garantía: 402;
 magistrados: 11 (c).
 Interdictos: 139 ss.;
 clases: 140;
 dobles: 216;
 posesorios: 214 ss.;
 procedimientos: 141.
 Interdictio (aquae et ignis): 183 (III.1), 185, 199;
 época justiniana: 220; pródigo: 574.
 Interdictum
 de arboribus caedendis: 234 (2);
 de aqua: 268;
 de clandestina possessione: 219 (D);
 de glande legeada: 234 (1);
 de itinere actuque privato: 268;
 de libris exhibendis et ducendis: 334 (2), 502 (c);
 demolitorium: v. *interdictum ex operis novi nuntiatione*;
 de preario: 219 (C);
 de superficie: 281 (b);
 de uxore exhibenda et ducenda: 534 (A.e.2);
 de vi armata: 219;
 ex operis novi nuntiatione: 234 (7);
 fraudatorium: 466 (b);
 quam hereditatem: 655;
 quam servitutem: 268;
 quem fundum: 256 (A);
 quem usufructum: 275;
 quod legatorum: 580, 661 (D.1);
 quod vi aut clam: 235;
 quorum honorum: 655;
 Salvianum: 291 (b);
 unde vi: 219 (A), 220;
 unde vi armata: 219 (B), 220;
 utilis: 467 (c.1);
 uti possidetis: 217, 220;
 utrobi: 218, 220.
 Intereses (usurae): 207 (d.1), 362.
 Interpellatio: 463.
 Interpretatio (interpretación)
 Pontifices: 32; prudentes: 44.
 Interregnum: 3 (b.1), 12 (1.e), 17 (3).
 Interrogatio in iure: 116 (3), 152.
 Interpolaciones: 62.
 Intra vires hereditatis: 649 (1).
 Invetcae et illatae: 207 (c), 291 (a).
 Inventario (tutor): 562 (A).
 Isla (insula)
 in flumine nata: 243 (D);
 in mari nata: 242 (IV).
 Iter: 265;
 ad hauriendum: 265 (A.i);
 ad sepulchrum: 199 (B).
 Iudex: 119 (a);
 iudices dati y pedanei: 150 (4.b);
 tarea del: 121.
 Iudicatus: 105.
 Iudicem dare: 118.
 Iudicia
 imperio continens: 110;
 legitima: 109.
 Iudicis (vel arbitris) postulatio: 103.
 Iudicium
 calumniae: 118 (2), 123 (c);
 contrarium: 123 (1.d);
 dare: 118;
 domesticum: 502.
 iura in re aliena: 262 ss.
 iura praediorum: v. *Servidumbres*.
 Iuridici: 119 (c).
 Iurisdicatio: 91, 116.
 Iurisprudentes: 44-45;
 v. *Juristas*.
 Iurisprudentia; definición: 82 (d).
 Ius: 29;
 abutendi: 224 (3), 270 (A);
 abstinendi: 638 (B-C);
 adscrescendi: 645;
 Aelianum (Tripartitum): 32;
 agendi cum patribus, magistrados: 11 (a.2), 17 (b);
 agendi cum populo, magistrados: 11 (a.2);
 altius non tollendi: 265 (B.iv);
 aureorum annulorum: 177 (A.2);
 auspiciorum (maiorum; minorum), magistrados: 11 (a.3);
 capiendi: 620 (III);
 civile: 86;
 clasificaciones: 83 ss.;
 commercii
 ciudadanos romanos: 182;
 (libertos ciudadanos romanos): 177 (A);
 (libertos Latinos iunianos): 177 (B);
 commune: 85;
 conubii
 ciudadanos romanos: 182;
 (libertos ciudadanos romanos): 177 (A);
 distintas acepciones: 78;
 diversos empleos: 79-80;
 edicendi, magistrados: 11 (a.2), 41;
 emphiteuticarium: 233;
 etimología: 76;
 exponendi: 502 (b);
 Flavianum: 32;
 fluminis: 265 (B.v);
 gentium: 87-88;
 honorarium: 43, 89;
 honorum
 ciudadanos romanos: 182;
 libertos ciudadanos romanos: 177 (A);
 in agro vectigale: 263;
 liberorum: 532 (b); 571, 608;
 luminum: 265 (B.iv);
 maius Latium; minus Latium: 184 (B.4);
 naturale: 87-88;
 ne prospectui vel luminibus officiat: 265 (B.iv);
 offerendi et succedendi: 295 (B.ii);
 v. *Successio in locum*;
 oneris ferendi: 265;
 Papirianum: 30;
 pascendi: 266 (A.2);
 perpetuum: 283;
 persequendi: 295 (C);
 postliminii: v. *Postliminium*;
 praetorium; v. *Ius honorarium*;
 praefendi (acreedor hipotecario): 295 (B);
 del pupilo: 567 (a);
 privatum: 83;
 prohibendi: 260 (B);
 prociendi: 265;
 publice respondendi: 49;
 publicum: 83-84;
 sepulchri: 199;
 singulare: 85 (2);
 stillicidii: 265 (B.v);
 sufragii
 ciudadanos romanos: 182;
 libertos ciudadanos romanos: 177 (A);
 tigni immittendi: 265;
 vendendi (hijo): 502 (c);
 para adoptar: 508 (1-2);
 para emancipar: 511;
 vitae necisque: 502 (a).
 Iusiurandum: 117, 152;
 in iure; in item: 117, 123;
 liberti: 404;
 necessarium, voluntarium: 117, 123 (1.e);
 (non) calumniae: 118 (2), 153 (1).
 Iustitia, definición: 82 (a).
 Iusta causa: v. *Causa*.

Juez que hace suya la causa: 357 (A);
 v. *Iudex*.
 Juicio de Dios (sacramentum): 101.

in bonis habere: 228;
limitaciones: 232;
propiedad peregrina: 230;
propiedad provincial: 229.
Donación: 450 ss.;
ante nuptias (propter nuptias): 543;
donaciones matrimoniales: 542 ss.;
donatio sub modo: 388, 455;
inter vivos: 451 ss.;
limitaciones: 452;
mortis causa: 456;
revocación: 454.
Dos praelegata: 541 (B.2), 660 (C.1).
Dote: 538 ss.;
constitución: 539;
régimen jurídico al disolverse el matrimonio: 541;
régimen jurídico durante el matrimonio: 540;
retenciones: 541.
Dotis datio: 539.
Dotis dictio v. *Dictio dotis*.
Duo rei stipulandi (duo rei promittendi): 389;
v. *Stipulatio solidaria*.
Duplicatio: 132 (4).
Duumviri iure dicundo: 150.4.

E

Edoia legum: 65.
Ecclesia (obispos, monjes y clérigos):
arbitraje: 157;
colonos: 180 (E.1);
excluidos de la patria potestas: 510 (4);
excusaciones, tutela: 561 (C);
fundaciones piae causae: 193 (3-4);
manumisión (in ecclesia): 174 (D);
prescripción, acciones: 94 (5);
San Ambrosio: 26;
sucesión clérigos: 607 (C.a);
testamento, formas: 619 (II.4);
usufructo: 240 (A.iv);
venta de cosas sagradas: 199 (A.b).
Edad: 187 (A).
Edere actionem (editio actionis): 111, 115.
Edicto
Carboniano: 596;
clases: 42;
de alterutro: 541 (B.2), 541 (C.7);
de aquaeductu Venafrano: 233 (2);
de fidei: 356;
de los magistrados: 41;
importancia del edicto del pretor: 43;
Perpetuo: 51 (2).
Edictum Theodorici: 60 (III).
Edificación (inaedificatio): 245 (E).
Edificio que amenaza ruina: 234 (6).
Edil: 12 (I.b).
Ejecución
en el procedimiento extra ordinem: 158;
en el procedimiento formulario: 145 ss.;
en las legis acciones: 105-107.
Emancipatio (emancipación): 511;
Anastasio: 511 (A y B.2);
Justiniano: 511 (A).
Emperadores, dinastías: 23.

Emptio spei; emptio rei speratae: 419 (3).
Emptio venditio: v. *Compraventa*.
Endoploratio: 338.
Enitatus: 283-284.
Enriquecimiento (sin causa): 522.
Epanagogue: 65.
Episcopalis audientia: 157 (2).
Erctum non cito: 433.
Error: 304;
de derecho y de hecho: 304;
in corpore: 304 (III.i);
in negotio: 304 (I);
in persona: 304 (II);
in qualitate: 304 (III.iii);
in substantia: 304 (III.ii);
respecto de la cosa: 304 (III).
Erroris causa probatio: 503 (c).
Esclavo (servus): 159 bis, 165-167;
causas de esclavitud: 168;
condición jurídica: 168;
esclavo fugitivo: 211 (3);
peculio: 167;
servi poenae: 172;
servus publicus: 166.
Escuelas
de Derecho: 56;
del Derecho Natural: 70;
de los Comentaristas: 68;
de los Glosadores: 67;
histórica: 71;
humanista: 69;
(Proculeyanos-Sabinianos): 50.
Especificación: 247.
Esponsales (sponsalia): 528.
Estipulación: v. *Stipulatio*.
Equidad: v. *Aequitas*.
Evicción (evictio): 421.
Exauguratio: 199 (A.b.2).
Excepción (exceptio): 117, 132;
clasificación: 133;
doli generalis y doli specialis: 305 (ii);
doli mali: 305 (ii): 385;
iusti domini: 255;
legis Cinciae: 452;
legis Laetoriae: 575 (B.a);
maris non traditae: 415;
non adimpleti contractus: 415;
non numeratae pecuniae: 386, 408;
pacti conventi: 132 (4), 183, 486;
quod metus causa: 306 (c.2);
rei donatae et traditae: 452;
rei iudicatae vel in iudicium deductae: 120, 124;
rei venditae et traditae: 255.
s.c. Macedoniani: 363;
s.c. Velleiani: 402; 561;
vitiosae possessionis: 217 (2-3), 218 (1), 219 (A.3),
220.
Excusación (tutor): 561.
Executores: 152, 158.
Exercitor navis: ver *Actio exercitoria*.
Exhereditatio: v. *Exhereditatio*.
Expensatio: 405, 406.
Exposición del hijo: v. *Ius exponendi*.
Expromissio: 480.

Expropiación: 233.
Extinción de las obligaciones: 469 ss.;
clasificación de los casos: 469.
Extra ordinem cognitio: 150;
apelación: 156;
características: 151;
marcha del procedimiento: 152;
pruebas: 154;
sentencia: 155;
vías de ejecución: 158.

F

Facere: 318.
Falsus tutor: 566.
Familia, concepto: 498 ss.;
de esclavos: 339;
de publicanos: 339.
Familiae emptor: 616.
Fas: 81, 531 (a y c.1).
Favor
libertatis: 100, 168 (I);
testamenti: 621 (II.1).
Fenus nauticum: 262.
Ferruminatio: 246 (b).
Festuca: 100, 174 (A);
Fianza: v. *Sponsio*; *Fideipromissio*; *Fideiussio*.
Fictio legis Corneliae: 171.
Fictus possessor: 251.
Fideicomiso: 674 ss.;
concepto: 674;
de cosas singulares: 674, 682;
de familia: 665;
de herencia: 674, 677;
de libertad: 684;
de residuo: 686;
evolución de los fideicomisos: 675;
régimen de los fideicomisos: 676.
Fideiussio: 397;
efectos: 398;
en la época de Justiniano: 401;
indemnitas: 399 (A.2);
relación entre el acreedor y los obligados: 399;
relación entre el deudor y los fideiussos: 399.
Fideipromissio: 394.
Fides
clientes: 4 (b.1);
fideicomisos: 674 ss.;
patrono: 179;
sociedad: 434;
sponsio: 381 (4);
stipulatio: 381 (3);
usufructo: 240 (C);
v. *Bona fides*.
Fiducia
cum amico: 368 (I);
cum creditore: 286.
Filosofía (influjo)
Iluminismo: 73, 90;
ius naturale: 88;
primeros filósofos: 47;
respecto de cosa: 194;
respecto de fuentes de las obligaciones: 324;
respecto de res incorpóreas: 195;

respecto de sujeto de derecho: 159 bis;
respecto de la especificación: 247.
Fiscus: 190, 293.
Flamines Dialis
adrogatio: 510 (4);
confarreatio: 513 (3).
Flumina: 200.
Fórmula: 108, 124 ss.;
arbitraria: 133 (A);
con trasposición de personas: 138' (B), 147;
ficticia: 136;
adrogatio: 506;
legis Aquiliae: 350;
manus: 512;
in factum concepta: 135;
in ius concepta: 134;
Octaviana: v. *Actio quod metus causa*;
partes: 124 ss.
Fraude (manumisión): 176 (A.iii.3);
en perjuicio de los acreedores: 466-467.
Fructus licitatio: 141 (3.a).
Frutos: 207 (d);
caídos en el fundo vecino: 234 (1);
en la rei vindicatio: 254 (2).
Fuerza mayor: v. *Casus*.
Fundaciones: 193;
v. *Piae causae*.
Fundos stipendiarios y tributarios: 229;
v. *Provincias*.
Furiosus: 187 (C), 529;
bonorum possessio: 596 (c);
curatela: 573.
Furtum: 332 ss.;
acciones: 338-339;
animus furandi: 335;
animus lucri faciendi: 336 (1);
clases: manifestum-nec manifestum: 337-338;
conceptum: 339 (a);
ejercicio de la actio furti: 340-342;
formas de comisión (furtum rei, furtum usus,
furtum possessionis): 333;
oblatum: 339 (b);
sobre qué cosas puede recaer: 334.

G

Garantías personales: v. *Fideipromissio*; *Fideiussio*;
Sponsio.
Garantías reales: v. *Hypoteca*; *Pignus*; *Prædium*.
Gastos hechos en la cosa: v. *Impensae*.
Gens (gentiles): 2, 585;
patres gentis: 3(b).
Gestio (tutor): 563 (A);
herencia: v. *Pro herede gestio*.
Gestión de negocios: 446.
Glosadores, escuela de los: 67.

H

Habere licere: 414;
stipulatio de: 421.
Habitatio (habitación): 277.
Hechos jurídicos: 298;
v. *Negocios jurídicos*.
Heredis institutio (institución de heredero): 621.

Herencia (hereditas)
 ab intestato: 581 ss.;
 adquisición: 636 ss.;
 concepto: 579;
 dañosa (damnosa): 579;
 del liberto ciudadano romano: 608;
 del liberto latino iuniano: 609;
 de los libertos dediticios: 610;
 de un filiusfamiliae: 613;
 evolución histórica: 578;
 testamentaria: 614 ss.;
 yacente: 650.
 Hereditas yacens (herencia vacante): 650.
 Hereditatis petitio: 654.
 Herederos: 579;
 ex re certa: 621;
 extraños: 639; suyos y necesarios (sui heredes):
 583, 638;
 necesarios: 637;
 protección del heredero: 653 ss.;
 situación del heredero después de aceptar la herencia: 644.
 Hermanos: germani, unilaterales: 604, 505.
 Hexabiblos: 65
 Hijos
 adoptivos: 506, 508;
 legitimados: 509;
 legitim, spurii, vulgo concepti, obscuro loco nati:
 504 (2);
 naturales: 504 (2), 509, 549, 607 (B);
 póstumos: 620.
 Humanitas: 354, 446 (1), 471 (b); 506 (b.iv), 634 (2).
 Homo: 159;
 (liber bona fidei serviens): 165 (2);
 sacer: 199 (A).
 Honor: v. *Infamia*.
 Honorarium
 en el mandato: 440 (B);
 profesiones liberales: 432 (2).
 Hyperocha: 290 (4), 296 (c).
 Hypotheca: 291 ss.;
 características: 292;
 casos especiales: 294;
 derechos del acreedor hipotecario: 295;
 extinción: 296;
 hipotecas tácitas y legales: 293.

I

Impedimentos matrimoniales: 531.
 Impensae (rei vindicatio): 254 (c).
 Imperium:
 magistrados: 11 (a.1);
 proconsulare maius et infinitum: 21 (b).
 Impubes: 187 (A.b);
 adrogatio: 506 (b.ii);
 pubertati proximi: 187 (A.b);
 ver *Púberes*.
 In bonis habere: 228.
 In causa Mancipi: v. *Mancipium*.
 Indefensus: 111, 117.
 In diem addictio: v. *Compraventa*; *Pacta adiecta*.
 Indignus: 624, 634.
 de los legados: 667.
 Ineficacia de los testamentos: 623 (B).
 Infamia: 123 (1.1), 187 (D), 354.
 Infantes: 187 (A.a);
 (infantiae proximi): 187.
 Infittando lis crescit in duplum: v. *Demanda infittans*.
 Ingenuos: 164;
 herencia de un ingenuo emancipado: 612.
 in integrum restitutio: 142, 466 (a-b);
 (menores): 575 (B.b);
 (pupilo): 567 (d).
 In iure cessio: 237;
 hereditatis: 652.
 Iniuria: 351 ss.;
 atrox iniuria: 354;
 penas: 354.
 In ius vocatio
 legis acciones: 98;
 procedimiento formulario: 111.
 Injuria (iniuria), distintos significados: 351.
 In mancipio (in causa Mancipi): 180 (A).
 Inmissio (de humo y otras emanaciones): 234 (4).
 Insinuatio: 258, 453, 544 (3).
 Institor: v. *Actio institoria*.
 Institución de heredero: v. *Heredis institutio*.
 Institutas
 de Gayo: 50,
 de Justiniano: 64 (III).
 Instrumenta
 domus: 201 (c);
 dotalia: 530; 539;
 Fundi: 201 (c).
 Intentio: 125;
 errores en la intentio: 127.
 Intercessio
 garantía: 402;
 magistrados: 11 (c).
 Interdictos: 139 ss.;
 clases: 140;
 dobles: 216;
 posesorios: 214 ss.;
 procedimientos: 141.
 Interdictio (aqua et ignis): 183 (III.1), 185, 199;
 época justiniana: 220; pródigo: 574.
 Interdictum
 de arboribus caedendis: 234 (2);
 de aqua: 268;
 de clandestina possessione: 219 (D);
 de glande legenda: 234 (1);
 de itinere actuque privato: 268;
 de liberis exhibendis et ducendis: 334 (2), 502 (e);
 demolitorium: v. *interdictum ex operis novi nuntiatione*;
 de praecario: 219 (C);
 de superficie: 281 (b);
 de uxore exhibenda et docenda: 534 (A.e.2);
 de vi armata: 219;
 ex operis novi nuntiatione: 234 (7);
 fraudatorium: 466 (b);
 quam hereditatem: 655;
 quam servitutem: 268;
 quem fundum: 256 (A);
 quem usufructum: 275;

quod legatorum: 580, 661 (D.1);
 quod vi aut clam: 235;
 quorum honorum: 655;
 Salvianum: 291 (b);
 unde vi: 219 (A), 220;
 unde vi armata: 219 (B), 220;
 utilis: 467 (c.1);
 uti possidetis: 217, 220;
 utrubi: 218, 220.
 Intereses (usurae): 207 (d.1), 362.
 Interpellatio: 463.
 Interpretatio (interpretación)
 Pontifices: 32; prudentes: 44.
 Interregnum: 3 (b.1), 12 (1.e), 17 (3).
 Interrogatio in iure: 116 (3), 152.
 Interpolaciones: 62.
 Intra vires hereditatis: 649 (1).
 Invetiae et illatae: 207 (c), 291 (a).
 Inventario (tutor): 562 (A).
 Isla (insula)
 in flumine nata: 243 (D);
 in mari nata: 242 (IV).
 Iter: 265;
 ad bauriendum: 265 (A.1);
 ad sepulchrum: 199 (B).
 Iudex: 119 (a);
 iudices dati y pedanei: 150 (4.b);
 tarea del: 121.
 Iudicatus: 105.
 Iudicem dare: 118.
 Iudicia
 imperio continens: 110;
 legitima: 109.
 Iudicis (vel arbitris) postulatio: 103.
 Iudicium
 calumniae: 118 (2), 123 (c);
 contrarium: 123 (1.d);
 dare: 118;
 domesticum: 502.
 Iura in re aliena: 262 ss.
 Iura praediorum: v. *Servidumbres*.
 Iuridici: 119 (c).
 Iurisdicção: 91, 116.
 Iurisprudentes: 44-45;
 v. *Juristas*.
 Iurisprudencia; definición: 82 (d).
 Ius: 29;
 abutendi: 224 (3), 270 (A);
 abstinerendi: 638 (B-C);
 adscrescendi: 645;
 Aelianum (Tripartita): 32;
 agendi cum patribus, magistrados: 11 (a.2), 17 (b);
 agendi cum populo, magistrados: 11 (a.2);
 altius non tollendi: 265 (B.iv);
 aureorum annulorum: 177 (A.2);
 auspicioorum (maiorum; minorum), magistrados:
 11 (a.3);
 capiendi: 620 (III);
 civile: 86;
 clasificaciones: 83 ss.;
 commercii
 ciudadanos romanos: 182;
 (libertos ciudadanos romanos): 177 (A);
 (libertos Latinos Iunianos): 177 (B);
 commune: 85;
 conubii
 ciudadanos romanos: 182;
 (libertos ciudadanos romanos): 177 (A);
 distintas acepciones: 78;
 diversos empleos: 79-80;
 edicendi, magistrados: 11 (a.2), 41;
 emphiteuticarium: 283;
 etimología: 76;
 exponendi: 502 (b);
 Flavianum: 32;
 Iuninis: 265 (B.v);
 gentium: 87-88;
 honorarium: 43, 89;
 honorum
 ciudadanos romanos: 182;
 libertos ciudadanos romanos: 177 (A);
 in agro vectigale: 263;
 liberorum: 632 (b); 571, 608;
 Iunium: 265 (B.iv);
 maius Latium; minus Latium: 184 (B.4);
 naturale: 87-88;
 ne prospectui vel luminibus officiatur: 265 (B.iv);
 offerendi et succedendi: 295 (B.II);
 v. *Successio in locum*;
 oneris ferendi: 265;
 Papirianum: 30;
 pascendi: 265 (A.2);
 perpetuum: 283;
 persequendi: 295 (C);
 postliminii: v. *Postliminium*;
 praetorium; v. *Ius honorarium*;
 praefereendi (acreedor hipotecario): 295 (B);
 del pupilo: 567 (a);
 privatum: 83;
 prohibendi: 260 (B);
 prociendi: 265;
 publice respondendi: 49;
 publicum: 83-84;
 sepulchri: 199;
 singulare: 85 (2);
 stillicidii: 265 (B.v);
 sufragii
 ciudadanos romanos: 182;
 libertos ciudadanos romanos: 177 (A);
 tigni inmitendi: 265;
 vendendi (hijo): 502 (c);
 para adoptar: 508 (1-2);
 para emancipar: 511;
 vitae necisque: 502 (a).
 Iusiurandum: 117, 152;
 in iure; in litem: 117, 123;
 liberti: 404;
 necessarium, voluntarium: 117, 123 (1.e);
 (non) calumniae: 118 (2), 153 (1).
 Iustitia, definición: 82 (a).
 Iusta causa: v. *Causa*.
 J.
 Juez que hace suya la causa: 357 (A);
 v. *Iudex*.
 Juicio de Dios (sacramentum): 101.

posibilidad de ser tutora: 561;
tutela de: 568 ss.
Municipium: 191;
v. *Personas jurídicas*.
Mutuo: 359 ss.;
acciones: 361;
formas de constitución: 360;
intereses: 362.

N

Nacimiento, requisitos para tenerlo por tal: 161.
Nasciturus: 160.
Natalium restitutio: 177.
Naturalis obligatio (obligación natural): 321.
Nautae: 339, 357 (D), 360.
Negocio jurídico: 297 ss.;
clasificaciones: 299;
elementos
accidentales (modalidades): 307 ss.;
esenciales: 300 (A);
naturales: 300 (B);
ineficacia: 315.
representación: 314;
Negotiorum gestio v. *Gestión de negocios*.
Nemine sibi ipso causam possessionis mutare potest: 210 (4).
Nemini res sua servit: 264 (a).
Nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet: 238 (b.1).
Nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest: 579, 621 (I.1), 645.
Nexum: 316.
Nomen
ciudadanos romanos: 182 (3);
del adrogado: 508 (1);
libertos ciudadanos romanos: 182 (3).
Nomina transscripticia: 405;
clases: 406.
Nomina arcaria: 405 (3).
Non bis in eadem: 120.
Non usus: 267.
Novación (novatio): 478 ss.;
necesaria: 481;
requisitos: 480.
Novelas: 64 (IV);
116 (sucesión contra el testamento): 635;
119 y 128 (herencia ab intestato): 602.
Noxae deditio (abandono noxal): 180 (A), 331 (C).
Nudo propietario (usufructo): 269.
Nulidad, actos jurídicos: 315.
Nuncupatio: 236 (5), 616.

O

Oblatio curiae: 509 (2);
v. *Legitimatio (legitimación)*.
Obligación (obligatio): 316-317;
alternativas y facultativas: 322, 387;
civiles y honorarias: 320;
correales: 339;
divisibles e indivisibles: 322;
elementos: 318;
efectos: 459 ss.;

específicas y genéricas: 322;
extinción: 459 ss.;
fuentes: 324;
literales: 403 ss.;
mancomunadas, solidarias, cumulativas y ambulatorias: 323;
naturales: 321;
obligatio y actio: 318;
qua se contraen por el consentimiento: 410 ss.;
que se contraen por escrito: 404 ss.;
que se contraen por la cosa: 358 ss.;
que se contraen por palabras: 381 ss.

Obras

realizadas en el fundo sin autorización: 234 (9);
realizadas en terreno ajeno: 234 (7).
Obsequium (patronato): 178 (a).
Obsequium: 465.
Occupatio: 242;
bellica: 242 (II).
Oneris ferendi: 264 (c.1), 264 (B.ii).
Ope consilio: 341.
Operae liberti: 178 (b).
Operae servorum: 278.
Operis novi nuntiatio: 234.
Orbi: 532.
Ordinus (liberto): 684.
Os fractum: 351.

P

Pacta adiecta, compraventa: 423.
Pactiones et stipulationes (servidumbres): 266 (III), usufructo, 272.
Pacto: 326.
Pactum commissorium
compraventa: 423 (a);
de mutuo dando: 358 (a); 359 (1);
de non petendo: 486;
de non praestanda eviczione: 421;
de retroemendo (de retrovendendo): 423 (d);
de vendendo: 290;
dispositivas: 423 (c);
distrahendi: 286;
fiducias: 286;
in diem addictio: 423 (b);
pignus: 290.
Pago: 470 ss.;
a quién se debe pagar: 473;
casos especiales v. *Solutio y Acceptitutio*,
cuándo se debe pagar: 475;
dónde se debe pagar: 474;
prueba del pago: 476;
qué se debe pagar: 471;
quién puede pagar: 472.
Pandectas v. *Digesto*.
Pandectística alemana: 72.
Paraphernales (bienes): 537.
Paráfrasis de Teófilo: 65.
Pararii: 405.
Parens manumissor: 511.
Parentesco: 499.
Partes (cosas): 207 (a).
Partición de la herencia: v. *Actio familiae erciscundae*.

Partitio legata (legado parciario): 660 (V).
Parto de la esclava: 167 (D), 207 (d.3), 271 (C.d.2).
Paterfamilias
adquisición para el: 314 (A), 516 (A);
obligaciones a cargo del: 314 (B), 516 (B);
pater emancipator: 511 (1.2), 512;
potestades: 500 ss.
Pater is est quem nuptiae demonstrant: 504 (1).
Patria potestas: 501 ss.;
ejercicio: 502;
extinción: 510;
modos de nacer: 503.
Patricios: 4 (a);
integración patricio-plebeya: 8.
Patrimonium: 196;
relaciones con familia y hereditas: 578 (I).
Patronato: 178.
Pecoris ad aquam adpulsus: 265 (A.2).
Peculio: 517;
castrense: 517 (B);
cuasi castrense: 517 (C);
profecticio: 517 (A);
v. *Bona Materna y Bona Adventicia*.
Pecunia: 196 (3), 201 (3).
Perceptio: 207 (d.4), 271.
Pérdida de la cosa debida: 491.
Peregrini: 185;
(dediticii): 185 (3).
Periculum
compraventa: 420;
enfiteusis: 284.
Permuta (permutatio): 375 (A).
Perpetuatio obligationis: 464 (a).
Perquisitio lance et licio: 337.
Persona: 159 bis;
(comienzo y fin): 160;
(servilis; servi): 159.
Personae incertae: 620.
Personas jurídicas: 188.
Pertenenencias (cosas): 207 (c).
Pesca (occupatio): 242 (I.5).
Piae causae (fundaciones): 193.
Pictura: 246 (f).
Pignoris capio: 107.
Pignus (posesión), 213;
ex iudicati causa: 158, 294 (a), 287 ss.;
pignus pignoris: 292;
pignus praetorium: 294 (b);
praedia: 294;
v. *Prenda e Hipoteca*.
Plagio (secuestro de personas): 334.
Plantatio: 245 (A).
Plazo: 310;
clases: 311;
efectos: 312.
Plebiscitos: 38.
Plebeyos: 4 (c);
ley de las XII Tablas: 8 (3);
secesión de la plebe: 8 (2).
Pluris petitio: 127 (A).
Pollicitatio: 458 (a).
Pontifices: 3 (d.1);
(adrogatio): 506 (a);
testamento: 615 (A).

Populus Romanus: 84, 189.
Posesión: 208;
ad interdicta: 213 (I);
adquisición: 210;
ad usucapionem: 240;
civil: 213 (I);
conservación: 211;
efectos: 209;
interina (sacramentum in rem): 101;
pérdida: 212;
pretoriana: 213 (B);
protección: 214 ss.;
vacua possessio: 238;
vicios de la posesión: 217.
Possessio iuris:
v. *Quasi possessio*.
Positum vel suspensum: 357.
Postliminium (ius postliminii): 170;
de cosas: 242.
Postulatio actionis: 115, 116.
Postumos: 620, 630;
postumi Aquiliani: 630;
postumi sui: 630;
postumi Vellaeiani y quasi postumi Vellaeiani: 630;
quasi postumi: 630.
Potestas
censoria del princeps: 21(c);
magistrados: 11 (a);
tribunicia del princeps: 21 (a).
Praedes litis et vindictiarum: 100.
Praedia: 294.
Praediatura: 240 (C.2.c).
Praefecti pretorio: 21 (3.b), 150, 156.
Praefectus annonae: 21 (3.c).
Praefectus urbi: 21 (3.a), 150 (4.a), 560.
Praefectus vehiculorum: 21 (3.c).
Praefectus vigilum: 21 (3.c).
Praelegatum v. *Dos praelegata*.
Praescriptio: 131;
longi temporis: 241;
longissimi temporis: 241 (B y C).
Praestare: 318, 414 (2).
Precarium: 213, 375 (C);
precarista (como possessor): 213 (B.iii).
Prenda: 288;
caracteres: 289;
contrato: 371, ss.;
efectos: 290.
Prescripción
(extintiva de acciones): 94.
Prestación: 318;
v. *Dare, Facere, Praestare*.
Préstamo marítimo v. *Fenus nauticum*.
Préstamos: 358 ss.;
pretorios: 378.
Presunción
Muciana: 542 (5).
paternidad: 504.
Presunciones: 122, 154.
Pretención de herederos: 630 ss.
Pretor
(fideicomisarios): 675;
(liberalis causa): 150;
(tutelar): 150, 560;
(urbano y peregrino): 12 (1.c), 40, 108.

Princeps; Senatus: 16 (a.1), 16 (b.2);
v. *Principado*.
Principado: 18;
constitución política: 21;
orígenes: 19-20;
¿Principado o Diarquía?: 22.
Principios fundamentales del Derecho; Ulpiano: 82 (c).
Prisión privada: 145 (2), 158 (5).
Privilegium: 85 (3).
Procedimiento
apud iudicem: 121 ss.;
arbitral: 157;
en los interdictos (per formulam arbitriam):
141 (2);
extra ordinem: 150 ss.;
formulario: 108 ss.;
in iure: 111 ss.;
legis actiones: 95 ss.;
per sponsiones et restipulationes: 141 (3).
Procheirón: 65.
Procurator: 114;
in rem suam: 400 (I), 494 (b).
Pródigo: 574.
Profanatio: 199 (A.b.2).
Pro herede gestio: 622, 640 (I).
Promissio dotis: 539.
Propiedad: v. *Dominium*.
Provincias
Caesaris: 22, 190;
gobierno de: 22 (3);
populi Romani: 22, 190.
Provocatio ad populum: 11 (a.1).
Prueba
carga de: 121;
del pago: 476;
en el procedimiento extra ordinem: 154.
Púberes (pubertad): 187;
(pubertati proximi): 187.
Publicidad de la propiedad: 268.
Purgatio morae: 464.c.

Q

Quantum ea res est (erit, fuit): 129.2.
Quarta divi Pii (quarta Antonina): 506.
Quarta Falcidia: 664.666.
Quarta Pegasiana: 680.
Quasi ex contractu: 327;
condominio: 260.D;
gestión de negocios: 449;
pago de lo indebido: 376;
tutela: 563.
Quasi ex delicto: 328, 357.
Quasi possessio: 221.
Quasi traditio: 266.
Quasi usufructus: 270 (B).
Querella inofficiosi testamenti: 633 ss.;
ejercicio: 634.
Querella non numeratae pecuniae: 386.

R

Rapina: 344.
Receptum argentarii: 380;

arbitrii: 380;
nautarum, cauponum, stabulariorum: 380.
Recompensa: 458.
Reconocimiento de hijos: 504 (I.4).
Recuperatores: 119 (b).
Redemptus ab hostibus: 180.
Reembolso (obligaciones solidarias): 391.
Registro inmobiliario: v. *Publicidad inmobiliaria*.
Regula Catoniana: 669.
Res vindicatio: 250;
contra quién se ejerce: 251;
del hijo: 502;
efectos de la sentencia: 254;
juicio de: 252;
per formulam petitoriam: 252;
per sponsionem: 252;
prueba: 253;
utilis: 456.
Relegatio in insulam: 183 (III.3).
Remisión de la obligación: 486.
Renuncia (renuntiatio), sociedad: 436 (B), 444.
Replicatio: 132 (4);
doli: 486;
legis Cinciae: 452;
pacti: 486.
Representación: 314;
de herederos: 583 (b), 588, 603;
en el mandato: 439.
Representantes procesales: 113;
v. *Cognitor y Procurator*.
Repudiación de la herencia: 642 (D).
Repudio: 548.
República: v. *Res publica*.
Res
clasificaciones: 197;
communes: 200 (A);
conceptor: 194;
consumibles: 205;
corporales et incorporeales: 195;
derelictae (abandonadas): 242 (VI);
divini iuris: 199;
divisibles-indivisibles: 206;
extra commercium: 198;
familiares del César: 190 (2);
fungibles: 204;
furtivae: 240 (A.ii);
in commercium: 201;
inventae in litore maris: 242 (III);
mancipi: 201;
muebles-inmuebles: 202;
nullus: 242, 650;
publicae: 200;
religiosae: 199 (B);
sacrae: 199 (A);
sanctae: 199 (C);
simples y compuestas: 201;
universitatis: 200 (C);
vi possessae: 240 (A.ii).
Res iudicata: 124.
Rescriptum Principis: 53 (b);
forma de adrogar: 506 (a);
forma de legitimar: 509 (iii).
Resolución
compraventa, 423 (1);

condición resolutoria: 308;
propiedad: 226.
Responsa prudentium: 44, 49.
Responsabilidad
del deudor: 460 ss.;
del heredero (ultra vires): 644;
(intra vires): 649.
Res publica: 7 ss.;
comienzos: 7;
composición política: 9 ss.;
integración patricio-plebeya: 8.
Restitutio
in integrum: v. *In integrum restitutio*;
natalium: 177 (A.2).
Retenciones (del marido al devolver la dote): 541 (3).
Reverentia: 111.
Revocación
del legado: 673 (a);
del testamento: 624;
por actos fraudulentos del deudor: 466;
v. *Actio Pauliana*; *Interdictum fraudatorium*.
Reyes (nombres): 3 (a.3).

S

Sacramentum
in personam: 102;
in rem: 99 (A);
interpretación del: 100;
monto del: 100.
Sagra privata: 506 (1 y a), 578, 651, 660 (V.1).
Sanctio (lex): 34;
(res): 199 (I).
Satisfactio: v. *Cautio*.
Scriptura: 246 (e).
Secesión de la plebe: 8.
Secuestro: v. *Sequester*.
Semel heres semper heres: 621 (III), 622 (A.5), 647, 677.
Senado
atribuciones: 17;
en la Monarquía: 3 (b);
en la República: 16.
Senadoconsulto: 17 (b), 47.
Afinianum: 601;
Apronianum: 191;
Articuleianum: 684 (3.e);
Claudianum: 172 (c);
Danusianum: 684 (3.d);
Hosidianum: 233 (1);
Iuncianum: 684 (3.b);
Iuventianum: 654 (C.D);
Largianum: 609;
Macedonianum: 363;
Neronianum: 659;
Orphitianum: 600;
Pegasianum: 680;
Plancianum: 504 (4);
Rubrianum: 684 (3.a);
Sabinianum: 601;
Silanianum: 173 (I.a);
Tertullianum: 599;
Trebellianum: 679;
Velleianum: 187, 403, 561;
Vitrastianum: 684 (3.c);
Volusianum: 233 (1).
Senatus Populusque Romanus: 17 (e).
Sentencia
efectos: 124;
en el procedimiento extra ordinem: 155;
procedimiento formulario: 123.
Separatio (frutos): 207 (d.4), 284;
bonorum (acreedores hereditarios): 648;
bonorum (heredero necesario): 638.
Sepulchrum: 199 (B);
(sepulchra familiaria y hereditaria): 199 (B.3).
Sequester (sequestratario): 213 (B.iv); 369.
Servidumbres: 263 ss.;
(clasificación): 265;
constitución: 266;
extinción: 267;
personales: v. *ususfructus*, *Usus*, *Habitatio*, *Ope-
rae servorum*;
prediales: 264;
protección: 268;
rústicas: 265;
urbanas: 265.
Servi optio: 660.
Servio Tullio (Reformas): 5-6.
Servi poenae: 172 (b).
Servus: v. *Esclavo*.
Sexo: 187 (B).
Siembra (satio): 245 (A).
Silva caedua (y non caedua): 207 (d.2), 271.
Sine re: v. *Bonorum possessio*.
Sociedad: 433 ss.;
características: 434;
disolución: 436;
distribución de las ganancias y de las pérdidas:
435;
evolución: 433;
leonina: 435.
Societas
ad exemplum fratrum suorum: 433 (1);
alicuius negotiationis: 433 (II.c);
omnium bonorum: 433 (II.a);
quaestus: 433 (II.b);
unius rei: 433 (II.d).
Sodalitates: v. *Personas jurídicas*.
Solutio
indebiti: 376 (A);
(pago): v. *Pago*;
per aes et libram: 477.
Solutionis causa adiectio: 387, 388.
Spado: 529 (C.3).
Spatium deliberandi: 640 (II.a-b), 642 (D.1), 643 (c).
Specificatio (especificación): 247.
Spes hereditatis: 419 (4).
Sponsalia: v. *Sponsales*.
Sponsio: 381 (4);
dimidiae partis: 123 (1.b);
sanza: 394 (1);
restitutio tertiae partis: 123 (1.b);
Spurii: v. *Hijos*.
Stabularii: 339, 357 (D), 380.
Statuliber: 174 (C.3).
Status: 159, 163;
civitatis: 181 ss.;

familiae: 186;
 libertatis: 164 ss.;
 rei publicae: 189 (I.3);
 v. *Familia*.
Spendium: 22, 229.
Stipulatio: 381 ss.;
 accesorias: 392;
 acciones: 384;
 alternativa: 387 (d);
 carácter abstracto: 385;
 en favor de un tercero: 388 (II);
 facultativa: 387 (d.3);
 modalidades: 387;
 novatoria: v. *Novación*;
 nulas: 388;
 poenae: 388 (II.3), 392;
 post mortem: 388 (I);
 requisitos: 382-383;
 simplemente mancomunada: 389 (I);
 solidaria (activa y pasiva): 389 ss.
Stipulatio Aquiliana: 385, 480;
 duplae: 421;
 habere licere: 421.
Stipulationes emptae et venditae hereditatis: 678.
Stipulationes partis et pro parte (legatario parciario):
 660 (V.b);
 (fideicomisos): 680.
Stipulationes praetoriae: 144.
 Subscriptio, testamento: 618.
 Subsequens matrimonium: v. *Legitimus (legitima-
 ción)*.
 Subsignatio: 294 (c).
 Successio in loco: 295.
 Successio in singula re: 577 (3).
 Sucesión
 concepto: 577 ss.;
 de posesiones para usucapir: 240;
 legítima contra el testamento: 629 ss.
 Sui heredes: 583.
 Sui iuris, pater: 498.
 Sujeto de derecho: 180.
 Superficie: 280 ss.;
 situación del superficiario: 281.
 Superfluum: 286, 290, 295.
 Sustitución de heredero: 622;
 pupilar: 622 (B);
 quasi pupilar: 622 (C);
 vulgar: 622 (A).
 Sustitución fideicomisaria: 685.
 Synallagma: 325 (C.4), 373, 411 (B).
 Syngrapha: 407.

T

Tabulae
 nuptiales: 530;
 ruptura de las tablas del testamento: 625;
 testamenti: 622.
 Tenencia (possessio naturalis): 211, 213 (B.iv.2), 368.
 Tesoro: 242 (V).
 Testamenti factio
 activa: 620 (I);
 pasiva: 620 (II).
 Testamento: 614 ss.

apertura: 626;
 calatis comitiis: 615 (A);
 desertum (destitutum): 623 (B);
 especiales: 619 (II);
 holografo: 618 (3.a);
 ineffecta: 623;
 inoficioso: 633 ss.;
 in procinctu: 613 (B);
 inútil: 623 (b);
 invalidez: 623;
 irritum: 623 (d);
 manumisión: 174 (C);
 militar: 619 (I);
 non iure factum: 623 (a);
 nuncupativo: 618 (2);
 parentis inter liberos: 619 (II.4);
 per aes et libram: 618;
 posteriorius imperfectus: 625 (2);
 praetoriano: 617;
 revocación: 624;
 ruptum: 623 (c);
 tripartitum: 613.
 Testigos (unus testis, testis nullus): 154.
 Textura: 246 (c).
 Theodosio: 26.
 Tiempo: para usucapir: 240 (E).
 Tinctura: 246 (d).
 Título: v. *Causa*.
 Traditio: 238;
 brevi manu: 210 (4), 238 (a.2.iii);
 in incertam personam: 242 (VI);
 longa manu: 238 (I), 210 (I);
 symbolica: 210 (I), 238 (2.i).
 Transacción: 118 (I), 487.
 Transmissio Theodosiana: 642 (E.c).
 Traslación
 de legado: 673 (b);
 dominium: 235 (2);
 translatio rei: 235 (2).
 Trasmisión
 de créditos: 492 ss.;
 de la herencia: 652.
 Trasposición de personas: 147 (B).
 Tetrarquía: 24.
 Tribunal de los Centumviro: 119 (c).
 Tribunales de la plebe: 8, 11, 14, 15, 20, 21, 30, 36,
 39.
 Tributum: 22, 229.
 Trinotium: 513 (A).
 Triplicatio: 132 (4).
 Turpitud: 187 (D.6).
 Tutela: 553 ss.;
 concepto: 553;
 constituida por el pretor: 560;
 de las mujeres: 568 ss.;
 de los impúberes: 554 ss.;
 ejercicio: 562 ss.;
 excusaciones: 561;
 legítima: 558;
 responsabilidad del tutor: 566;
 testamentaria: 556.
 Tutor
 Attiliano: 560;

V

dativus: 557, 560;
 de la mujer: 570;
 fiduciario: 559 (B), 571;
 legítimo: 558, 571;
 optivus: 571;
 testamentario: 555.

U

Ultra vires hereditatis: 644 (B).
 Unde vi: v. *Interdictos*.
 Universitas
 (corpora): 191 (3), 192;
 rerum: 203.
 Usucapio: 239;
 hereditatis: 240 (E.1);
 pro herede: 651;
 requisitos: 240.
 Usurae: v. *Intereses*.
 Usureceptio: 240 (C.2.c).
 Usurpatio: 240 (D.1).
 Usus: 276;
 diuturnus usus: 266;
 forma de adquirir la manus: 513 (A);
 non usus: 274 (c).
 Ususfructus: 269;
 constitución: 272;
 cosas susceptibles de: 270;
 duración: 273;
 ejercicio: 271;
 extinción: 274;
 protección: 265.
 Ut possidetis: v. *Interdictos*.
 Utrubi: v. *Interdictos*.
 Uxor, llamamiento unde vir et uxor: 594.

Vades (vadimonium)

legis acciones: 98 (3);
 procedimiento formulario: 111.
 Vectigal (vectigalia): 213 (B.i), 283, 433.
 Venditio bonorum: 148;
 trámite: 147, 158 (3).
 Venia aetatis: 575.
 Venta de hijos: 502 (C).
 Vestales: 510 (4), 568.
 Via: 265.
 Vicarius (esclavo): 517 (A.2).
 Vicios redhibitorios: 422.
 Vindex
 manus injectio: 105 (I);
 procedimiento formulario: 111 (I).
 Vindicatio
 caducorum: 654 (C.1);
 en el sacramentum: 99 (A);
 servitutis (actio confessoria): 268, 658 (A.1);
 ususfructus: 275, 658 (A.1).
 Vindicta (manumisión per vindictam): 174 (A).
 Violencia
 (vis absoluta y compulsiva): 306;
 vis armata: 219 (B.3);
 vis cottidiana: 219 (B.3);
 vis ex conventu: 219 (A.4).
 Viuda: 531 (D.4);
 pobre: (607.1).
 Voluntas
 interpretación: 302;
 manifestación: 301;
 vicios: 303 ss.;
 v. *Error, Dolo y Violencia*.
 Votum: 458 (b).

Se terminó de imprimir el día 30 de junio de 2005,
En ARTES GRÁFICAS PISCIS S.R.L.
Junín 845, Buenos Aires, República Argentina
Tirada: 2100 ejemplares

Todos X
Querecho